

An orange circle containing a white capital letter 'V'. A thin blue line connects this circle to the circular inset image on the left. The circle is positioned over a large blue abstract shape in the bottom right corner of the page.

Wytyczne PPP

Tom I: Przygotowanie Projektów PPP

Tom II: Postępowanie PPP

Tom III: Umowa o PPP

Tom IV: Zarządzanie Umową o PPP

**Tom V: Rozwiązywanie sporów
w Projektach PPP**

Publikacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2025 r.,
wersja 1.0

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021–2027 w związku z realizacją projektu nr PTFE.01.01–IZ.00–0007/23.

Opracowanie: kwiecień 2025 r.

Warunki korzystania z niniejszej publikacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oświadcza, że treść opracowania ma charakter informacyjny i pełni funkcję rekomendacji opartych o krajowe i międzynarodowe doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno–prywatnego.

MFiPR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji ani za następstwa czynności i decyzji podjętych w oparciu o niniejsze Wytyczne. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Opracowanie nie powinno być wprost stosowane, bez odpowiedniego dostosowania do konkretnego przedsięwzięcia.

MFiPR upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych. Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MFiPR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

SPIS TREŚCI:

Spis schematów	5
Słownik pojęć.....	8
Wprowadzenie.....	17
1. Specyfika sporów w Projektach PPP	29
1.1 Ryzyka sporów wynikające z charakterystyki Projektów PPP.....	30
1.1.1 Długoterminowa relacja i jej wpływ na spory	40
1.1.2 Liczba interesariuszy i ich wpływ na eskalację konfliktów.....	41
1.1.3 Finansowanie zewnętrzne i jego ograniczenia	48
1.1.4 Specyfika infrastruktury jako elementu publicznego	50
1.1.5 Regulacje prawne wpływające na sposób rozstrzygania sporów.....	52
1.2 Metody unikania i ograniczania ryzyka sporów w Projektach PPP	54
1.2.1 Należycie napisana Umowa o PPP	54
1.2.2 Transparentność i bieżąca komunikacja między stronami.....	56
1.2.3 Monitoring i kontrola Projektu PPP	60
1.2.4 Współpraca pomiędzy stronami Projektu PPP	61
1.2.5 Odpowiednie zarządzanie ryzykiem sporów przez Zespół Projektowy, Doradców oraz Niezależnego Inżyniera.....	63
2. Polubowne metody rozwiązywania sporów	73
2.1 Wielopoziomowe klauzule rozwiązywania sporów	75
2.2 Konsultacje lub negocjacje	78
2.3 Mediacje <i>ad hoc</i> lub instytucjonalne	82
2.4 Koncyliacje.....	91
2.5 Komisja Rozjemcza	95

2.6	Mechanizmy decyzji eksperckich	102
2.7	Rola ugody.....	111
2.7.1	Istota ugody	112
2.7.2	Kluczowe regulacje w zakresie ugod w Umowach PPP	115
3.	Prowadzenie sporow na drodze postepowania sadowego albo arbitrazowego	137
3.1	Postepowanie arbitrazowe.....	139
3.1.1	Wady i zalety postepowania arbitrazowego	139
3.1.2	Wybor postepowania arbitrazowego.....	143
3.1.3	Wybor arbitrazu <i>ad hoc</i> lub instytucjonalnego	145
3.2	Postepowanie przed sadem powszechnym	154
3.3	Roznice pomiedzy postepowaniem sadowym i arbitrazowym	158

Spis schematów

Schemat 1 - Konsultacje rynkowe - Jakie są główne przyczyny powstawania sporów w Projektach PPP?	18
Schemat 2 – Konsultacje Rynkowe - Jakie są główne przyczyny, dla których spory nie są rozwiązywane na etapie realizacji Umowy o PPP?	19
Schemat 3 - Konsultacje rynkowe - Na jakim etapie Projektu PPP najczęściej występowały spory?	20
Schemat 4 - Konsultacje rynkowe - Z jakimi metodami rozwiązywania sporów w Projektach PPP miała Pani/Pan do czynienia?.....	21
Schemat 5 - Konsultacje rynkowe – Którą z metod rozwiązywania sporów w Projektach PPP uważa Pani/ Pan za najskuteczniejszą?	21
Schemat 6 - Konsultacje rynkowe – Czy w Projektach PPP, były utworzone zespoły dedykowane do zarządzania roszczeniami?	22
Schemat 7 - Konsultacje rynkowe – Czy w Pani/Pana doświadczeniu strony Projektu PPP są wystarczająco przygotowane do skutecznego rozwiązywania sporów?	23
Schemat 8 – Konsultacje rynkowe – Jakie działania Pani/Pana zdaniem mogłyby poprawić współpracę stron w zakresie polubownego rozwiązywania sporów?	24
Schemat 9 – Konsultacje rynkowe - Jakie działania motywujące strony do polubownego rozwiązywania sporów powinny być wprowadzane na etapie negocjowania Umowy o PPP?.....	25
Schemat 10 - Podział ryzyk w Projektach PPP na kategorie zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Ryzyka	32
Schemat 11 - Podstawowe ryzyka wpływające na powstawanie sporów w Projektach PPP	34
Schemat 12 - Specyfika Projektów PPP i jej wpływ na powstawanie sporów.....	39
Schemat 13 - Przykładowa struktura podmiotowa Projektu PPP	42
Schemat 14 – Najczęstsze przyczyny sporów w budownictwie w Polsce	64
Schemat 15 - Zarządzanie ryzykiem sporów przez Zespół Projektowy, Doradców oraz Niezależnego Inżyniera	71

Schemat 16 - Wielopoziomowa procedura rozwiązywania sporów	76
Schemat 17 - Wskazówki w zakresie wielopoziomowych klauzul rozwiązywania sporów.....	78
Schemat 18 - Istotne cechy mediacji	83
Schemat 19 - Przykładowe opłaty mediacyjne	87
Schemat 20 - Przebieg postępowania mediacyjnego	89
Schemat 21 - Przebieg koncyliacji prowadzonych przed Sądem Polubownym przy PGRP	93
Schemat 22 – Zalety koncyliacji	94
Schemat 23 – Zalety Komisji Rozjemczej.....	98
Schemat 24 - Charakterystyczne cechy poszczególnych metod polubownego rozwiązywania sporów.....	103
Schemat 25 - Podsumowanie opisów i rezultatów poszczególnych etapów rozwiązywania konfliktów.....	108
Schemat 26 – Rola ugody	111
Schemat 27 – Zmiana Umowy o PPP na gruncie Ustawy PZP	117
Schemat 28 – Zawarcie ugody zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych	130
Schemat 29 - Mechanizm zatwierdzania ugody w świetle wymogów art. 54a Ustawy o Finansach Publicznych	132
Schemat 30 - Wybrane zalety i wady postępowania arbitrażowego	140
Schemat 31 – Kiedy arbitraż jest właściwym sposobem rozwiązywania sporów	143
Schemat 32 – Koszty postępowania arbitrażowego	147
Schemat 33 - Opłaty w sądach arbitrażowych a opłaty sądowe w Polsce.....	148
Schemat 34 - Opłaty w sądach arbitrażowych w Polsce i na świecie w sprawach rozpoznawanych przez trzech arbitrów	150
Schemat 35 - Najistotniejsze kwestie analizy przy wyborze postępowania arbitrażowego, tzw. check-lista.....	152

Schemat 36 - Najważniejsze cechy sądowego postępowania gospodarczego	156
Schemat 37 - Najistotniejsze różnice pomiędzy postępowaniem sądowym i arbitrażowym	160

Słownik pojęć

Pojęcie	Znaczenie
Budowa	oznacza wybudowanie Infrastruktury Publicznej na Nieruchomości przekazanej Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny w zakresie opisanym w PFU i zgodnie z Dokumentacją Projektową
Dokumentacja Postępowania	oznacza wszelkie dokumenty przygotowane na potrzeby Postępowania PPP, w tym dokumenty zamówienia w rozumieniu Ustawy PZP
Dokumentacja Projektowa	oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu robót budowlanych (w szczególności koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy)
Doradca / Zespół Doradców	oznacza doradców zewnętrznych, w tym m. in. doradców finansowych, prawnych i technicznych zaangażowanych przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego
Dostępność	oznacza zapewnioną Użytkownikom na zasadach określonych w Umowie o PPP możliwość korzystania z Infrastruktury Publicznej
Etap Inwestycyjny	oznacza etap obejmujący projektowanie i budowę Infrastruktury Publicznej
Etap Operacyjny	oznacza etap obejmujący Utrzymanie lub Zarządzanie

Pojęcie	Znaczenie
Etap Przygotowawczy	oznacza etap obejmujący działania w ramach przygotowania organizacyjnego Podmiotu Publicznego, Ocenę Efektywności, Postępowanie PPP, Zamknięcie Komercyjne oraz Zamknięcie Finansowe
Etap	oznacza wyodrębnioną fazę realizacji Projektu PPP, obejmującą określony zakres zadań, obowiązków i ryzyk przypisanych stronom Umowy o PPP, o odrębnej funkcji technicznej, organizacyjnej lub finansowej. Etapy mogą obejmować Etap Przygotowawczy, Etap Inwestycyjny oraz Etap Operacyjny, przy czym granice między Etapami są określone w Umowie o PPP
Generalny Wykonawca	oznacza podmiot, z którym Partner Prywatny zawiera umowę o Budowę Infrastruktury Publicznej albo zaprojektowanie i Budowę Infrastruktury Publicznej
Infrastruktura Publiczna	oznacza jakikolwiek składnik majątkowy Podmiotu Publicznego, który wykorzystywany będzie na potrzeby realizacji Projektu PPP
Instytucje Finansujące	oznacza każdy bank lub instytucję kredytową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, będącą stroną umowy kredytowej związanej z realizacją Umowy o PPP
JST	oznacza jednostkę samorządu terytorialnego
Komisja Rozjemcza	oznacza niezależny organ ustanowiony na mocy Umowy o PPP albo <i>ad hoc</i> w celu bieżącego rozstrzygania sporów pomiędzy Podmiotem Publicznym

Pojęcie	Znaczenie
	a Partnerem Prywatnym w trakcie realizacji Projektu PPP
Komitet Sterujący	oznacza przedstawicieli Podmiotu Publicznego lub Partnera Prywatnego odpowiedzialnych za decyzje strategiczne
KC	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
KPC	oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Formuła Tradycyjna / Metoda Tradycyjna	oznacza sposób realizacji projektu przez Podmiot Publiczny na skutek udzielenia zamówienia publicznego lub kilku zamówień publicznych bez zastosowania modelu PPP
Nieruchomość	oznacza działki gruntu, które powinny zostać szczegółowo opisane w Umowie o PPP, prawo do korzystania z których stanowić może wkład własny Podmiotu Publicznego w Przedsięwzięcie
Niezależny Inżynier / NI	oznacza podmiot – najczęściej instytucjonalny – działający na rzecz Projektu PPP, wyznaczony przez strony Umowy o PPP do wykonywania usług, określonych w Umowie o PPP oraz umowie z Niezależnym Inżynierem zawartej zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP

Pojęcie	Znaczenie
Ocena Efektywności	oznacza analizy dotyczące Projektu PPP, wykonywane przez Podmiot Publiczny przed ogłoszeniem Postępowania PPP, mające na celu ocenę efektywności realizacji Przedsięwzięcia w rozumieniu przepisów Ustawy o PPP
Okres Budowy	oznacza czas na realizację Budowy, zdefiniowany w Umowie o PPP
Okres Obowiązywania Umowy	oznacza określony w Umowie okres od zawarcia Umowy i kończący się w dacie Zakończenia Umowy
Okres Projektowania	oznacza okres liczony od zawarcia Umowy do zakończenia Prac Projektowych
Okres Utrzymania	oznacza okres liczony od zakończenia Budowy do Zakończenia Umowy
Operator	oznacza podmiot realizujący usługi Utrzymania lub Zarządzania

Pojęcie	Znaczenie
Opłata za Dostępność / OzD	oznacza wynagrodzenie Partnera Prywatnego płatne przez Podmiot Publiczny, uzależnione od Dostępności aktywa i jakości świadczonych usług, a nie rzeczywistego wykorzystania składnika Infrastruktury Publicznej
Partner Prywatny	oznacza partnera prywatnego w rozumieniu przepisów Ustawy o PPP i ma zastosowanie zarówno do podmiotów zainteresowanych zawarciem Umowy o PPP, podmiotów biorących udział w Postępowaniu PPP, jak też podmiotów, z którymi została zawarta Umowa o PPP
Partnerstwo Publiczno – Prywatne / PPP	oznacza partnerstwo publiczno–prywatne w rozumieniu Ustawy o PPP
Podmiot Publiczny	oznacza podmiot publiczny w rozumieniu przepisów Ustawy o PPP
Podwykonawca	oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, z którą Partner Prywatny zawrze umowę na wykonywanie określonego zakresu Umowy, w tym Generalny Wykonawca lub Operator
Postępowanie PPP / Postępowanie	oznacza postępowanie na wybór Partnera Prywatnego
Prace Projektowe / Projektowanie	oznaczają prace obejmujące wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, innej

Pojęcie	Znaczenie
	dokumentacji technicznej w celu zrealizowania Budowy zgodnie z Umową PPP
Program Funkcjonalno – Użytkowy / PFU	oznacza program funkcjonalno–użytkowy w rozumieniu Ustawy PZP oraz odpowiednich przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
Projekt PPP / Przedsięwzięcie	oznacza przedsięwzięcie w rozumieniu Ustawy o PPP
Roboty / Roboty Budowlane	oznaczają roboty budowlane prowadzone w celu zrealizowania Budowy
Rozporządzenie w sprawie Ryzyka	oznacza rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie
Spółka Projektowa	oznacza spółkę specjalnego przeznaczenia, utworzoną w celu realizacji konkretnego Projektu PPP
Spółka PPP	oznacza spółkę Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego, o której mowa w Ustawie o PPP
Standardy Utrzymania	oznaczają standardy utrzymania Infrastruktury Publicznej, określone w Umowie o PPP
SWZ	oznacza specyfikację warunków zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy PZP

Pojęcie	Znaczenie
Teren Budowy	oznacza teren, w tym Nieruchomość i wszelkie inne tereny, na których wykonywane będą Roboty Budowlane określone w Umowie o PPP
Umowa Bezpośrednia	oznacza umowę pomiędzy stronami Umowy o PPP a Instytucjami Finansującymi (lub z wyznaczonym przez Instytucje Finansujące agentem działającym na ich rzecz), na podstawie, której uzgadnia się zasady współpracy z Instytucjami Finansującymi, w szczególności w przypadku wypowiedzenia Umowy o PPP w wyniku naruszenia jej postanowień przez Partnera Prywatnego
Umowa o PPP / Umowa	oznacza umowę dotyczącą Projektu PPP, zawieraną pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym
Ustawa o PPP	oznacza ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym
Ustawa PZP	oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa o Finansach Publicznych	oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa o Odpowiedzialności za Naruszenie Dyscypliny	oznacza ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Utrzymanie	oznacza wszelkie działania i czynności Partnera Prywatnego w celu wypełnienia Standardów Utrzymania

Pojęcie	Znaczenie
	Infrastruktury Publicznej oraz zapewnienia Dostępności Infrastruktury Publicznej
Użytkownik	oznacza podmiot korzystający z Infrastruktury Publicznej (użytkownika końcowego)
Wspólny Komitet Sterujący	oznacza zespół utworzony z przedstawicieli Partnera Prywatnego oraz Podmiotu Publicznego, którzy są umocowani do podejmowania strategicznych decyzji w Projekcie PPP.
Wytyczne Tom I	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie przygotowania Projektów PPP
Wytyczne Tom II	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie prowadzenia Postępowania PPP
Wytyczne Tom III	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie Umowy o PPP
Wytyczne Tom IV	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie Zarządzania Umową o PPP
Zakończenie Umowy	oznacza zakończenie Umowy o PPP niezależnie od jego podstawy
Zamawiający	oznacza zamawiającego w rozumieniu Ustawy PZP lub Ustawy o Umowie Koncesji
Zamknięcie Finansowe	oznacza podpisanie umów dotyczących uzyskania przez Partnera Prywatnego finansowania, w łącznej

Pojęcie	Znaczenie
	kwocie wystarczającej do należytej realizacji Projektu PPP
Zarządzanie	oznacza wszelkie działania i czynności Partnera Prywatnego w celu należytego zarządzania Infrastrukturą Publiczną oraz usługami, które powinny zostać sprecyzowane w Umowie o PPP
Zamknięcie Komercyjne	oznacza zawarcie pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym Umowy o PPP
Zarządzanie Umową o PPP	oznacza ogół działań i czynności Podmiotu Publicznego w zakresie zarządzania procesami związanymi z wykonywaniem Umowy o PPP, w tym monitoring i kontrolę należytej jakości robót i usług, w tym zarządzanie zmianami, ryzykiem, roszczeniami i płatnościami oraz Zakończeniem Umowy o PPP
Zespół Projektowy PPP / Zespół Projektowy / Zespół	oznacza zespół Podmiotu Publicznego powołany do przygotowania, realizacji i monitorowania Projektu PPP

Wprowadzenie

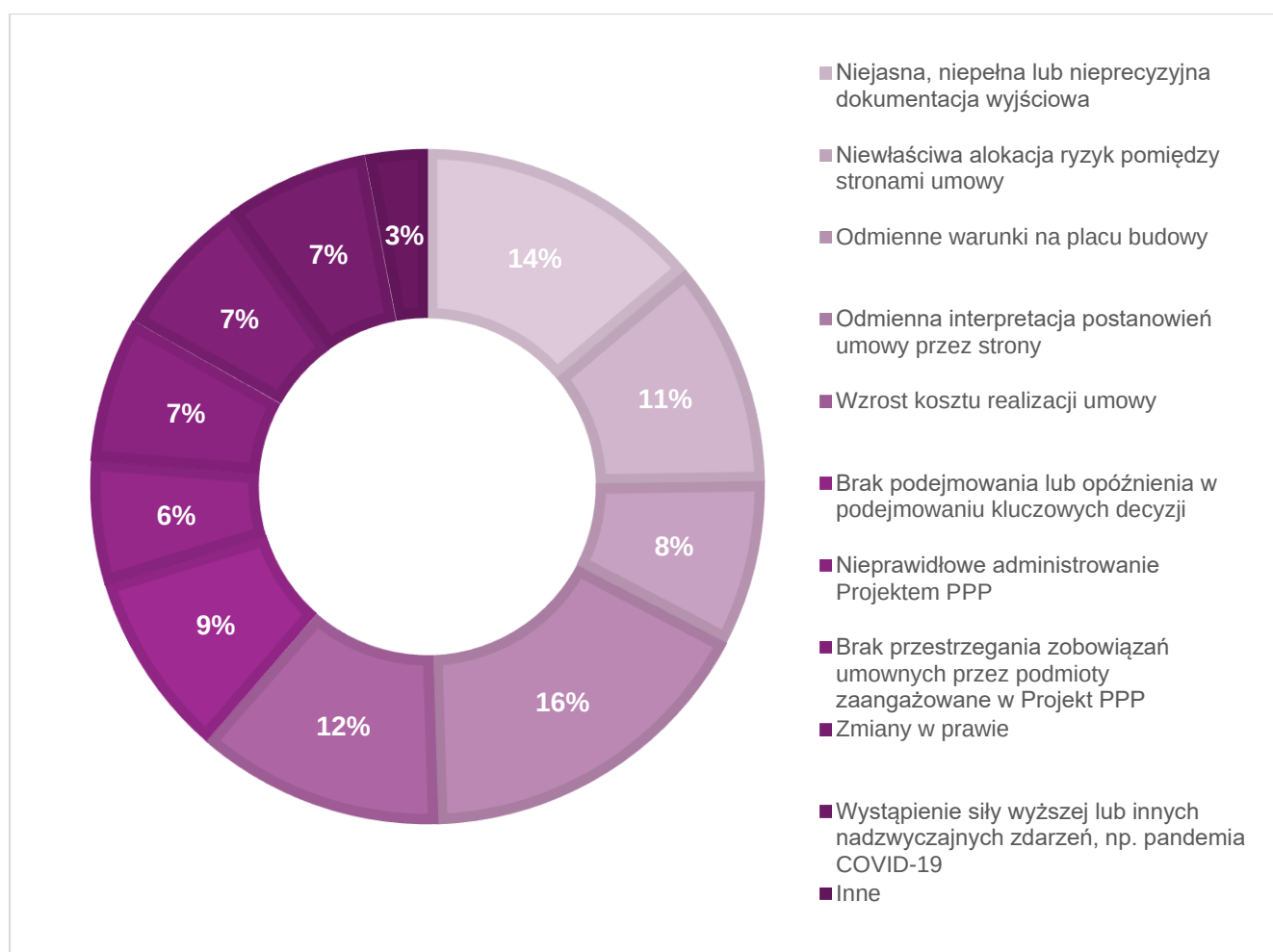
Partnerstwo publiczno–prywatne (PPP) to model współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, mający na celu realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz świadczenie usług publicznych. Dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego oraz podziałowi ryzyka, PPP stanowi skuteczne narzędzie do finansowania, budowy i zarządzania infrastrukturą publiczną, taką jak m. in. drogi, szpitale, szkoły czy instalacje energetyczne. Kluczowym elementem tej współpracy jest zrównoważony podział zasobów, odpowiedzialności oraz ryzyk, co pozwala na osiągnięcie korzyści dla obu stron.

Chociaż PPP oferuje wiele zalet, takich jak optymalizacja kosztów, innowacyjne podejście do zarządzania infrastrukturą oraz zwiększona efektywność operacyjna, nie jest wolne od wyzwań. Ze względu na długoterminowy charakter Umów o PPP, zaangażowanie wielu interesariuszy oraz specyfikę regulacyjną, w projektach tych mogą pojawiać się różnego rodzaju spory. Spór to sytuacja, w której co najmniej dwie strony mają sprzeczne stanowiska w określonej kwestii i nie mogą dojść do porozumienia. W kontekście Umów o PPP spór może wynikać z różnych przyczyn, mających charakter sporów prawnych w zakresie wykładni postanowień Umowy o PPP, czy sporów faktycznych dotyczących okoliczności wykonania Umowy o PPP, np. odmienne warunki na placu budowy czy wzrost kosztu realizacji umowy. Konflikty mogą wynikać również z różnic w celach strategicznych, odmiennych kultur organizacyjnych oraz podejść do zarządzania i egzekwowania umowy. Mogą one pojawiać się na każdym etapie realizacji Projektu PPP – od Etapu Przygotowawczego, przez Etap Inwestycyjny, aż po Etap Operacyjny.

Spory w Projektach PPP mogą mieć daleko idące konsekwencje finansowe i operacyjne. Mogą powodować opóźnienia w realizacji inwestycji, wzrost kosztów realizacji, a w skrajnych przypadkach – nawet doprowadzić do całkowitego fiaska Projektu PPP. Ponadto, nieumiejętne zarządzanie konfliktami może negatywnie wpłynąć na relacje pomiędzy stronami, osłabiając wzajemne zaufanie i utrudniając przyszłą współpracę. Dlatego kluczowe jest nie tylko zrozumienie przyczyn powstawania sporów, ale także wdrożenie skutecznych mechanizmów ich zapobiegania oraz rozwiązywania.

Z przeprowadzonych na potrzeby niniejszych Wytycznych konsultacji z podmiotami realizującymi Projekty PPP w Polsce, w tym w szczególności Podmiotami Publicznymi, Partnerami Prywatnymi lub Doradcami wynika, że główne przyczyny powstawania sporów w Projektach PPP są różnorodne, aczkolwiek najczęściej wskazywanymi przyczynami jest odmienna interpretacja postanowień Umowy o PPP przez strony (16 %) lub niejasna, niepełna lub nieprecyzyjna dokumentacja wyjściowa (14 %), w skład w której wchodzi m. in. Dokumentacja Projektowa, SWZ itp.:

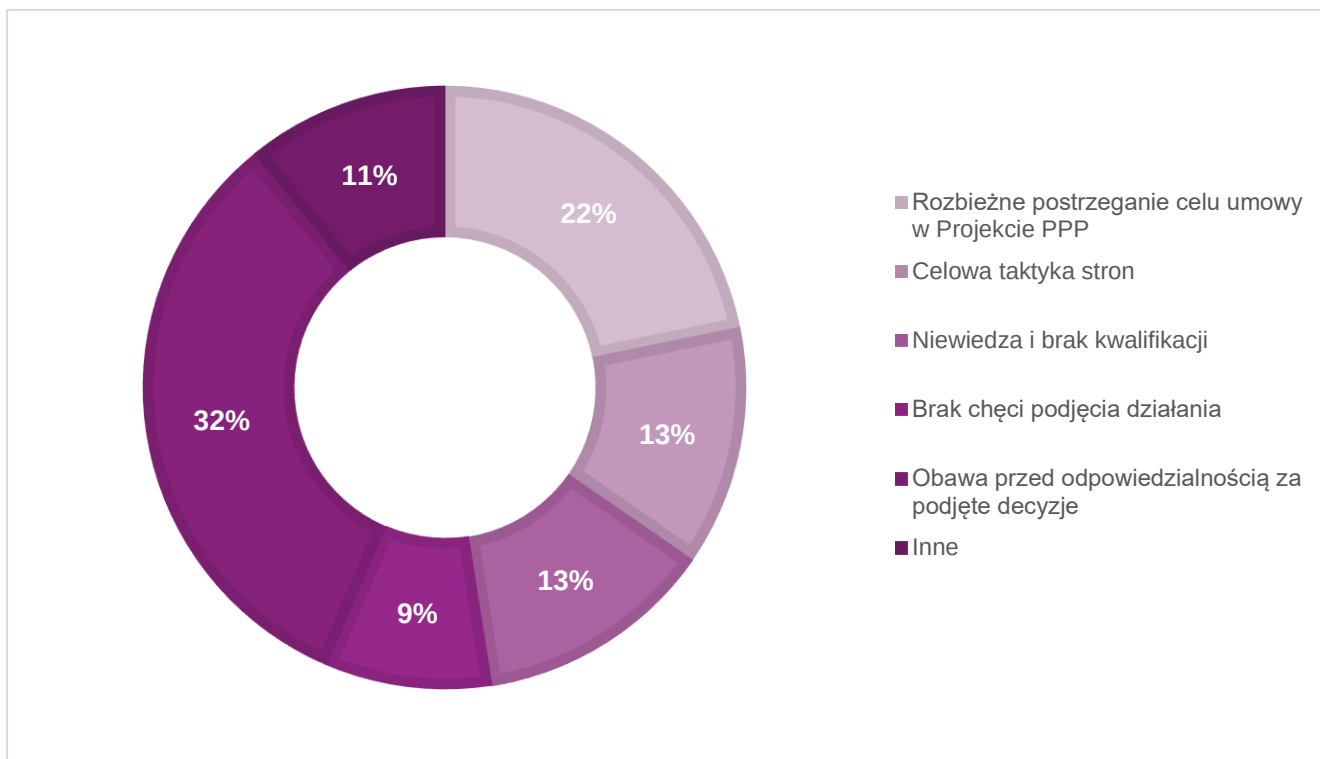
Schemat 1 - Konsultacje rynkowe - Jakie są główne przyczyny powstawania sporów w Projektach PPP?



Natomiast jako główne przyczyny braku rozwiązania sporów na etapie realizacji Umowy o PPP wskazano przede wszystkim obawę przed odpowiedzialnością za

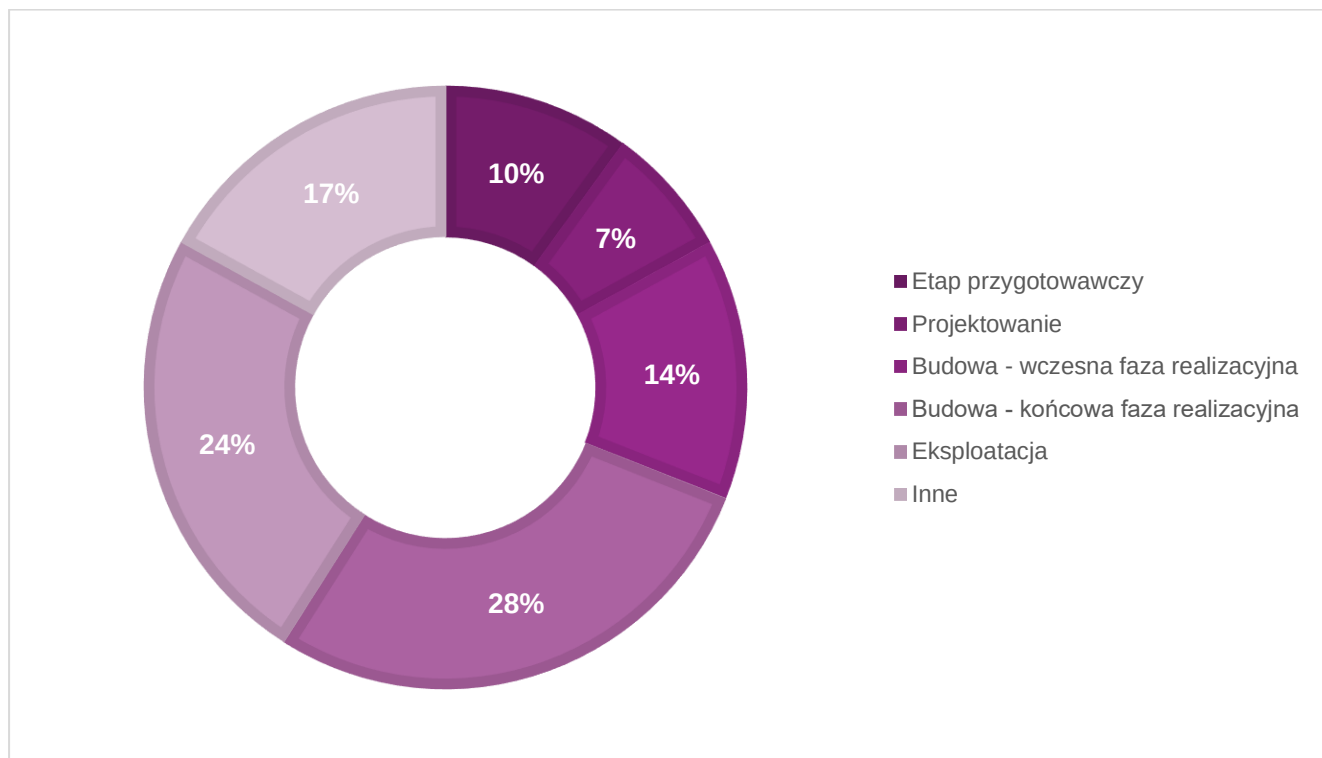
podjęte decyzje (32 %) lub rozbieżne postrzeganie celu umowy w Projekcie PPP (22 %):

Schemat 2 – Konsultacje Rynkowe - Jakie są główne przyczyny, dla których spory nie są rozwiązywane na etapie realizacji Umowy o PPP?



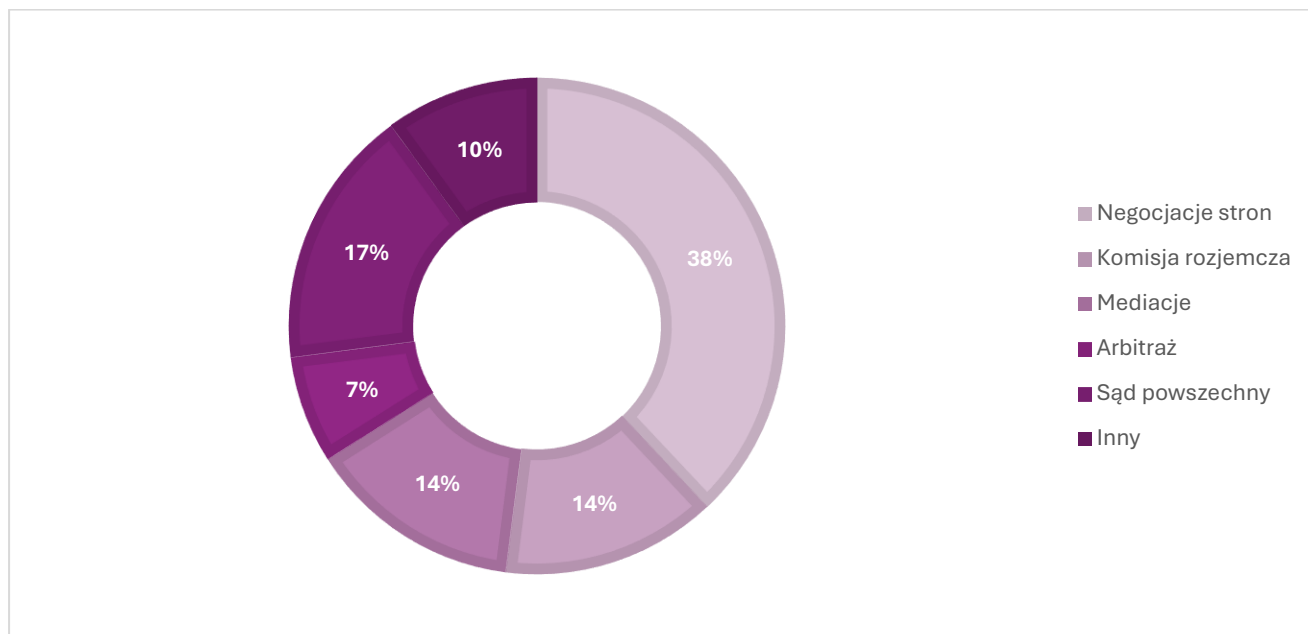
Warto wskazać, że według respondentów ponad 50 % powstałych sporów z którymi mieli do czynienia wystąpiło na końcu fazy budowlanej w ramach Etapu Inwestycyjnego lub w Etapie Operacyjnym.

Schemat 3 - Konsultacje rynkowe - Na jakim etapie Projektu PPP najczęściej występowały spory?

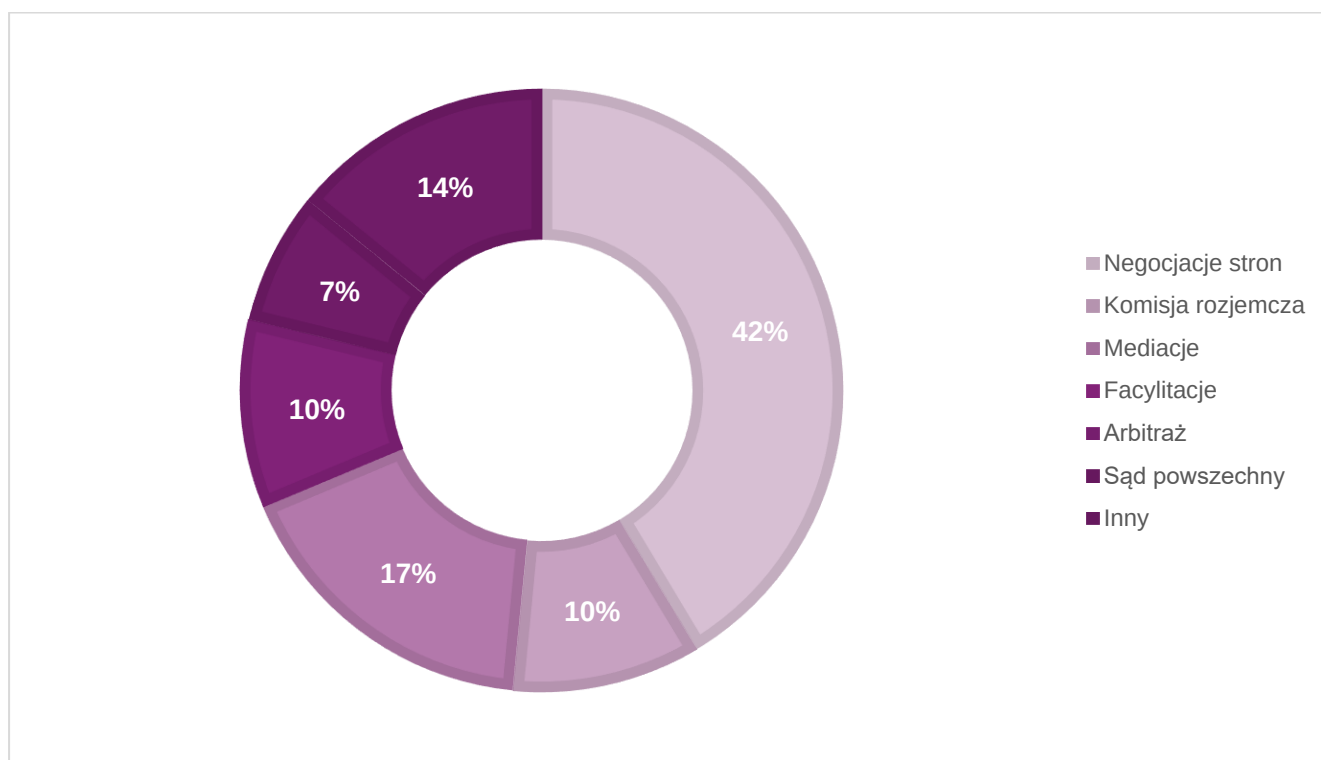


Wyniki konsultacji potwierdzają także rosnące zainteresowanie polubownymi metodami rozwiązywania sporów (ADR), takimi jak negocjacje, mediacje, koncyliacje, komisje rozjemcze oraz rozstrzygnięcie przez eksperta. Większość respondentów (66 %) wskazała bowiem, że w Projektach PPP w których brali udział, przewidziano polubowne metody rozwiązywania sporów. Przy czym najpopularniejszą metodę stanowiły negocjacje (38 %), które są również uważane za najskuteczniejszą metodę rozwiązywania sporów. Warto jednak odnotować, że pomimo powszechnego krytycyzmu działalności sądów powszechnych, część respondentów (14 %) wskazała właśnie drogę sądową jako najskuteczniejszą metodę rozwiązania sporów w Projektach PPP.

Schemat 4 - Konsultacje rynkowe - Z jakimi metodami rozwiązywania sporów w Projektach PPP miała Pani/Pan do czynienia?

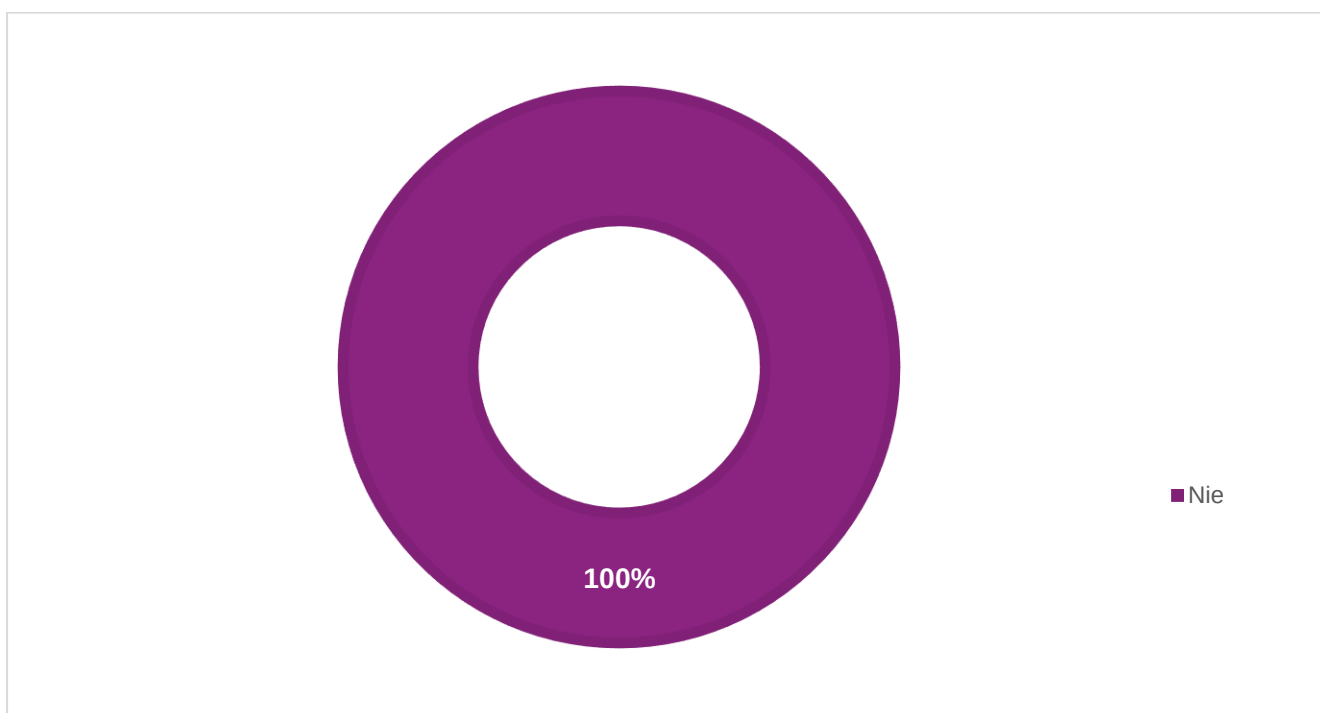


Schemat 5 - Konsultacje rynkowe – Którą z metod rozwiązywania sporów w Projektach PPP uważa Pani/ Pan za najskuteczniejszą?



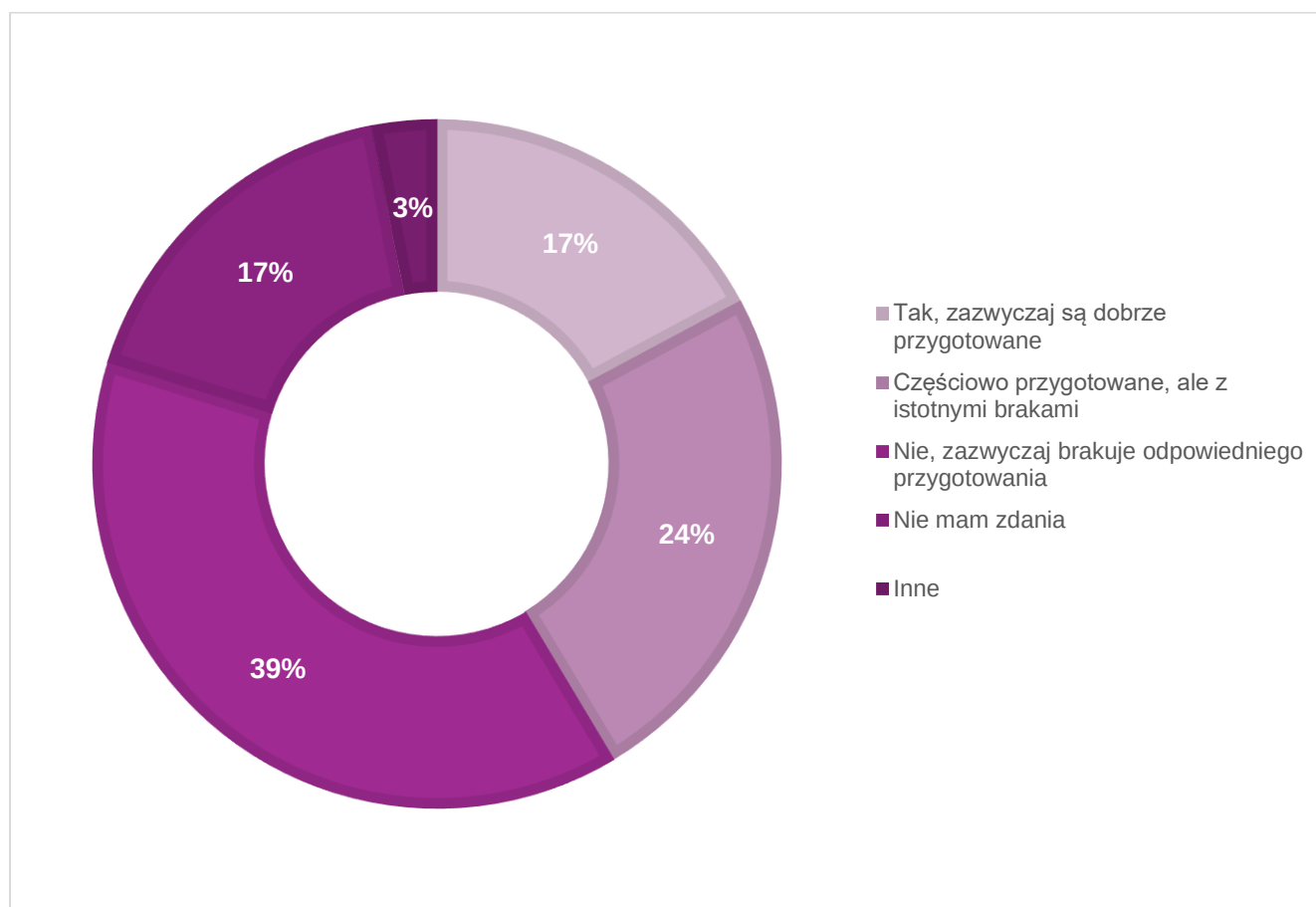
W kontekście postrzegania negocjacji jako najskuteczniejszej metody rozwiązywania sporów w Projektach PPP, warto odnotować, że 100 % respondentów wskazało, że w Projektach PPP, w których brali udział, były utworzone zespoły dedykowane do zarządzania roszczeniami, zarówno po stronie Podmiotu Publicznego, jak i Partnera Prywatnego.

Schemat 6 - Konsultacje rynkowe – Czy w Projektach PPP, były utworzone zespoły dedykowane do zarządzania roszczeniami?



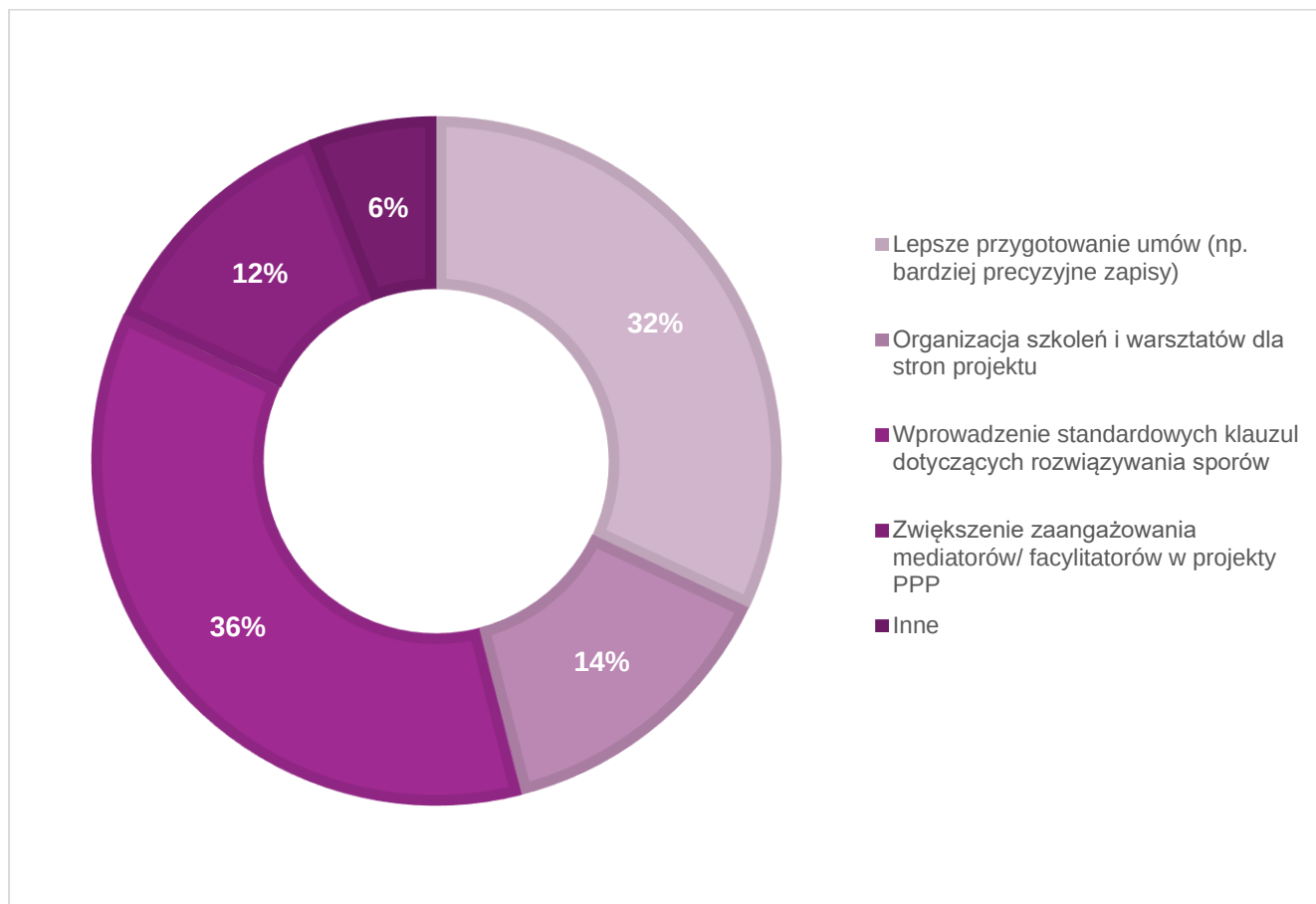
Konsultacje rynkowe potwierdzają, że dla skutecznego i efektywnego rozwiązywania powstałych sporów konieczne jest przede wszystkim odpowiednie zarządzanie powstałymi roszczeniami i przygotowanie stron do takich działań. W wielu przypadkach podmioty zaangażowane w Projekty PPP nie są jednak w pełni przygotowane do skutecznego rozwiązywania sporów, które zdarzają się jednak w wielu Projektach PPP.

Schemat 7 - Konsultacje rynkowe – Czy w Pani/Pana doświadczeniu strony Projektu PPP są wystarczająco przygotowane do skutecznego rozwiązywania sporów?

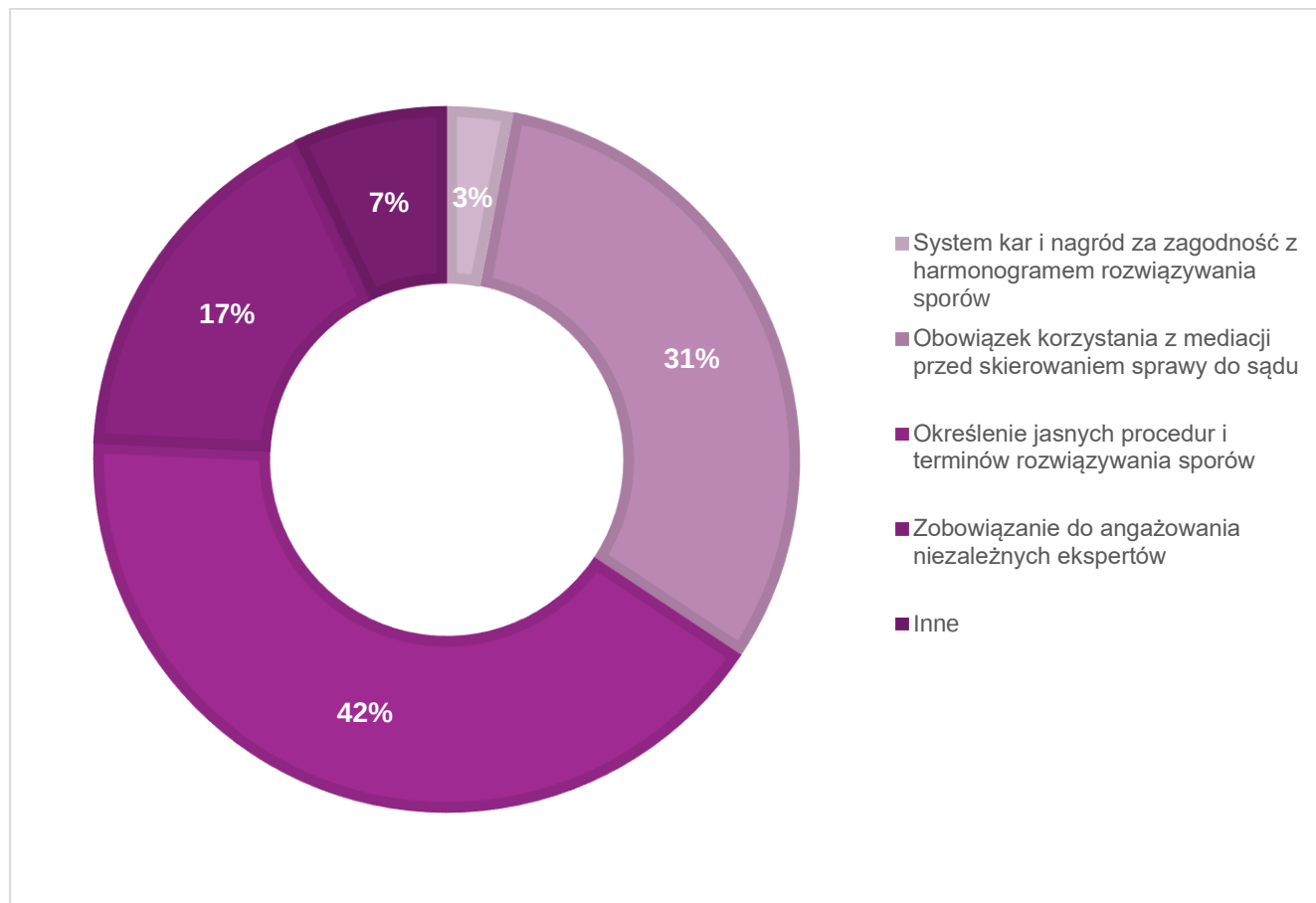


Biorąc to pod uwagę, w ocenie uczestników rynku PPP w Polsce współpracę stron Umów o PPP w zakresie polubownego rozwiązywania sporów mogłyby poprawić w szczególności takie mechanizmy jak wprowadzenie ustandaryzowanych klauzul dotyczących rozwiązywania sporów w Projektach PPP (36 %) czy lepsze przygotowywanie Umów o PPP (32 %), co może mieć przede wszystkim miejsce w oparciu o stosowanie przez Podmioty Publiczne wniosków płynących z Wytycznych Tom I - V. Uczestnicy rynku PPP w Polsce wskazują również, że motywację dla polubownego rozwiązywania sporów w Projektach PPP mogłoby stanowić w szczególności określenie jasnych procedur i terminów rozwiązywania sporów w ramach klauzul umownych (42 %) oraz obowiązek korzystania z mediacji przed skierowaniem sprawy na drogę sądową albo arbitrażową (31 %).

Schemat 8 – Konsultacje rynkowe – Jakie działania Pani/Pana zdaniem mogłyby poprawić współpracę stron w zakresie polubownego rozwiązywania sporów?



Schemat 9 – Konsultacje rynkowe - Jakie działania motywujące strony do polubownego rozwiązywania sporów powinny być wprowadzane na etapie negocjowania Umowy o PPP?



Wyniki przeprowadzonych konsultacji potwierdzają, że spór jest w większości przypadków immanentnym elementem realizacji Projektów PPP. Dlatego tak istotne jest prawidłowe przygotowanie się przez strony Projektu PPP do zarządzania nim, poprzez wcześniejsze opracowanie w Umowie o PPP jasnych reguł na wypadek zaistnienia sporu. Uczestnicy rynku PPP w Polsce jednoznacznie wskazują również, że pożądanymi ścieżkami rozstrzygania sporów są polubowne metody rozwiązywania sporów, które jeżeli zostaną prawidłowo implementowane, to pozwalają uniknąć długotrwałych i kosztownych postępowań arbitrażowych lub sądowych.

Strony Umów o PPP, mając na uwadze korzyści dla Projektu PPP oraz interes publiczny, powinny w pełni wykorzystywać dostępne przedsądowe procedury rozwiązywania sporów, zaś Podmioty Publiczne, przygotowując projekt Umowy o

PPP, powinny uwzględniać taką możliwość. Ustawa o Finansach Publicznych przewiduje taką możliwość, a odpowiednio wczesne działania mogą zapobiec eskalacji konfliktów i zapewnić sprawną realizację Umowy o PPP.

Celem Tomu V Wytycznych jest zatem dostarczenie praktycznych narzędzi i metod zarządzania sytuacjami konfliktowymi w Projektach PPP. Pomimo, że konflikty są nieuniknionym elementem długoterminowej współpracy, nie muszą prowadzić do zakłóceń w realizacji umowy. Wręcz przeciwnie – właściwie zarządzane mogą stanowić okazję do wypracowania akceptowalnych i korzystnych dla obu stron rozwiązań. W przypadku zaistnienia sporu najważniejszym zadaniem Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego jest zatem zapewnienie efektywnej kontynuacji Projektu PPP. Na niezakłóconej realizacji Przedsięwzięcia zależy także Instytucjom Finansującym.

Ponieważ szczególną rolę w procesie zarządzania sporami odgrywają polubowne metody ich rozwiązywania, to powinny być stosowane już na etapie realizacji Umowy o PPP, a najlepiej jeszcze przed powstaniem formalnego sporu. Efektywne podejście do konfliktów wymaga otwartości na dialog, umiejętności analizy stanowiska drugiej strony oraz poszukiwania rozwiązań przynoszących obopólne korzyści. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych, co sprzyja stabilności współpracy w ramach Przedsięwzięcia.

Wytyczne Tom V obejmują szereg kluczowych zagadnień, w tym:

- rolę zespołu projektowego po stronie Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego, Komitetów Sterujących, Niezależnego Inżyniera oraz ekspertów w rozwiązywaniu konfliktów w trakcie realizacji Projektów PPP;
- zastosowanie kilkustopniowych mechanizmów rozstrzygania sporów, obejmujących etap konsultacji (np. negocjacje, mediacje, Komitety Sterujące), etap ekspercki (np. Komisja Rozjemcza, niezależny ekspert), a także etap postępowania sądowego lub arbitrażowego;
- możliwości ugodowego zakończenia sporu na etapie przedsądowym, w tym zgodnie z Ustawą o PPP i Ustawą PZP oraz Ustawą o Finansach Publicznych;
- wady i zalety poszczególnych alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
- różnice między postępowaniem sądowym a arbitrażowym oraz praktyczne aspekty wyboru odpowiedniej ścieżki postępowania dla Projektów PPP.

Dzięki kompleksowemu podejściu, Wytyczne Tom V dostarczą podmiotom zaangażowanym w realizację Projektów PPP praktyczne narzędzie do efektywnego zarządzania ryzykiem sporów, co przyczyni się do stabilności, efektywności i długoterminowego sukcesu inwestycji PPP w Polsce.

Ponadto, w Wytycznych Tom V znajdują się odniesienia do poszczególnych sekcji w Wytycznych Tom I, II, III oraz IV, które są powiązane z opisywanymi tu aspektami rozwiązywania sporów w Projektach PPP. Wytyczne Tom V stanowią niezależny dokument, niemniej rekomendowane jest, aby czytelnicy zaznajomili się z treścią poprzednich Tomów Wytycznych w celu lepszego zrozumienia poszczególnych zagadnień. Wskazanie powiązanych Części i Punktów w Tomach I, II, III i IV, w których znajdują się odniesienia do zagadnień poruszanych w Tomie V, ma miejsce przede wszystkim wówczas, gdy zagadnienia te są wyjaśnione całościowo w pozostałych Tomach i mają istotne znaczenie dla zrozumienia treści zawartej w Tomie V.

Wytyczne Tom V zawierają treść podstawową oraz ramki wyróżnione w tekście, wskazujące na treści szczególnie istotne. Ramki są oznaczone w następujący sposób:

Tytuł ramki	Ikona	Znaczenie
Dobre Praktyki		wskazanie najlepszych praktyk w oparciu o doświadczenia międzynarodowe i krajowe
Przykładowe Postanowienia		wskazanie przykładowych postanowień Umów o PPP
Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom I–IV		wskazanie Części i Punktów w Wytycznych Tom I, Wytycznych Tom II, Wytycznych Tom III oraz Wytycznych Tom IV w których szczegółowo wyjaśnione są zagadnienia poruszane w Wytycznych Tom V
Przykłady		wskazanie praktycznych przykładów
Uwaga		wskazanie kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę
Źródła Informacji		wskazanie dodatkowych źródeł informacji rozszerzających treści zawarte w Wytycznych Tom V

Umieszczone w Wytycznych Tom V schematy, tabele i innego rodzaju grafiki mają za zadanie uporządkowanie informacji zawartych w tekście i ułatwienie ich analizy.

Należy zwrócić uwagę, że Wytyczne Tom V mają jedynie charakter wskazówek dla Podmiotu Publicznego co do metod zarządzania sporami w Projektach PPP. Nie stanowią one gotowych rozwiązań, ani też zamkniętego katalogu działań możliwych do podjęcia przez Podmiot Publiczny i jego Doradców, a także Partnerów Prywatnych uczestniczących w Projektach PPP. Warto bowiem wskazać, że każda sytuacja sporna wymaga indywidualnego spojrzenia oraz oceny różnych aspektów niezbędnych dla efektywnego zarządzania sporem.

Rozdział 1

Specyfika sporów w Projektach PPP

1.1 Ryzyka sporów wynikające z charakterystyki Projektów PPP

Powiązane Sekcje Wytycznych PPP Tom I–IV



Tom I: Część I Punkt 1.4 – Podział ryzyka

Tom II: Punkt 2.1 – Podstawy prawne współpracy w ramach PPP

Tom III: Część I Punkt 1 – Kluczowe czynniki sukcesu Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 2 – Charakterystyka Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 2.1 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Projektowania

Tom III: Część II Punkt 2.2 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Projektowania

Tom III: Część II Punkt 2.5 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót

Tom III: Część II Punkt 2.6 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Robót

Tom III: Część II Punkt 3.2 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania i Zarządzania

Tom III: Część II Punkt 3.3 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w Okresie Utrzymania

Tom IV: Część I Punkt 1 – Charakterystyka i znaczenie Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część I Punkt 2 – Kluczowe czynniki sukcesu Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.4 – Ryzyka i roszczenia

Przyczyny sporów w Projektach PPP są ściśle powiązane z ryzykami skorelowanymi z ich realizacją oraz podziałem (alokacją) tych ryzyk do Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego. Dobre praktyki szczegółowo opisane w Wytycznych Tom III i

Wytocznych Tom IV wymagają, by ryzyko było przypisane temu podmiotowi, który jest kompetentny do zarządzania danym ryzykiem.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Ryzyka, w Projektach PPP ryzyka można podzielić według następujących kategorii:

Schemat 10 - Podział ryzyk w Projektach PPP na kategorie zgodnie z

Rozporządzeniem w sprawie Ryzyka

ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia (np. ryzyko braku dostępności niektórych informacji wpływających na realizację projektu – przykładowo, w zakresie danych o terenie budowy)

ryzyka budowy (np. ryzyko opóźnienia, ryzyko wzrostu kosztów i cen, ryzyka błędów projektowych i nieścisłości w specyfikacji, itd.)

ryzyka związane z dostępnością (np. ryzyko braku możliwości wykonania usług w zakontraktowanej ilości)

ryzyka związane z popytem

ryzyka związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia (np. związane z ograniczoną dostępnością zewnętrznych źródeł finansowania w postaci dotacji / dofinansowania lub *project finance*)

ryzyko o charakterze politycznym

ryzyko o charakterze legislacyjnym

ryzyka makroekonomiczne

ryzyka regulacyjne

ryzyka związane z przychodowością przedsięwzięcia

ryzyko siły wyższej

ryzyka związane z rozstrzyganiem sporów

ryzyka związane z lokalizacją przedsięwzięcia

ryzyka związane ze stanem środowiska naturalnego

ryzyka związane z przekazywaniem składników majątkowych

ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych

ryzyko braku akceptacji społecznej

Powyższy podział, zaproponowany w Rozporządzeniu w sprawie Ryzyka, ma charakter przedmiotowy, tj. poszczególne ryzyka wyróżniono na podstawie ich materii. Są one charakterystyczne dla różnych Etapów realizacji Projektu PPP - niektóre z tych ryzyk materializują się tylko w jednym z Etapów (przykładowo, ryzyka związane z przychodowością Przedsięwzięcia są charakterystyczne dla Etapu Operacyjnego), inne zaś mogą wystąpić na każdym Etapie Przedsięwzięcia (np. ryzyko wzrostu cen i kosztów, ryzyko braku akceptacji społecznej, siła wyższa, zmiana prawa).

Z uwagi na długość trwania Projektu PPP utrudnionym jest taki podział ryzyk, który nie prowadziłby do nakładania się poszczególnych kryteriów podziału lub powielania ryzyk. Jak bowiem wskazano, pewne rodzaje ryzyk, w szczególności zmiana kosztów i cen, siła wyższa czy zmiana prawa, nie są bowiem charakterystyczne dla jednego konkretnego Etapu realizacji Projektu PPP i mogą się ziścić, w różnych formach, w każdym z nich. Dlatego też wydaje się, że bardziej zasadne jest dokonanie podziału ryzyk w Projektach PPP według fazy realizacji projektu, w trakcie której mogą się one ziścić.

Przykładową matrycę ryzyk (dla sektora drogowego), wraz z ich alokacją do stron Umowy o PPP, przedstawiono w Załączniku nr 8 do Wytycznych Tom I. W ślad za zaproponowaną matrycą ryzyk, można wskazać, że podstawowe ryzyka wpływające na powstawanie sporów w Projektach PPP, w podziale dla poszczególnych Etapów realizacji Projektu PPP kształtują się jak niżej:

Schemat 11 - Podstawowe ryzyka wpływające na powstawanie sporów w Projektach PPP

Etap Przygotowawczy	Etap Inwestycyjny	Etap Operacyjny
- o brak dostępności wszystkich informacji; - o lokalizacja przedsięwzięcia; - o niedoszacowanie kosztów realizacji; - o brak dostępności nakładów na realizację projektu lub ograniczona dostępność; - o ryzyko braku akceptacji społecznej; - o ryzyko polityczne i legislacyjne.	- o ryzyka budowy, w tym w szczególności ryzyko siły wyższej, zmiany prawa i wzrostu kosztów / cen; - o ryzyka związane ze stanem środowiska naturalnego; - o brak akceptacji społecznej; - o brak dostępności lub ograniczona dostępność finansowania (nakładów na realizację przedsięwzięcia); - o ryzyka związane z rozstrzygnięciem sporów; - o ryzyko braku akceptacji społecznej.	- o ryzyka związane z popytem i podażą; - o ryzyko wzrostu cen; - o ryzyko zmiany prawa - ryzyka regulacyjne i legislacyjne; - o ryzyko siły wyższej; - o brak akceptacji społecznej; - o ryzyka związane z przychodowością przedsięwzięcia.

Ryzyka związane z Etapem Przygotowawczym Przedsięwzięcia są zasadniczo ryzykami Podmiotu Publicznego – na tym etapie dochodzi dopiero bowiem do wyboru Partnera Prywatnego. Co istotne, ryzyka te mogą ujawniać się na dalszym etapie realizacji Projektu PPP – przykładowo, brak dostatecznych informacji z fazy Postępowania PPP dotyczących lokalizacji Przedsięwzięcia i panujących na Terenie

Budowy warunków (np. gruntowo – wodnych) może ujawnić się na etapie wykonywania przez Partnera Prywatnego robót ziemnych w Okresie Budowy. Ryzyko związane z niedostateczną precyzyjnością Dokumentacji Postępowania w praktyce również ujawnia się dopiero na Etapie Inwestycyjnym i może objawiać się sporami na gruncie wykładni tej dokumentacji lub błędami projektowymi. To także na Etapie Inwestycyjnym może ujawnić się ryzyko Partnera Prywatnego polegające na zbyt niskiej wycenie kosztów wykonania Robót w stosunku do warunków realizacji Przedsięwzięcia. Innymi słowy, w Projektach PPP ryzyka nie są ograniczone wyłącznie w ramach jednego Etapu realizacji Przedsięwzięcia, ale z uwagi na złożoność tych projektów (podmiotową i przedmiotową) oraz ich długotrwałość, przenoszą się pomiędzy Etapami. Biorąc pod uwagę, że w Projektach PPP przedmiot Umowy o PPP jest zazwyczaj wykonywany (budowany) na Etapie Inwestycyjnym, a następnie także utrzymywany lub zarządzany przez Partnera Prywatnego na Etapie Operacyjnym, jedność podmiotowa w Projektach PPP może być zjawiskiem pozytywnym dla zapobiegania i wczesnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych lub spornych. Partner Prywatny wiedząc bowiem, że będzie eksploatował wytworzony przez siebie składnik majątkowy, może być bowiem bardziej zmotywowany do poszukiwania optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które przyczynią się do zmniejszenia kosztów jego eksploatacji lub zwiększenia związanych z tym korzyści (tzw. inżynieria wartości, ang. *value engineering*).

Ryzyka towarzyszące Etapowi Inwestycyjnemu i Etapowi Operacyjnemu są ryzykami, które strony Umowy o PPP mogą podzielić między siebie, na zasadzie swobody umów (art. 353¹ KC). W praktyce stosuje się rozwiązania w których Partner Prywatny przyjmuje na siebie w szczególności zwykle ryzyko wzrostu cen (tj. ryzyko niebędące nadzwyczajną zmianą stosunków w rozumieniu art. 357¹ KC, ryzyka związane z pozyskaniem i utrzymaniem finansowania Projektu PPP (jeśli to Partner Prywatny je pozyskuje) oraz ryzyka związane z Robotami (opóźnienia, wzrost kosztów mieszczący się w zakresie uznawanym za tzw. ryzyko umowne lub ryzyko inflacyjne / stóp procentowych, jakość realizowanych Robót, itd.). Podmiot Publiczny przyjmuje na siebie najczęściej znaczącą część ryzyka związanego ze zdarzeniami zewnętrznymi, na które Partner Prywatny nie ma wpływu oraz ryzyka związane z wkładem własnym Podmiotu Publicznego (np. ryzyko odmiennych warunków

gruntowych na Terenie Budowy, ryzyko odnalezienia na Terenie Budowy infrastruktury zewnętrznej, zmiana prawa, działania organów administracji, itd.).

Uwaga

W praktyce można spotkać się z podejściem, zgodnie z którym to Partner Prywatny powinien ponosić większość ryzyk związanych z Etapem Inwestycyjnym i Etapem Operacyjnym, ponieważ jest podmiotem profesjonalnym, wnoszącym do projektu istotny wkład własny (finansowanie, *know-how*, zasoby ludzkie i sprzętowe, itd.).

Z charakteru Umowy o PPP, jako ram dla współpracy Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego, nie wynika jednak szczególny podział ryzyk. Co prawda Ustawa o PPP, w art. 1 ust. 2, wskazuje, że wspólna realizacja przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego opiera się na „*podziale zadań i ryzyk*” pomiędzy stronami Umowy o PPP, jednak zgodnie z poglądami doktryny prawnej, Umowa o PPP nie jest odrębnym typem umowy nazwanej. W konsekwencji, kryterium podziału zadań i ryzyk ma charakter funkcjonalny i nie jest kryterium wystarczającym (ani właściwym) do wyróżnienia Umowy o PPP jako szczególnego typu umowy na tle innych umów.

Podział zadań i ryzyk nie jest zresztą konstrukcją charakterystyczną wyłącznie dla Umów o PPP, albowiem KC zawiera przepisy alokujące konkretne ryzyka i zadania do stron określonych umów – tak dzieje się w szczególności w przypadku umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane (np. art. 633 KC – Zamawiający ponosi ryzyka związane z nieodpowiedniością dostarczonych przez niego materiałów; art. 636 KC – Generalny Wykonawca ponosi ryzyko niewłaściwego wykonywania umowy; art. 640 KC – Zamawiający ponosi ryzyko braku współdziałania z Generalnym Wykonawcą czy art. 651 KC – Zamawiający ponosi ryzyko wadliwości Dokumentacji Projektowej oraz odmienności warunków na Terenie Budowy).

Największą liczbę sporów w Projektach PPP generują tzw. ryzyka wspólne, czyli takie, które nie zostały jednoznacznie przypisane wyłącznie jednej stronie Umowy o PPP, a ich skutki mogą w różnym stopniu wpływać na sytuację obu stron. Do typowych przykładów należą m. in.: siła wyższa, istotny wzrost cen (np. kosztów

materiałów lub mediów), oraz czynniki zewnętrzne wpływające na poziom popytu. W przypadku tych ryzyk często brakuje precyzyjnych postanowień umownych regulujących sposób ich rozliczenia lub podział skutków ich wystąpienia. To zaś powoduje, że w razie ich ziszczenia się, strony mogą prezentować rozbieżne interpretacje co do wpływu danego zdarzenia na równowagę ekonomiczną Projektu PPP – zwłaszcza w zakresie uprawnienia do zmiany wynagrodzenia, przedłużenia harmonogramu lub renegocjacji zakresu świadczenia.

Jak pokazuje przykładowa matryca ryzyk (Załącznik nr 8 do Wytycznych Tom I), dla wielu ryzyk – takich jak 3.24 Siła wyższa, 3.7 Nadmierna inflacja czy 2.12 Zmiany przepisów prawa – wskazano ich wspólny charakter, pozostawiając szczegóły rozliczenia skutków zdarzenia do określenia w Umowie o PPP lub rozstrzygnięcia w toku sporu. Taka sytuacja skutkuje nie tylko potencjalnym konfliktem w trakcie realizacji Projektu PPP, ale również brakiem przewidywalności i ryzykiem utraty kontroli nad harmonogramem oraz budżetem Projektu PPP. W praktyce, wiele z tych sporów rozstrzyganych jest dopiero po zaangażowaniu podmiotów trzecich – najczęściej biegłych, ekspertów kontraktowych lub sądów – co może wpłynąć na opóźnienia w realizacji Przedsięwzięcia oraz generowanie dodatkowych kosztów po obu stronach.

Co istotne, sama alokacja ryzyka pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym – ustalana na etapie Postępowania PPP – nie stanowi zwykle bezpośredniego źródła sporu, o ile została jasno opisana i zaakceptowana. Problem pojawia się w sytuacji, gdy Umowa o PPP nie przewiduje wystarczająco szczegółowych mechanizmów operacyjnych, np. sposobu dokumentowania materializacji ryzyka, progów uprawniających do zmiany wynagrodzenia, trybu waloryzacji, czy procedury zatwierdzania kosztów. Spór nie dotyczy więc przypisania ryzyka, ale interpretacji jego konsekwencji – co w Projektach PPP, z uwagi na ich skomplikowanie i wieloletni charakter, staje się problemem o istotnych skutkach systemowych.

Dodatkowo, nadmierne przesuwanie ciężaru ryzyk na Partnera Prywatnego, często postrzegane przez Podmiot Publiczny jako sposób minimalizacji własnej ekspozycji, może w dłuższej perspektywie prowadzić do odwrotnych skutków. Taki model

alokacji powoduje zazwyczaj wzrost ceny ofertowej (uwzględniającej bufor ryzyka), a w dalszej fazie – zwiększone prawdopodobieństwo sporów, roszczeń lub prób renegotjacji Umowy o PPP. Partnerzy Prywatni, widząc brak równowagi w podziale ryzyk, mogą podejmować działania defensywne, ograniczając elastyczność, zaangażowanie czy innowacyjność, co przekłada się na niższą efektywność realizacji i eksploatacji Przedsięwzięcia. W skrajnych przypadkach może dojść do pogorszenia relacji kontraktowych i trwałego osłabienia współpracy operacyjnej, co z kolei godzi w podstawową ideę Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

Przykłady



W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym zaprojektowania, budowy i wieloletniego utrzymania kompleksu basenów miejskich, Umowa o PPP przewidywała, że Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za operacyjne funkcjonowanie obiektu, a wynagrodzenie miało być wypłacane w formie Opłaty za Dostępność.

W Umowie o PPP wskazano, że koszty zużycia mediów (energii elektrycznej, gazu, wody) w okresie operacyjnym ponosi Partner Prywatny, jednak nie przewidziano mechanizmu umożliwiającego waloryzację tych kosztów w przypadku ich istotnego wzrostu. W chwili zawierania Umowy o PPP założono stabilność cen mediów, a wzrost tych kosztów został potraktowany jako „zwykłe ryzyko operacyjne” Partnera Prywatnego.

Po rozpoczęciu Etapu Operacyjnego, w wyniku globalnych zaburzeń gospodarczych, doszło do gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej i gazu – ich poziom wzrósł o ponad 80% względem poziomu zakładanego w modelu finansowym Przedsięwzięcia. Partner Prywatny wskazał, że dalsze świadczenie usług bez mechanizmu kompensacyjnego grozi utratą płynności finansowej i wystąpił z wnioskiem o renegotjację Opłaty za Dostępność. Podmiot Publiczny odmówił, powołując się na literalne brzmienie Umowy o PPP i przypisanie kosztów eksploatacyjnych wyłącznie do Partnera Prywatnego.

Przykłady

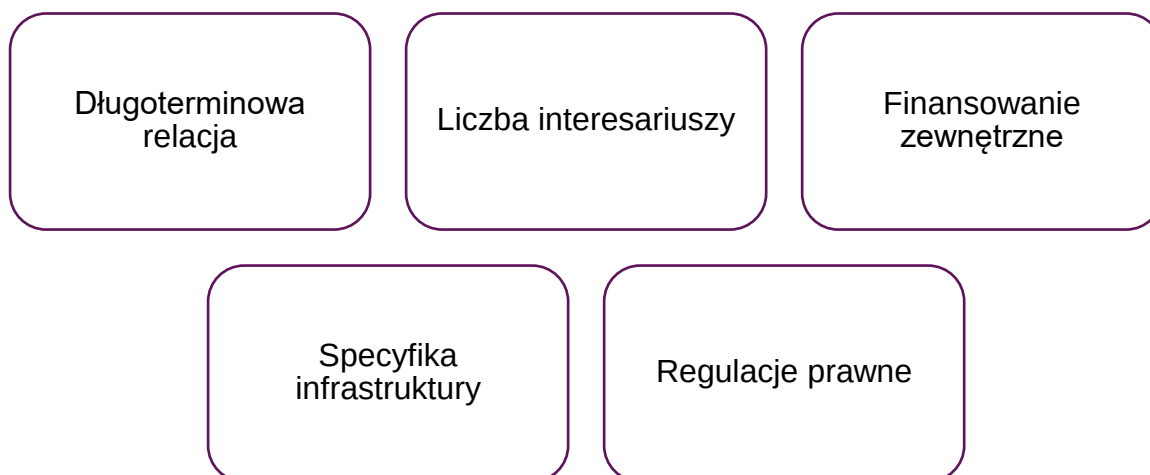


W Umowie o PPP nie przewidziano jednak żadnej procedury rozliczenia skutków ziszczenia się takiego ryzyka, jakim są nadzwyczajne zmiany kosztów zużycia mediów. Nie określono również progu, od którego taka zmiana mogłaby być uznana za podstawę waloryzacji, ani nie wskazano narzędzi pozwalających na wspólną ocenę wpływu tego ryzyka na równowagę ekonomiczną projektu.

W efekcie spór eskalował – Partner Prywatny wystąpił na drogę sądową, domagając się zmiany umowy na podstawie *klauzuli rebus sic stantibus* (art. 357¹ KC), co z kolei wymusiło na Podmiocie Publicznym utworzenie rezerwy budżetowej i zawieszenie planów rozwoju innych usług sportowych. Dodatkowo, konflikt doprowadził do pogorszenia relacji operacyjnych – Partner Prywatny ograniczył jakość świadczonych usług do poziomu minimalnych wymagań kontraktowych, a Podmiot Publiczny zaczął wprowadzać częstsze kontrole i notyfikacje formalne.

Projekty realizowane w formule PPP odróżnia od innych przedsięwzięć szereg cech charakterystycznych, w tym w szczególności:

Schemat 12 - Specyfika Projektów PPP i jej wpływ na powstawanie sporów



1.1.1 Długoterminowa relacja i jej wpływ na spory**Powiązane Sekcje Wytycznych PPP Tom I–IV**

Tom I: Część I Punkt 3 – Etapy realizacji Projektu PPP

Tom II: Punkt 3.2 Harmonogram Postępowania

Tom III: Część I Punkt 2.4 – Okres Obowiązywania Umowy o PPP

Pierwszą fundamentalną cechą Projektów PPP, odróżniającą je od realizacji inwestycji w ramach Formuły Tradycyjnej, jest jego długoterminowy charakter, który obejmuje nie tylko sam czas Budowy Infrastruktury Publicznej, ale również okres jej eksploatacji, utrzymania i zarządzania. Okres realizacji Projektu PPP najczęściej wynosi od dwudziestu (20) do nawet trzydziestu pięciu (35) lat – przy czym Etap Inwestycyjny trwa zazwyczaj od trzech (3) do pięciu (5) lat i obejmuje projektowanie oraz Roboty, zaś Etap Operacyjny może trwać pomiędzy dziesięć (10), a trzydzieści (30) lat.

Długoterminowość tej relacji ma kilka istotnych implikacji dla ryzyka sporów. Po pierwsze, Projekt PPP generuje trwałe relacje kontraktowe pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym, które nie kończą się – jak w przypadku Formuły Tradycyjnej – z chwilą odbioru robót (relacja pomiędzy stronami ogranicza się wtedy zasadniczo do realizacji obowiązków gwarancyjnych i rękojmianych). Przeciwnie, zakończenie Etapu Inwestycyjnego oznacza początek intensywnej współpracy w ramach Etapu Operacyjnego, wymagającej bieżącego uzgadniania, rozliczeń, reagowania na zmiany otoczenia i zarządzania ryzykiem.

W takich warunkach każdy spór – nawet dotyczący zakończonego już Etapu Inwestycyjnego – ma potencjał, by negatywnie wpłynąć na jakość współpracy w kolejnych latach na Etapie Operacyjnym. Może prowadzić do utraty zaufania, formalizacji komunikacji, osłabienia współdziałania stron czy ograniczenia elastyczności w rozwiązywaniu bieżących problemów. To z kolei może rzutować nie tylko na efektywność Zarządzania Umową o PPP, ale również na jakość usług świadczonych na rzecz Użytkowników.

Długoterminowość Projektu PPP oznacza także większą podatność na występowanie zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, takich jak zmiana prawa, wzrost kosztów, zmiana potrzeb społecznych czy presja polityczna. Ich materializacja często wymaga rewizji warunków ekonomicznych Umowy o PPP, a brak przewidzianych procedur adaptacyjnych – lub niechęć jednej ze stron do ich stosowania – prowadzi do eskalacji sporów.

W świetle powyższego, kultura współpracy, przejrzystość oraz odpowiednio zaprojektowane mechanizmy prewencji i rozwiązywania sporów są nie mniej istotne niż sama alokacja ryzyk w Dokumentacji Postępowania i Umowie o PPP. Należy zatem traktować długoterminowy charakter Projektu PPP jako zarówno wartość, jak i wyzwanie – wymagające świadomego kształtowania relacji instytucjonalnej między Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym, nie tylko w dniu podpisania Umowy o PPP, ale przez cały Okres Obowiązywania Umowy.

1.1.2 Liczba interesariuszy i ich wpływ na eskalację konfliktów

Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom I–IV



Tom I: Część I Punkt 1.2 - Uczestnicy Projektów PPP

Tom IV: Część I Punkt 4 - Role i odpowiedzialność stron Umowy o PPP w procesie Zarządzania Umową o PPP

Drugim czynnikiem różnicującym Projekty PPP jest duża liczba interesariuszy, których interesy nie zawsze są zbieżne.

Struktura realizacji Projektu PPP jest w praktyce bardziej złożona niż realizacja Formuły Tradycyjnej polegającej najczęściej na budowie lub świadczeniu usług, a po stronie zarówno Podmiotu Publicznego, jak i Partnera Prywatnego zaangażowana jest większa liczba podmiotów (Generalny Wykonawca, Podwykonawcy itd.). Poszczególne podmioty mogą być zaangażowane przez cały cykl życia Projektu PPP (dotyczy to głównych interesariuszy, czyli Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego, ich Doradców oraz Instytucji Finansujących), ale ich zaangażowanie

może być ograniczone tylko do jednego (lub kilku) Etapów (np. Generalny Wykonawca w Etapie Inwestycyjnym).

Schemat 13 - Przykładowa struktura podmiotowa Projektu PPP

Etap Inwestycyjny	Etap Operacyjny
○ Generalny Wykonawca robót budowlanych – jako podwykonawca Partnera Prywatnego; ○ Podwykonawcy Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych – jako dalsi Podwykonawcy Partnera Prywatnego; ○ Niezależny Inżynier; ○ Instytucje Finansujące, np. banki lub instytucje unijne w przypadku współfinansowania projektu z UE; ○ organy administracji publicznej i regulatorzy (tacy jak PINB/WINB, starosta / prezydent miasta, UDT/TDT i inni).	○ operator infrastruktury – jako podwykonawca Partnera Prywatnego; ○ Instytucje Finansujące, np. banki; ○ organy administracji publicznej i regulatorzy (WIOŚ/GIOŚ, marszałek województwa, URE, UKE, inni).

Momentami szczególnie wrażliwymi z perspektywy eskalacji sporów są tzw. punkty przejściowe między Etapami realizacji Projektu PPP – w szczególności zakończenie Etapu Inwestycyjnego i rozpoczęcie Etapu Operacyjnego. To właśnie wtedy dochodzi do:

- rozliczeń finansowych pomiędzy Partnerem Prywatnym a Generalnym Wykonawcą i jego Podwykonawcami;

- rozliczenia ewentualnych roszczeń z tytułu siły wyższej, błędów w Dokumentacji Postępowania, zmiany prawa lub warunków gruntowych;
- formalnego zakończenia współpracy z niektórymi interesariuszami (np. Niezależnym Inżynierem, częścią Doradców), którzy mogą być zainteresowani sformalizowaniem i rozstrzygnięciem nierozwiązanych dotąd sporów;
- weryfikacji jakości i zakresu wykonanych Robót w kontekście wymagań wynikających z Umowy o PPP oraz ewentualnych roszczeń Użytkowników lub organów nadzoru.

Uwaga



Generalny wykonawca robót budowlanych może być zainteresowany rozwiązaniem kwestii swoich roszczeń bezpośrednio przed lub po zakończeniu Okresu Budowy, z uwagi na zmianę stopnia jego zaangażowania w Projekt PPP. Podobnie, ewentualne roszczenia w relacji z Niezależnym Inżynierem (Podmiotu Publicznego lub Partnera Prywatnego) mogą kumulować się w końcowym okresie realizacji Etapu Inwestycyjnego, gdy standardowo kończy się współpraca z tym podmiotem. Końcowy okres Etapu Inwestycyjnego (oraz czas już po jego zakończeniu) to także moment rozliczeń z Podwykonawcami – przy czym odpowiedzialność z tego tytułu może, w zależności od postanowień Umowy o PPP, rozciągać się na Podmiot Publiczny, bądź „kończyć się” na Partnerze Prywatnym.

W tym zakresie należy wskazać, że od 2018 r. obowiązuje art. 7b Ustawy o PPP, zgodnie z którym strony Umowy o PPP mogą wyłączyć odpowiedzialność Podmiotu Publicznego względem Podwykonawców Robót. Niezbędne w tym celu jest wprowadzenie do Umowy o PPP jednoznacznego postanowienia przewidującego wyłączenie solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 647¹ KC, względem Podmiotu Publicznego. W przypadku, w którym Podmiot Publiczny jest jednocześnie inwestorem, Partner Prywatny ma obowiązek poinformować swoich Podwykonawców o powyższym wyłączeniu.

Moment, w którym powyższe podmioty – Generalny Wykonawca, jego Podwykonawcy, Operator, Niezależny Inżynier i inne podmioty kończące swoje

zaangażowanie w Projekcie PPP wraz z zakończeniem danego Etapu – mogą być zainteresowane ostatecznym rozstrzygnięciem sporów z Podmiotem Publicznym / Partnerem Prywatnym nie musi być zbieżny z dynamiką relacji umownej występującej pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym.

Należy przy tym wskazać, że Generalny Wykonawca i Podwykonawcy na Etapie Inwestycyjnym mogą przedkładać roszczenia także na potrzeby negocjacyjne, a nie wszystkie z tych roszczeń mogą być oparte na bezspornych i oczywistych podstawach faktycznych i prawnych, z których swoje roszczenia może wywodzić także Partner Prywatny (takie roszczenia – niejako wspólne dla Generalnego Wykonawcy i Partnera Prywatnego - określane są w terminologii anglojęzycznej jako *line claims* albo *back-to-back claims*). W takim przypadku Generalny Wykonawca może podnosić względem Partnera Prywatnego roszczenia, które ten może jednocześnie podnosić, na podstawie Umowy o PPP, względem Podmiotu Publicznego (kluczowa jest w tym zakresie zbieżność postanowień Umowy o PPP z umową zawartą z Generalnym Wykonawcą oraz tożsamość okoliczności faktycznych, z których wywodzone są roszczenia Partnera Prywatnego i Generalnego Wykonawcy / Podwykonawców).

Przykładem takiego roszczenia może być roszczenie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania Robót Budowlanych z uwagi na nieprzewidywalne warunki gruntowe na Terenie Budowy lub błąd w Dokumentacji Postępowania. W takiej sytuacji Generalny Wykonawca realizuje na rzecz Partnera Prywatnego roboty dodatkowe, za które zapłata nie została przewidziana w jego wynagrodzeniu w umowie z Partnerem Prywatnym. Jednocześnie, w relacji z Podmiotem Publicznym, to Partner Prywatny wykonuje roboty dodatkowe na rzecz Podmiotu Publicznego, za które nie otrzymuje właściwego ekwiwalentu (wynagrodzenia). Zakładając, że Umowa o PPP i umowa z Generalnym Wykonawcą są w tym zakresie równobrzmiące (ang. *back-to-back*), można w uproszczeniu wskazać, że roszczenie Generalnego Wykonawcy do Partnera Prywatnego jest jednocześnie roszczeniem Partnera Prywatnego do Podmiotu Publicznego. Odpowiednie zarządzanie takimi roszczeniami wymaga w szczególności właściwego uzależnienia procedury zgłaszania roszczeń w umowie z Generalnym Wykonawcą od analogicznej procedury zawartej w Umowie o PPP, w szczególności dobrania

terminów pozwalających Partnerowi Prywatnemu na przekazanie roszczenia Generalnego Wykonawcy do Podmiotu Publicznego.

Od powyższej sytuacji należy odróżnić - często występującą w praktyce - sytuację, w której Podmiot Publiczny i Partner Prywatny posiadają względem siebie roszczenia wzajemne, wywodzone z różnych podstaw prawnych, ale z tożsamych okoliczności faktycznych. Przykładem może być wystąpienie opóźnienia w realizacji kluczowego kamienia milowego Etapu Inwestycyjnego. Opóźnienie to - jeśli jest zawinione przez Partnera Prywatnego - może uprawniać Podmiot Publiczny do dochodzenia zapłaty kar umownych, a jeśli jest niezawinione (np. wynika z siły wyższej lub zmiany prawa) - może uprawniać Partnera Prywatnego do zmiany terminów realizacji Etapu Inwestycyjnego lub zwrotu dodatkowych kosztów.

Poszczególni interesariusze mogą zatem mieć także rozbieżne interesy, a ciężar wyważenia tych interesów obciąża – odpowiednio – Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego.

Uwaga



Instytucje dofinansowujące Projekt PPP z dotacji unijnej będą zainteresowane minimalizacją ryzyka sporów, w szczególności, jeśli ich podłoże mogłoby zagrażać trwałości Projektu PPP. Instytucje Finansujące takie jak banki mogą natomiast postrzegać spory i roszczenia stron z perspektywy ryzyka konieczności zwiększenia ich zaangażowania finansowego w Projekt PPP (np. zwiększenia poziomu lub wydłużenia okresu kredytowania w celu sfinansowania zaspokojenia roszczeń). Generalny Wykonawca i jego Podwykonawcy (na Etapie Inwestycyjnym) będą natomiast zainteresowani utrzymaniem lub zwiększeniem zakładanego poziomu marżowości projektu, w tym – pokryciem finansowym zgłaszanych roszczeń oraz zmniejszeniem ryzyka odpowiedzialności względem Partnera Prywatnego i/lub Podmiotu Publicznego z tytułu kar umownych bądź gwarancji jakości / rękojmi. W interesie Podmiotu Publicznego będzie natomiast utrzymanie pierwotnych założeń budżetowych (tj. brak zwiększenia kosztów realizacji projektu) oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników projektu (np. w zakresie zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych), przy zadowoleniu

Uwaga

społeczności lokalnej. Interesy Partnera Prywatnego mogą być zaś – w zależności od okoliczności – zbieżne z interesami Podmiotu Publicznego lub Generalnego Wykonawcy i Operatora (w zależności od modelu realizacji Przedsięwzięcia oraz Etapu). Na to wszystko nakładają się dodatkowo interes udziałowców i akcjonariuszy Podmiotu Publicznego, Partnera Prywatnego i pozostałych interesariuszy, których istotnym celem będzie maksymalizacja zysków z Projektu PPP.

W praktyce, ryzyko konfliktu wzmacnia również rozproszenie reżimów rozwiązywania sporów. Brak zbieżnych postanowień dotyczących właściwości sądu, formy postępowania (arbitraż, sąd powszechny, Komisja Rozjemcza) oraz harmonogramu zgłaszania roszczeń może skutkować istotnymi komplikacjami w trakcie realizacji Projektu PPP.

Dobre Praktyki

W celu ograniczenia ryzyka niejednolitego rozpoznawania powiązanych roszczeń przez różne podmioty zaangażowane w Projekt PPP, zaleca się wprowadzenie w Umowie o PPP i powiązanych umowach (z Generalnym Wykonawcą, Operatorem, Niezależnym Inżynierem, Instytucjami Finansującymi) zbieżnych mechanizmów rozwiązywania sporów. Obejmuje to w szczególności:

- wskazanie tych samych form rozstrzygania sporów (np. arbitraż instytucjonalny, Komisja Rozjemcza itd.),
- harmonizację terminów i trybów zgłaszania roszczeń (np. poprzez procedurę notyfikacji),
- uzależnienie skuteczności roszczenia w jednej relacji od działania w innej (np. umożliwienie Generalnemu Wykonawcy zgłoszenia roszczenia jedynie

Dobre Praktyki



wtedy, gdy Partner Prywatny uprzednio przekazał je Podmiotowi Publicznemu),

- przewidzenie jednolitego forum interpretacyjnego w razie rozbieżności (np. wspólne powołanie eksperta technicznego lub wspólnej Komisji Rozjemczej).

Takie rozwiązania są zgodne z międzynarodowymi standardami – m. in. zasadami współzależności kontraktowej (ang. *contractual alignment*) promowanymi przez instytucje takie jak *EPEC*¹, czy *World Bank PPP Legal Resource Center*².

Brak zbieżności postanowień o rozstrzyganiu sporów może bowiem prowadzić do:

- podwójnego ryzyka przegranej w różnych postępowaniach,
- rozbieżnych rozstrzygnięć na tle tych samych zdarzeń,
- obniżenia zdolności Partnera Prywatnego do dochodzenia roszczeń „w górę” łańcucha kontraktowego,
- lub nawet blokady możliwości efektywnego zakończenia danego Etapu.

¹ Źródło: https://www.eib.org/attachments/publications/epec_guide_to_ppp_en.pdf

² Źródło: <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/applicable-all-sectors/designing-ppp-contracts>

1.1.3 Finansowanie zewnętrzne i jego ograniczenia

Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom I–IV



Tom II: Punkt 6.5.6.1 - Wymagania dla modelu finansowego

Tom III: Część II Punkt 1.9 – Finansowanie Przedsięwzięcia

Tom III: Część II Punkt 4.2 – Model Finansowy

Tom IV: Część II Punkt 1.5 – Model Finansowy

Istotnym aspektem wpływającym na możliwość rozstrzygnięcia sporów z Umów o PPP jest finansowanie Projektu PPP ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z dotacji unijnych oraz w ramach finansowania przez Instytucje Finansujące, w których dług spłacany jest z przepływów pieniężnych generowanych przez Projekt PPP.

W odróżnieniu od Formuły Tradycyjnej, w której to Podmiot Publiczny finansuje przedsięwzięcie bezpośrednio z budżetu i posiada pełną swobodę w zakresie jego rozliczania, Partner Prywatny w Projekcie PPP pozostaje przez cały Okres Obowiązywania Umowy związany zobowiązaniami wobec Instytucji Finansujących. Z punktu widzenia rozwiązywania sporów, ten model tworzy szereg ograniczeń i napięć, których brak w Metodzie Tradycyjnej.

Zawierane w ramach Projektu PPP Umowy Bezpośrednie z Instytucjami Finansującymi często zawierają klauzule, które ograniczają Partnera Prywatnego w zakresie swobodnego rozstrzygnięcia sporów. Mogą one bowiem: (i) zakazywać zrzeczenia się roszczeń lub uznania ich niezasadności bez zgody Instytucji Finansującej (co wpływa na elastyczność Partnera Prywatnego w mediacjach lub negocjacjach), (ii) wymagać przeznaczenia środków uzyskanych z tytułu kar umownych lub odszkodowań na wcześniejszą spłatę kredytu (ograniczając dostępność tych środków do rozliczeń z Generalnym Wykonawcą lub pokrycia kosztów własnych), czy (iii) narzucać obowiązek podejmowania działań w celu dochodzenia roszczeń, nawet jeśli z perspektywy operacyjnej lub kontraktowej Partner Prywatny byłby skłonny do ich umorzenia lub odroczenia.

Umowy Bezpośrednie oraz dokumentacja finansowania mogą również przewidywać szczegółowe obowiązki informacyjne – np. obowiązek zgłaszania każdej sytuacji sporu, roszczenia lub ryzyka związanego z potencjalnym naruszeniem Umowy o PPP. Partner Prywatny jest zatem często zobowiązany do: (i) bieżącego raportowania sytuacji spornych Instytucjom Finansującym, (ii) uzyskiwania zgody Instytucji Finansującej na zawarcie ugody (co może powodować opóźnienia w rozwiązaniu sporu), oraz (iii) utrzymywania rezerw finansowych na potencjalne roszczenia, co ogranicza jego elastyczność operacyjną.

Z punktu widzenia Instytucji Finansującej, najważniejszym celem jest ochrona przepływów pieniężnych przeznaczonych na spłatę zadłużenia. W efekcie, spory mogą być postrzegane nie jako kwestia relacji kontraktowej, ale jako zagrożenie dla wykonalności struktury finansowej. Może to skutkować: (i) żądaniem zaostreżenia działań windykacyjnych przez Partnera Prywatnego, (ii) odmową refinansowania lub uwolnienia rezerw do czasu rozstrzygnięcia sporu, lub (ii) wprowadzeniem dodatkowych warunków do Umowy Bezpośredniej, np. prawa przejęcia zarządzania projektem w przypadku braku skutecznej egzekucji roszczeń (ang. *step-in rights*).

Dobre Praktyki



Aby ograniczyć ryzyka wynikające z konfliktu pomiędzy zobowiązaniami kontraktowymi i finansowymi, zaleca się zapewnienie spójności postanowień dotyczących sporów w Umowie o PPP, Umowie Bezpośredniej oraz dokumentach finansowania. W szczególności powinny one:

- jasno określać, w jakim zakresie Partner Prywatny może samodzielnie prowadzić negocjacje i zawierać ugody,
- przewidywać obowiązki informacyjne Partnera Prywatnego wobec Instytucji Finansujących, ale bez blokowania możliwości elastycznego rozwiązywania sporów z Podmiotem Publicznym,

Dobre Praktyki

- regulować, kiedy i jak Instytucje Finansujące mogą dochodzić wpływu na sposób prowadzenia sporu (np. po osiągnięciu określonego progu wartościowego),
- dopuszczać rozwiązania etapowe, np. udzielenie zgody warunkowej na zawarcie ugody z określoną strukturą płatności lub przeznaczeniem środków.

W niektórych jurysdykcjach (np. Wielka Brytania, Kanada, Australia), zaleca się, aby Doradcy już na Etapie Przygotowawczym dokonywali weryfikacji zgodności mechanizmów rozwiązywania sporów z oczekiwaniami Instytucji Finansujących. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której struktura finansowania wymusza rozwiązania niekorzystne z perspektywy efektywnego Zarządzania Umową o PPP.

1.1.4 Specyfika infrastruktury jako elementu publicznego

Jednym z czynników szczególnie wpływających na charakter i przebieg sporów w ramach Umowy o PPP jest specyfika Infrastruktury Publicznej, będącej przedmiotem Projektu PPP. W przeciwieństwie do przedsięwzięć komercyjnych, Infrastruktura Publiczna w modelu PPP pełni z zasady funkcję użyteczności publicznej, służąc zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej lub regionalnej – np. poprzez zapewnienie dostępności edukacji, ochrony zdrowia, transportu publicznego czy podstawowych usług komunalnych.

Z tego powodu, spory wynikające z realizacji Umowy o PPP nie mogą być rozpatrywane wyłącznie w kontekście interesów kontraktowych stron, jak ma to miejsce w klasycznych relacjach biznesowych. Ich rozstrzyganie musi uwzględniać również: (i) ciągłość świadczenia usług publicznych, (ii) społeczny i polityczny wymiar inwestycji, lub (iii) ryzyko naruszenia interesu publicznego w razie opóźnień lub zakłóceń w realizacji Przedsięwzięcia.

W praktyce oznacza to, że przy rozwiązywaniu sporów z Umów o PPP szczególne znaczenie ma zapewnienie niezakłóconej dostępności Infrastruktury Publicznej

(Dostępność), niezależnie od stanu relacji kontraktowych stron. Dotyczy to zwłaszcza Etapu Operacyjnego, w którym ewentualne zakłócenia świadczenia usług mogą mieć bezpośredni wpływ na jakość życia lokalnej społeczności, a także konsekwencje polityczne i budżetowe dla Podmiotu Publicznego.

Specyfika Infrastruktury Publicznej wymaga od stron Umowy o PPP: (i) szczególnego wyważenia interesów kontraktowych i publicznych w procesie rozwiązywania sporów, (ii) projektowania takich mechanizmów (np. Komisja Rozjemcza, rozstrzygnięcia tymczasowe eksperta, płatności warunkowe), które minimalizują ryzyko przerwania świadczenia usług publicznych, nawet w warunkach poważnego konfliktu, (iii) świadomego planowania rozwiązań „awaryjnych” (np. trybu tymczasowego przejęcia świadczenia usług, harmonogramów naprawczych), które będą mogły być uruchomione bez szkody dla społeczności lokalnej.

Wreszcie – specyfika Infrastruktury Publicznej jako składnika majątkowego zarządzanego przez Podmiot Publiczny, lecz wytworzonego i utrzymywanego przez Partnera Prywatnego, wymaga uwzględnienia dodatkowego elementu odpowiedzialności – nie tylko kontraktowej, ale też społecznej i reputacyjnej. Właśnie dlatego w Projektach PPP standardowe mechanizmy rozwiązywania sporów, znane z tradycyjnych relacji gospodarczych, muszą być uzupełnione o rozwiązania dostosowane do charakteru zadań publicznych.

Przykłady



W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym budowy i zarządzania parkingiem miejskim, Partner Prywatny zobowiązał się do wybudowania nowoczesnego obiektu i jego operowania przez dwadzieścia (20) lat, w zamian za możliwość czerpania przychodów z opłat parkingowych. Po zakończeniu budowy, lokalna społeczność zaczęła zgłaszać liczne skargi na wysokie stawki za parkowanie, twierdząc, że utrudnia to dostęp do centrum miasta i negatywnie wpływa na lokalnych przedsiębiorców. Podmiot Publiczny, obawiając się protestów i spadku poparcia społecznego, zażądał obniżenia stawek, na co Partner Prywatny nie chciał się zgodzić, wskazując, że wpływy z opłat są kluczowe dla rentowności

Przykłady

projektu. Zamiast wejść na drogę sądową, strony skorzystały z mechanizmów rozwiązywania sporów przewidzianych w Umowie o PPP i wspólnie opracowały rozwiązanie. Wprowadzono różnicowanie opłat, oferując mieszkańcom preferencyjne stawki, a lokalnym przedsiębiorcom możliwość wynajmu miejsc na preferencyjnych warunkach. Dzięki uwzględnieniu interesu społeczności lokalnej udało się uniknąć eskalacji konfliktu i zapewnić stabilne funkcjonowanie infrastruktury, jednocześnie zachowując równowagę ekonomiczną projektu.

1.1.5 Regulacje prawne wpływające na sposób rozstrzygania sporów**Powiązane Sekcje Wytycznych PPP Tom I–IV**

Tom I: Część I Punkt 1.1 – Podstawowe cechy modelu PPP

Tom I: Część I Punkt 2 – Otoczenie instytucjonalno-prawne Projektów PPP

Tom II: Punkt 2 – Podstawy prawne oraz tryby wyboru Partnera Prywatnego

Tom III: Część I Punkt 2.2 – Istotne warunki Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 2.6 – Zakres zastosowania Ustawy PZP do Umowy o PPP

Tom IV: Część I Punkt 4 – Role i odpowiedzialność stron Umowy o PPP w procesie Zarządzania Umową o PPP

Charakter prawny Projektów PPP sprawia, że sposób rozstrzygania sporów w ich ramach istotnie różni się od relacji czysto komercyjnych występujących w prywatnych inwestycjach gospodarczych. Choć Umowa o PPP ma charakter umowy cywilnoprawnej, jej zawarcie, wykonywanie oraz zmiana podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa publicznego, w szczególności: (i) Ustawy PZP – w zakresie dopuszczalności modyfikacji warunków Umowy o PPP, (ii) Ustawy o Finansach Publicznych – w zakresie racjonalności i legalności wydatkowania środków publicznych, lub (iii) Ustawy o Odpowiedzialności za Naruszenie Dyscypliny

– w zakresie sankcji osobistych dla osób podejmujących decyzje po stronie Podmiotu Publicznego.

W praktyce oznacza to, że rozwiązywanie sporów pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym, w tym poprzez zawieranie ugód lub aneksów do Umowy o PPP, nie może opierać się wyłącznie na przesłankach biznesowych, takich jak kompromis, opłacalność lub szybkość zakończenia konfliktu. Każde działanie w tym zakresie musi być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Kwestie te zostały szczegółowo omówione w Podrozdziale 2.7 Tomu V Wytycznych.

Powyższe ograniczenia mają istotny wpływ na elastyczność i tempo rozwiązywania sporów w ramach Projektu PPP – szczególnie w przypadkach, gdy spór dotyczy Etapu Inwestycyjnego, ale jego skutki rozciągają się na Etap Operacyjny (np. poprzez wpływ na harmonogram lub wskaźniki Dostępności).

Uwaga



W praktyce mogą wystąpić następujące konsekwencje:

- opóźnienia w zawarciu porozumień, wynikające z konieczności przeprowadzenia formalnej analizy opłacalności lub uzyskania wewnętrznych zgód i opinii,
- utrudnienia w stosowaniu mediacji lub innych metod alternatywnych (ADR), które wymagają kompromisów trudnych do uzasadnienia w świetle zasady gospodarności,
- ograniczenie możliwości częściowego uznania roszczenia lub zrzeczenia się roszczeń, nawet w przypadku ewidentnej nieopłacalności prowadzenia sporu,
- zwiększenie ryzyka „zamrożenia” sporu, jeżeli żadna ze stron nie ma wystarczającej podstawy prawnej do jego rozstrzygnięcia poza sądem.

W odróżnieniu od relacji komercyjnych, w których strony mogą niemal dowolnie zmieniać postanowienia umowy, rozłożyć ryzyko lub zawrzeć ugodę na podstawie

Uwaga

własnej oceny, w Umowach o PPP strony muszą stale odnosić się do ograniczeń ustawowych, a wszelkie działania w tym zakresie są potencjalnie kontrolowane przez organy zewnętrzne (np. NIK, RIO, KE).

1.2 Metody unikania i ograniczania ryzyka sporów w Projektach PPP**1.2.1 Należy napisać Umowę o PPP****Powiązane Sekcje Wytycznych PPP Tom I–IV**

Tom I: Część I Punkt 6 - Zarządzanie Umową o PPP

Tom III: Część I Punkt 1 – Kluczowe czynniki sukcesu Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 2.1 – Warunki konieczne Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 1.11 – Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 5 – Przypadki zewnętrzne

Tom IV: Część I Punkt 1 - Charakterystyka i znaczenie Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część I Punkt 4 - Role i odpowiedzialność stron Umowy o PPP w procesie Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1 – Narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.4 – Ryzyka i Roszczenia

Pierwszym i podstawowym narzędziem stron, pozwalającym na unikanie lub ograniczenia ryzyka sporów w Projektach PPP, jest prawidłowo napisana Umowa o PPP wraz z kluczowymi załącznikami, ponieważ to te dokumenty określają podstawowe zasady wzajemnej współpracy między stronami, ich prawa i obowiązki,

a także metody pozwalające na rozwiązanie zaistniałych rozbieżności między stronami, na długo przed powstaniem realnego sporu.

Uwaga



Należy mieć na uwadze, że znaczna liczba sporów, które przenoszą się na grunt postępowania sądowego lub arbitrażowego związanych jest z rozbieżnymi stanowiskami stron w zakresie interpretacji ich obowiązków wynikających z Umowy o PPP. Prawidłowo sporządzona Umowa o PPP pozwoli ograniczyć ryzyko przyszłych sporów.

Umowa o PPP jest dokumentem obszernym, regulującym zasady współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym długookresowo, dlatego istotne jest by jej postanowienia były spójne i czytelne dla jej stron. Umowa o PPP powinna w precyzyjny sposób określać prawa i obowiązki stron, nie pozostawiając w tym zakresie wątpliwości interpretacyjnych.

Konieczne jest także uwzględnienie w Umowie o PPP postanowień regulujących prawa i obowiązki stron z podziałem na Etap Inwestycyjny i Etap Operacyjny.

Prawidłowo skonstruowana Umowa o PPP musi cechować się również elastycznością jej postanowień. Jest to istotne z uwagi na jej długoterminowy charakter. W trakcie negocjacji w ramach Etapu Przygotowawczego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń, które mogą mieć wpływ na realizację Projektu PPP, dlatego istotne jest takie sformułowanie postanowień Umowy o PPP, aby w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnej, strony z obowiązujących postanowień mogły z łatwością odczytać swoje prawa i obowiązki. Dodatkowo, Umowa o PPP powinna przewidywać łatwe i szybkie ścieżki rozwiązania ewentualnych rozbieżności lub sporów na początkowym ich etapie, poprzez zapewnienie stałego kontaktu i współpracy między Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym. Pożądane regulacje umowne dotyczące rozwiązywania sporów w Umowach o PPP zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 2 Wytycznych Tom V.

Istotne jest, aby strony miały świadomość, że jeżeli na etapie negocjacji Umowy o PPP nie zostaną wypracowane odpowiednie zasady wzajemnej komunikacji i współpracy to zarządzanie Projektem PPP w przyszłości może okazać się trudne i wiązać się z licznymi sporami i ryzykami.

Dobre Praktyki



Prawidłowo sporządzona Umowa o PPP powinna, w szczególności:

- zawierać spójne i czytelne postanowienia;
- precyzyjnie określać prawa i obowiązki stron;
- być sporządzona z wykorzystaniem opracowanych przez branżę wytycznych;
- zawierać postanowienia uwzględniające zmianę warunków rynkowych i komercyjnych (np. klauzula waloryzacyjna);
- właściwie określać ryzyka i ich podział między stronami;
- charakteryzować się elastycznością postanowień;
- zawierać definicję pojęć;
- określać zasady wzajemnej komunikacji i współpracy stron;
- prawidłowo określać cel Projektu PPP

1.2.2 Transparentność i bieżąca komunikacja między stronami

Transparentność oraz regularna, dwustronna komunikacja pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym stanowią jedno z kluczowych narzędzi ograniczania ryzyka konfliktów i eskalacji sporów w Projekcie PPP. W odróżnieniu od Formuły Tradycyjnej, relacja w PPP ma charakter długoterminowego partnerstwa – co oznacza, że zarówno problemy techniczne, jak i organizacyjne lub finansowe muszą być rozwiązywane w czasie rzeczywistym, bez odkładania ich do momentu formalnego sporu.

Transparentna wymiana informacji pozwala na:

- wczesną identyfikację potencjalnych zagrożeń (np. opóźnień, rozbieżności w rozliczeniach, ryzyk realizacyjnych),
- zapobieganie błędnym interpretacjom postanowień Umowy o PPP lub zakresu obowiązków stron,
- wzajemne rozumienie ograniczeń instytucjonalnych (np. czasochłonności procesu decyzyjnego po stronie Podmiotu Publicznego),
- budowanie kultury współpracy, w której strony czują się współodpowiedzialne za sukces całego Projektu PPP.

Realizacja Projektu PPP wymaga zatem komunikacji między stronami w dużo wyższym stopniu niż przedsięwzięcia realizowane w Formule Tradycyjnej. Udział Podmiotu Publicznego w Projekcie PPP bardzo często wiąże się z przedłużonym okresem decyzyjnym, co może powodować niezrozumienie po stronie Partnera Prywatnego. Aby uniknąć sporów z tym związanych, Podmiot Publiczny powinien na bieżąco zachować ciągłość komunikacji z Partnerem Prywatnym i informować go o przyczynach przedłużających się procesów decyzyjnych oraz powodach podejmowania danych decyzji.

Przykłady



W hipotetycznym Projekcie PPP Zespół Projektowy PPP funkcjonował jedynie na Etapie Przygotowawczym i Inwestycyjnym, co doprowadziło do problemów na Etapie Operacyjnym. Partner Prywatny nie wiedział, kto po stronie Podmiotu Publicznego odpowiada za Zarządzanie Umową o PPP, a brak formalnej struktury decyzyjnej powodował opóźnienia i konflikty. Mimo braku oficjalnych uprawnień, niektórzy pracownicy Podmiotu Publicznego nadal podejmowali działania, co prowadziło do chaosu organizacyjnego. W efekcie komunikacja między stronami była ograniczona, a decyzje podejmowane nieskutecznie. Po pewnym czasie powołano nowy Zespół Projektowy PPP, który uporządkował zarządzanie

Przykłady



projektem. Wprowadzono stałe punkty kontaktowe, regularne raportowanie i jasne zasady współpracy. Dzięki temu poprawiła się efektywność operacyjna i zmniejszono ryzyko sporów.

Zasady komunikacji pomiędzy stronami Umowy o PPP powinny zostać określone już na początku współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, a następnie powinny być przestrzegane w całym okresie realizacji Projektu PPP.

W celu unikania nieporozumień, Podmiot Publiczny i Partner Prywatny powinni wspólnie wypracować i utrzymywać formalny system komunikacji, który obejmuje co najmniej:

- o określenie struktur odpowiedzialnych za wymianę informacji (np. Wspólny Komitet Sterujący, Zespoły Projektowe),
- o ustalenie częstotliwości i formy kontaktu (np. cykliczne spotkania robocze, raporty, tablice projektowe),
- o zdefiniowanie kanałów i terminów na przekazywanie kluczowych dokumentów, uwag, zgłoszeń roszczeń itp.,
- o zapewnienie transparentności działań po stronie Podmiotu Publicznego, w szczególności w zakresie harmonogramu decyzyjnego, uzgodnień międzywydziałowych, postępów analiz lub konsultacji z instytucjami nadzorczymi.

Dobre Praktyki



Transparentność i bieżąca komunikacja między stronami Umowy o PPP są kluczowe dla unikania konfliktów w Projekcie PPP. Międzynarodowe doświadczenia potwierdzają, że skuteczna komunikacja jest fundamentem udanych Projektów PPP:

- Raport National Audit Office (NAO) w Wielkiej Brytanii dotyczący inicjatywy Private Finance Initiative (PFI) wskazuje, że brak otwartego i uczciwego dialogu może prowadzić do opóźnień, podkreślając znaczenie tego aspektu zarządzania projektem. Relacje i komunikację między wykonawcami a sektorem publicznym oceniono jako kluczowe dla sukcesu projektów³.
- W wielu Projektach PPP, opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC lub Wytycznych Banku Światowego, stosuje się mechanizm wczesnych powiadomień (eng. *early warning notices*). Polega on na obowiązkowym zawiadamianiu drugiej strony o ryzyku problemu, zanim jeszcze stanie się on przedmiotem sporu, co umożliwia wczesne reagowanie i minimalizowanie potencjalnych konfliktów.

Powyższe przykłady podkreślają znaczenie transparentności i regularnej komunikacji w Projektach PPP, co jest kluczowe dla ich sukcesu i minimalizacji ryzyka sporów.

³ Źródło: https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2009/10/2009_performance_pfi_construction.pdf

1.2.3 Monitoring i kontrola Projektu PPP

Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom I – IV



Tom III: Część II Punkt 1.11 – Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.7 – Monitorowanie Dostępności i jakości świadczonych usług

Tom IV: Część II Punkt 1.8 – Monitorowanie aspektów finansowych Projektu PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.9.3 – Systemy zarządzania informacją

Tom IV: Część II Punkt 1.9.4 – Listy sprawdzające

Tom IV: Część II Punkt 2.3 – Wstępne określenie Standardów Utrzymania

Tom IV: Część II Punkt 3.1 – Terminowość Prac Projektowych i zgodność z przepisami prawa oraz PFU

Tom IV: Część II Punkt 3.3 – Zgodność robót budowlanych z PFU i ich jakość

Tom IV: Część II Punkt 4.1 – Weryfikacja jakości świadczonych usług oraz Dostępności Infrastruktury Publicznej

Istotnym elementem unikania sporów jest prowadzenie przez Podmiot Publiczny stałego monitoringu i kontroli realizacji Projektu PPP przez Partnera Prywatnego. Poprzez stały monitoring Podmiot Publiczny ma możliwość wykrycia ewentualnych nieprawidłowości we wczesnym etapie i zainicjować konieczne działania zaradcze po stronie Partnera Prywatnego.

W praktyce, monitoring i kontrola realizacji Projektu PPP opiera się na samokontroli Partnera Prywatnego, który sporządza cykliczne raporty na temat swojej działalności i przekazuje je do Podmiotu Publicznego.

Podmiot Publiczny nie powinien jednak ograniczać swoich czynności kontrolnych wyłącznie do analizy przekazywanych przez Partnera Prywatnego raportów. Zaleca się prowadzenie dodatkowych kontroli realizacji Projektu PPP, doraźnych wizji lokalnych, weryfikacji skarg ze strony Użytkowników oraz kontroli w zakresie Dostępności.

Odpowiednio prowadzone działania kontrolne i monitorowanie realizacji Projektu PPP przez Partnera Prywatnego pozwalają na identyfikację bieżących ryzyk i ich neutralizowanie na wczesnym etapie, zanim nastąpi eskalacja w postaci sporu między stronami Umowy o PPP.

Dobre Praktyki



W wielu przypadkach (np. w modelach PPP w Australii czy Nowej Zelandii) stosuje się dedykowane platformy elektroniczne, za pomocą których monitorowane są wskaźniki jakości usług, poziom Dostępności, incydenty i reklamacje – co znacząco podnosi przejrzystość działań i pozwala na wczesne reagowanie na sytuacje które mogą prowadzić do potencjalnych konfliktów.

1.2.4 Współpraca pomiędzy stronami Projektu PPP

Kluczowa dla prawidłowej realizacji Umowy o PPP jest wzajemna współpraca pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, pomimo odmiennych zadań i interesów stron. Dla udanej współpracy istotna jest oczywiście transparentność i komunikacja, które zostały opisane powyżej, jednak poza tymi aspektami, strony Umowy o PPP powinny szczególną uwagę zwracać na docelowy punkt ich współdziałania.

Głównym celem Podmiotu Publicznego w ramach Projektu PPP jest zapewnienie określonych usług, podczas gdy Partner Prywatny jest odpowiedzialny za prawidłową realizację tych usług dla Użytkowników, w zamian za określone wynagrodzenie. Pomimo, że motywacje stron są odmienne, to jednak prawidłowa realizacja Projektu PPP i wypełnienie celów obu stron jest niemożliwe bez wzajemnej współpracy. Tylko poprzez harmonijne działanie, w tym poszanowanie zdarzających się rozbieżności interesów stron Umowy o PPP, można skutecznie realizować cele wspólnego

przedsięwzięcia, minimalizując ryzyko konfliktów i zapewniając efektywność Projektu PPP.

Współpraca pomiędzy stronami Umowy o PPP powinna opierać się na opisanej powyżej prawidłowej komunikacji i transparentności, a także być oparta o właściwe rozwiązania przewidziane w Umowie o PPP.

Dobre Praktyki



Rekomenduje się opracowanie odpowiednich kanałów umożliwiających stałą współpracę stron, w postaci wzajemnych Zespołów Projektowych, roboczych i realizacyjnych, które na bieżąco będą rozwiązywać powstałe problemy przy realizacji Umowy o PPP.

Strony powinny przy realizacji Projektu PPP zachować również odpowiednią równowagę. Powinno się unikać sytuacji, w których jedna ze stron ma charakter dominujący i próbuje narzucać swoje zdanie drugiej stronie i zastępować takie rozwiązania mechanizmami pozwalającymi na wspólne opracowywanie rozwiązań danych problemów, które rozwiązywane na wczesnym etapie nie ewoluują w bardziej konfliktowe formy.

Przy realizacji Projektu PPP każda ze stron powinna wziąć na siebie odpowiedzialność prawidłowej jego realizacji i dążyć do wypracowywania wspólnych rozwiązań, umożliwiających realizację Projektu PPP w jak najwyższym standardzie.

Podział odpowiedzialności za realizację Projektu PPP, z wzajemnym rozłożeniem ciężaru decyzyjnego, w oparciu o wypracowane modele współpracy, pozwala na zwiększenie poziomu utożsamiania się z danym projektem, co pozwala niwelować ryzyko powstania bezowocnych sporów między stronami Umowy o PPP.

Przykłady

W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym modernizacji oświetlenia miejskiego Podmiot Publiczny i Partner Prywatny napotkali problem związany z niedostatecznym doświetleniem niektórych ulic, co wywołało skargi mieszkańców. Miasto uznało, że Partner Prywatny nie spełnia wymagań, podczas gdy Partner Prywatny twierdził, że działa zgodnie z umową. Zamiast eskalować konflikt, strony skorzystały z mechanizmu współpracy przewidzianego w umowie i powołały zespół roboczy, który przeanalizował sytuację. Wspólna analiza wykazała konieczność korekty rozmieszczenia lamp, co Partner Prywatny zgodził się zrealizować, a Miasto uwzględniło w rozliczeniach. Dzięki otwartej komunikacji i współpracy uniknięto sporów, a projekt został ulepszony zgodnie z interesem obu stron i mieszkańców.

1.2.5 Odpowiednie zarządzanie ryzykiem sporów przez Zespół Projektowy, Doradców oraz Niezależnego Inżyniera**Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom I–IV**

Tom I: Część II Punkt 2.1 – Działania przygotowawcze po stronie Podmiotu Publicznego

Tom III: Część II Punkt 1.13 – Niezależny Inżynier

Tom III: Część II Punkt 6 – Procedura rozwiązywania sporów

Tom IV: Część II Punkt 1 – Narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.3.2 – Rozwiązywanie sporów

Tom IV: Część II Punkt 1.8 – Monitorowanie aspektów finansowych Projektu PPP

Zarządzanie sporami w Projekcie PPP nie powinno być utożsamiane wyłącznie z rozwiązywaniem konfliktów przy użyciu sformalizowanych mechanizmów – takich jak

mediacja, arbitraż czy postępowanie sądowe. Kluczowe znaczenie ma bieżące rozpoznawanie potencjalnych źródeł rozbieżności, monitorowanie ryzyk kontraktowych i wykonawczych, identyfikacja sygnałów napięć oraz podejmowanie działań, które ograniczają ich wpływ na relację między stronami i na harmonogram realizacji Przedsięwzięcia. Im wcześniej spór zostanie zidentyfikowany, sklasyfikowany i odpowiednio zarządzony, tym większa szansa na jego zażegnanie bez eskalacji i negatywnych konsekwencji dla Projektu PPP. Brak reakcji w tym zakresie skutkuje zazwyczaj narastaniem problemu, utrwaleniem sprzecznych stanowisk stron, utratą zaufania oraz powstaniem realnego ryzyka destabilizacji Umowy o PPP.

Spory w Projektach PPP rzadko mają jednoznaczną i pojedynczą przyczynę – znacznie częściej wynikają ze splotu czynników, obejmujących kwestie techniczne, organizacyjne, finansowe i komunikacyjne.

Schemat 14 – Najczęstsze przyczyny sporów w budownictwie w Polsce

Zgodnie z raportami branżowymi dotyczącymi najczęstszych przyczyn sporów w budownictwie w Polsce⁴, częstymi przyczynami sporów w tego rodzaju przedsięwzięciach są:

- wzrost kosztów realizacji;
- brak podejmowania lub opóźnienie w podejmowaniu kluczowych decyzji;
- błędy lub niejasności w dokumentacji przetargowej i kontraktowej (tj. niejasne określenie specyfikacji przez zamawiającego);
- przekazanie przez zamawiającego niepełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia;

⁴ Źródło: <https://www.caservices.pl/raport-o-sporach-budowlanych-2024-perspektywa-2025/>

-
- o zmiany projektowe/wykonawcze narzucane przez zamawiającego lub wynikające z przypisanych mu ryzyk (np. odmiennych warunków gruntowych);
-
- o niewłaściwe przygotowywanie roszczeń.
-

Jednocześnie, jak wynika z raportów branżowych⁵, podstawową przyczyną, dla której spory nie są rozstrzygane na etapie realizacji umowy jest obawa przed odpowiedzialnością za podjęte decyzje.

Co najmniej czterema (4) ze wskazanych powyżej przyczyn powstawania sporów – oznaczone pogrubioną czcionką – można przy tym aktywnie zarządzać (lub co najmniej podejmować w ich zakresie działania mitygacyjne) już na wczesnym etapie w trakcie realizacji Umowy o PPP. Działania te mogą obejmować regularny przegląd i ocenę ryzyk, ocenę wykonalności założeń projektowych inwestycji (ang. *constructability reviews*) czy też bieżący przegląd specyfikacji i samej Umowy o PPP pod kątem ich adekwatności do aktualnych wyzwań realizacyjnych.

Doświadczenia międzynarodowe, w tym wytyczne European PPP Expertise Centre (EPEC)⁶ czy rekomendacje Banku Światowego⁷, jednoznacznie wskazują również, że dla skutecznego zarządzania sporami w Projektach PPP niezbędne jest odpowiednie przygotowanie instytucjonalne i operacyjne obu stron. Projekt PPP powinien być realizowany przez Zespół Projektowy wyposażony nie tylko w wiedzę prawną, techniczną i finansową, ale także w kompetencje negocjacyjne, decyzyjne i zarządcze. Kluczowa jest tutaj zatem rola Zespołów Projektowych oraz Doradców, którzy dzięki bieżącemu zaangażowaniu mogą wspierać proces podejmowania decyzji oraz ograniczać ryzyko eskalacji sporów. Szczególnie istotna jest również obecność Niezależnego Inżyniera, który – przy zachowaniu niezależności i koncentracji na interesie całego Przedsięwzięcia – może pełnić funkcję mediacyjną i

⁵ Źródło: <https://www.caservices.pl/raport-o-sporach-budowlanych-2024-perspektywa-2025/>

⁶ Źródło: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/default/files/2024-08/EPEC_Guide%20to%20Guidance_EN.pdf

⁷ Źródło: <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/tools>

ekspercką w rozstrzyganiu rozbieżności technicznych czy kontraktowych już na etapie ich pojawienia się.

Dobre Praktyki



Bieżące wyzwania realizacyjne mogą być omawiane w trakcie regularnych narad koordynacyjnych (tygodniowych / miesięcznych) pomiędzy personelem Podmiotu Publicznego i personelem Partnera Prywatnego.

W złożonych strukturach projektowych, w których podmiotami zaangażowanymi przez Partnera Prywatnego są także w szczególności Generalny Wykonawca i/lub Operator, Partner Prywatny powinien analogiczne spotkania koordynacyjne prowadzić także z tymi podmiotami.

Znaczną część okoliczności, które mogą następnie stać się zarzewiem sporów daje się bowiem rozstrzygnąć w sposób „roboczy”, w toku ustaleń i narad pomiędzy personelem realizacyjnymi (lub branżowymi, w zależności od tego, jakiego obszaru realizacji dotyczy dany spór) obu stron Umowy o PPP.

Wymaga to jednak nie tylko odpowiedniego doboru kadr oraz stosownego poziomu zaufania pomiędzy zespołem Podmiotu Publicznego i zespołem Partnera Prywatnego, ale także wyposażenie tych osób w stosowne narzędzia.

Podstawowym narzędziem jest swoboda decyzyjna, najczęściej znajdująca potwierdzenie bezpośrednio w Umowie o PPP lub w udzielonym poszczególnym osobom pełnomocnictwie / upoważnieniu. Takie upoważnienie może być ograniczone rodzajowo, do podejmowania określonych czynności, np. z wyłączeniem prawa do dokonywania zmian w Umowie o PPP lub do zrzekania się jakichkolwiek roszczeń. Im szerszy będzie zakres uprawnień personelu stron Projektu PPP do podejmowania i wdrażania bieżących decyzji projektowych, tym większa szansa na bieżące podejmowanie efektywnych decyzji, mitygujących prawdopodobieństwo powstania sporu.

Uwaga

O ile po stronie Partnera Prywatnego udzielenie takich upoważnień jest zazwyczaj kwestią wewnętrżnej organizacji, o tyle po stronie Podmiotu Publicznego sytuacja może być bardziej skomplikowana – z uwagi na wymogi wynikające przepisów prawach, w tym m. in. Ustawy o Finansach Publicznych, wieloetapowe procesy decyzyjne oraz konieczność dokumentowania racjonalności i legalności działań. Nie oznacza to jednak, że skuteczne zarządzanie sporem nie jest możliwe – przeciwnie, przy odpowiednim wsparciu Doradców oraz wypracowanych procedurach zarządczych, również po stronie Podmiotu Publicznego możliwe jest szybkie i efektywne reagowanie na pojawiające się problemy.

Ponadto, wczesne zaangażowanie zewnętrznych Doradców lub Zespołu Doradców w Przedsięwzięcie oraz bieżące korzystanie z ich doradztwa może być szczególnie istotnym narzędziem zapobiegającym powstawaniu sporów, zwłaszcza w przypadku asymetrii wiedzy i doświadczenia (technicznego, technologicznego, komercyjnego, itd.) pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym.

Podobnie istotną rolę może pełnić Niezależny Inżynier, wspierający Podmiot Publiczny na Etapie Inwestycyjnym, przy założeniu, że Niezależny Inżynier kieruje się przede wszystkim dobrem Przedsięwzięcia, nie zaś wyłącznie dobrem Podmiotu Publicznego, jako strony, który w wielu wypadkach zatrudnia Niezależnego Inżyniera i opłaca jego wynagrodzenie.

Jak zostało już to szerzej opisane w Punkt 1.13 Wytycznych Tom III - Niezależny Inżynier (nazwa nie jest zdefiniowana w przepisach prawa; używa się również określeń "inżynier kontraktu", "niezależny doradca") to podmiot działający na rzecz Projektu PPP, podejmujący działania związane zarówno z bieżącym, rzetelnym administrowaniem Umową o PPP, jak i z zapobieganiem sporom, łagodzeniem ich na wczesnym etapie, a także rozstrzyganiem spraw, w których wymiana sprzecznych stanowisk stron nie doprowadziła do konsensusu. W tym zakresie istotne jest zapewnienie, że Niezależny Inżynier nie ma konfliktu interesu przy wykonywaniu swoich zadań na rzecz Przedsięwzięcia, a także że w całym okresie Umowy o PPP będzie dysponował niezbędnym personelem, który będzie realizował zadania

wskazane w umowie oraz zapewni dyspozycyjność danego personelu. Ze względu na długoterminowy charakter Umowy o PPP należy zapewnić elastyczność w zakresie możliwości zastępowania ekspertów.

W niektórych przypadkach rozstrzygnięcie Niezależnego Inżyniera może modyfikować prawa i obowiązki stron, skutkujące niekiedy (ale nie zawsze) koniecznością zmiany Umowy o PPP. Przy wykonywaniu ww. funkcji Niezależny Inżynier powinien działać w sposób bezstronny, w oparciu o profesjonalną wiedzę, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy. Niezależny Inżynier powinien funkcjonować w sposób ciągły w Okresie Budowy, natomiast w Okresie Utrzymania mógłby być powoływany w przypadkach tego wymagających (*ad hoc*), z reguły dotyczyć to będzie kwestii w zakresie technicznym. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć koszty związane z funkcjonowaniem Niezależnego Inżyniera, przy jednoczesnym zachowaniu korzyści wynikających z tej instytucji.

Dobre Praktyki



Efektywne, bieżące rozwiązywanie kwestii spornych przez personel realizacyjny Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego wymaga:

- wprowadzenia do Umowy o PPP regularnych spotkań roboczych i koordynacyjnych (np. miesięcznych),
- uwzględnienia w ramach agendy tych spotkań bieżących wyzwań realizacyjnych oraz ryzyk, które już się zmaterializowały lub mogą się zmaterializować – pomocne w tym zakresie jest np. prowadzenie rejestru ryzyk przez Partnera Prywatnego, który może być wspólnie omawiany przez strony na spotkaniach,
- stworzenia matrycy komunikacyjnej, w ramach której osoby odpowiedzialne po stronie Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego za określone obszary realizacji posiadają swojego odpowiednika "po drugiej stronie", a także bezpośredni kontakt do tej osoby w bieżących sprawach dotyczących ich wspólnego obszaru,

Dobre Praktyki



- udzielenia personelowi realizacyjnemu stosownych upoważnień / pełnomocnictw do bieżącego rozstrzygania kwestii spornych i czynienia bieżących ustaleń,
- wprowadzenia umownej procedury / ścieżki:
 - notyfikacji zidentyfikowanych ryzyk, które już wystąpiły, lub mogą wystąpić (tzw. procedura wczesnego ostrzegania (ang. *early warning*), wraz z określeniem terminów, w których powinna nastąpić notyfikacja,
 - eskalacji ryzyk i problemów ze szczebla realizacyjnego na wyższe poziomy decyzyjności, z uwzględnieniem pozostałych interesariuszy Projektu PPP (Generalnego Wykonawcy, Podwykonawców, Instytucji Finansujących, itd.),
- wprowadzenie postanowień umownych umożliwiających bieżącą weryfikację nie tylko ryzyk projektu, ale także adekwatności rozwiązań umownych, w tym Dokumentacji Postępowania lub Dokumentacji Projektowej, w stosunku do aktualnych wyzwań realizacyjnych,
- umożliwienie stronom korzystania z zewnętrznych Doradców i ekspertów.

Uwaga

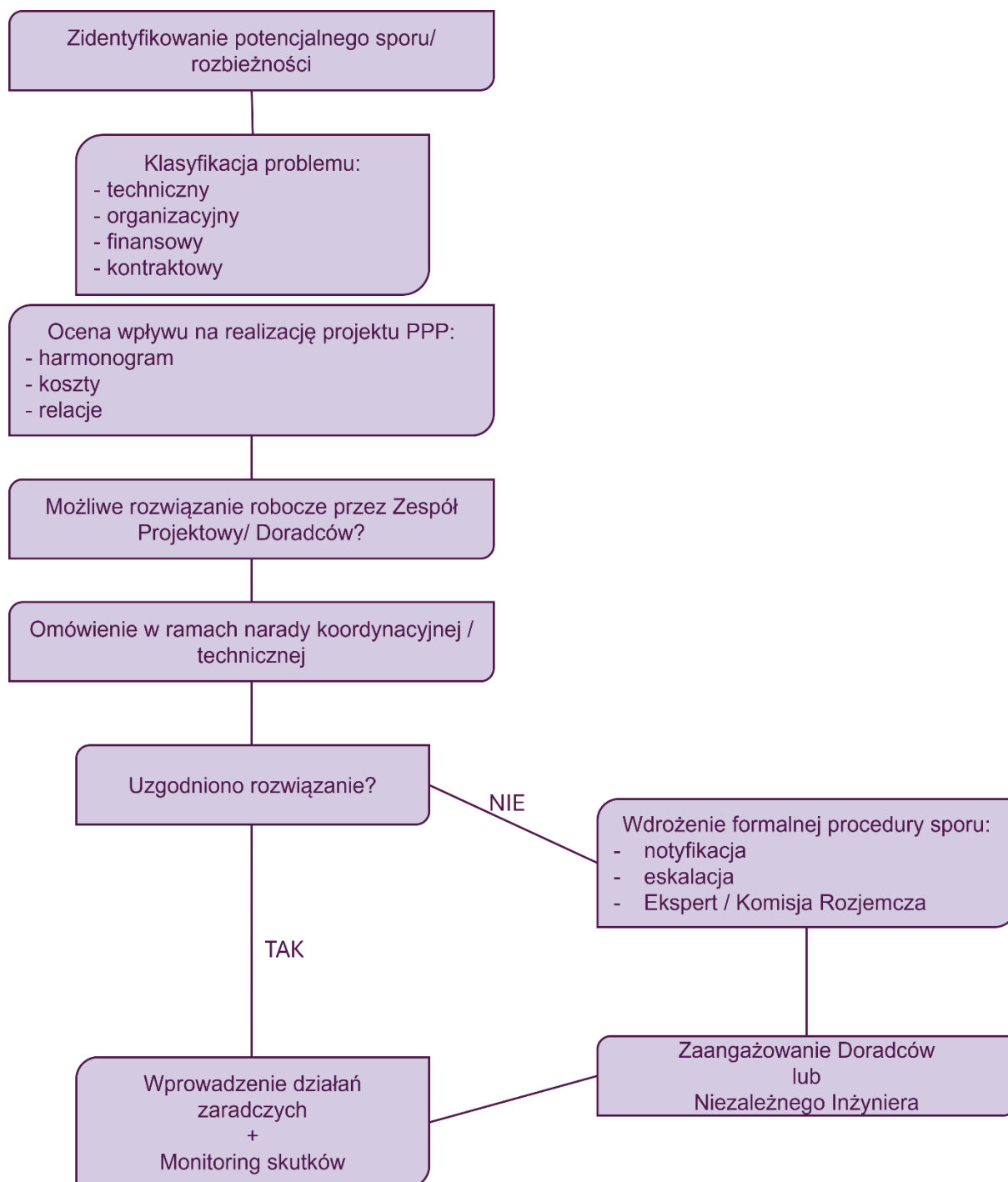


Często spotykanym w praktyce sposobem zarządzania sporami przez Zamawiających, również w Projektach PPP, jest wprowadzanie umownych terminów zawitych na zgłaszanie roszczeń oraz zewnętrznych ryzyk, gdzie bezskuteczny upływ tego terminu powoduje wygaśnięcie roszczenia lub utratę możliwości powoływania się na dane ryzyko (zdarzenie) w przyszłości. Jakkolwiek wprowadzanie takich terminów może być motywujące dla stron umowy, w tym w szczególności dla Partnera Prywatnego, to sam termin powinien być dobrany w sposób realny, możliwy do dochowania, a skutek jego niedochowania – wyraźnie zastrzeżony (skutku wygaśnięcia uprawnienia nie można bowiem domniemywać). Z dużą dozą

Uwaga

ostrożności należy podchodzić do rozwiązań, w których Partner Prywatny powinien notyfikować roszczenie w określonym terminie od momentu, w którym "powinien dowiedzieć się" o tym, że takie roszczenie może mu przysługiwać. W praktyce bowiem skutki zdarzeń zewnętrznych lub działań Podmiotu Publicznego mogą ujawniać się po upływie czasu i nie być możliwe do oceny w momencie zaistnienia samego zdarzenia szkodzącego. Zresztą, takie rozwiązanie – jeśli nie zostanie poddane negocjacjom – może zostać uznane za jednostronnie narzucone Partnerowi Prywatnemu, a w konsekwencji – nieskuteczne. W takiej sytuacji spór dotyczy kwestii czysto formalnych, a nie merytorycznych, które w wielu przypadkach są kluczowe dla dalszej, niezakłóconej realizacji Projektu PPP.

Schemat 15 - Zarządzanie ryzykiem sporów przez Zespół Projektowy, Doradców oraz Niezależnego Inżyniera



Zarządzanie sporami to zatem nie tyle reakcja na problem, ile narzędzie zapobiegania jego negatywnym skutkom – zarówno dla równowagi ekonomicznej

Przedsięwzięcia, jak i dla relacji między stronami czy interesów społeczności lokalnej. Właściwie prowadzona polityka zarządzania rozbieżnościami jest elementem szerszej strategii Zarządzania Umową o PPP i powinna funkcjonować jako codzienna praktyka operacyjna, a nie incydentalne działanie w sytuacjach kryzysowych. Dopiero gdy narzędzia te zawiodą, uzasadnione staje się sięgnięcie po sformalizowane mechanizmy rozwiązywania sporów, które zostaną omówione w Rozdziale 2 Wytycznych Tom V.

Rozdział 2

Polubowne metody rozwiązywania sporów

Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom I–IV

Tom III: Część II Punkt 6 – Procedura rozwiązywania sporów

Tom IV: Część II Punkt 1.3.2 – Rozwiązywanie sporów

Realizacja inwestycji w oparciu o modele PPP opiera się na długoterminowej współpracy sektora publicznego i prywatnego. Dlatego kluczowe jest, aby już od Etapu Przygotowawczego, a w szczególności na etapie negocjacji i podpisywania Umowy o PPP, wypracować jasne procedury rozwiązywania sporów dotyczących Przedsięwzięcia. Odpowiednio dobrane mechanizmy do realiów realizowanego Projektu PPP pozwalają na uniknięcie długotrwałych postępowań sądowych albo arbitrażowych oraz wiążących się z nimi dodatkowych kosztów dla stron Umowy o PPP. Stwarza to okazję dla stron do szybszego i tańszego rozwiązania konfliktu, a w efekcie ma pozytywny wpływ na możliwość kontynuowania Umowy o PPP, zwłaszcza na Etapie Operacyjnym.

Przykłady

W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym budowy miejskiego centrum sportowo-rekreacyjnego, podczas negocjacji Umowy o PPP Podmiot Publiczny ograniczył się do ogólnej klauzuli sądowej, nie przewidując szczegółowych mechanizmów rozwiązywania sporów. W trakcie Etapu Inwestycyjnego doszło do poważnych rozbieżności w interpretacji zapisów dotyczących odpowiedzialności za ryzyka gruntowe. Partner Prywatny domagał się dodatkowego wynagrodzenia za konieczne prace wzmacniające, a Podmiot Publiczny odrzucał te roszczenia. Brak ustalonych procedur mediacji lub decyzji eksperta uniemożliwił szybkie rozwiązanie sporu, przez co strony zostały zmuszone do skierowania sprawy do sądu powszechnego. Długotrwały proces i rosnące napięcia doprowadziły do opóźnień realizacyjnych i pogorszenia relacji między partnerami, co mogło zostać uniknięte, gdyby umowa przewidywała sprawny mechanizm bieżącego rozstrzygania sporów.

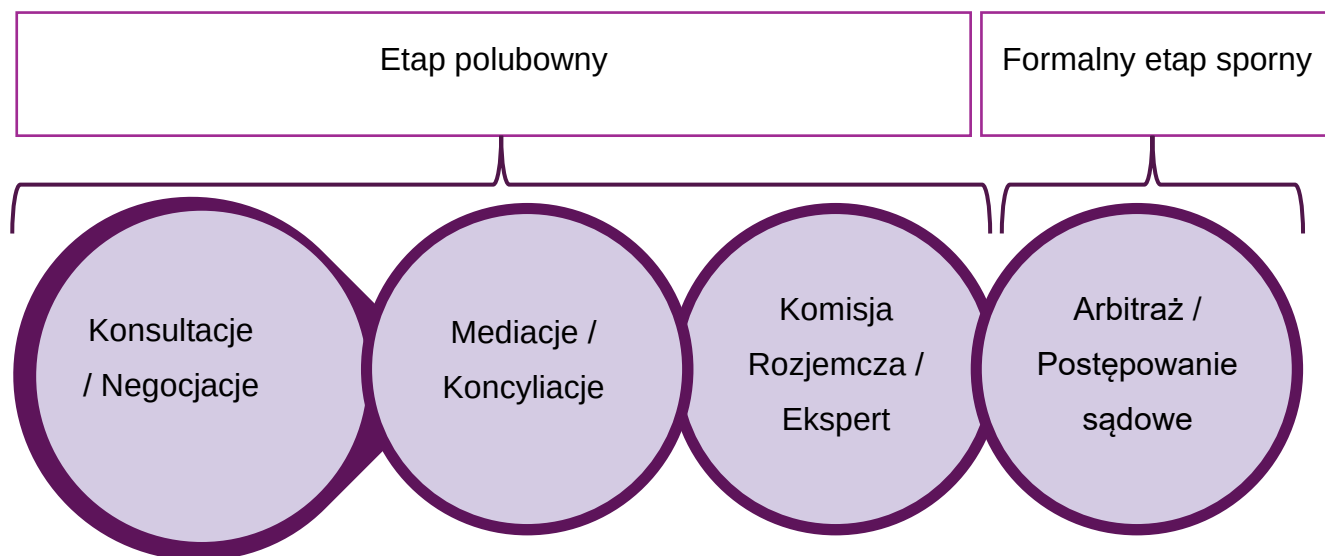
2.1 Wielopoziomowe klauzule rozwiązywania sporów

Zastosowanie wielopoziomowych klauzul rozwiązywania sporów, w oparciu o poprzedzenie postępowania sądowego albo arbitrażowego etapem polubownym, pozwala w maksymalny sposób wykorzystać wypracowane dotychczas wzajemne relacje Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego, co znacznie zwiększa szanse na szybkie rozwiązanie zaistniałego sporu. Pozwala to nie tylko zachować dobre relacje między stronami Umowy o PPP, ale również zapewnić dalszą współpracę w ramach Projektu PPP i ograniczyć ryzyko ponoszenia nadmiernych kosztów w związku z konfliktem.

W przypadku Projektów PPP rekomendowanym rozwiązaniem jest stosowanie wielopoziomowych klauzul rozwiązywania sporów. Klauzule te na początkowych etapach sytuacji konfliktowej opierają się na wykorzystaniu polubownych metod rozwiązywania sporów, takich jak przede wszystkim konsultacje lub negocjacje, mediacje, koncyliacje, Komisja Rozjemcza lub rozstrzygnięcie przez eksperta. W kolejnych etapach, w przypadku braku osiągnięcia porozumienia przez strony Umowy o PPP, klauzule te wskazują dopiero na rozwiązania *stricte* sporne w postaci postępowania sądowego albo arbitrażowego.

Praktyka wskazuje, że w Umowach o PPP najpowszechniej obecnie stosowaną procedurą rozwiązywania sporów jest trzystopniowa lub czterostopniowa procedura obejmująca konsultacje lub negocjacje, mediacje lub koncyliacje, etap ekspercki (tj. Komisje Rozjemcze lub eksperta), a finalnie formalne postępowanie sporne (w sądzie powszechnym albo arbitrażowym).

Schemat 16 - Wielopoziomowa procedura rozwiązywania sporów



Należy pamiętać, że strony Umowy o PPP dowolnie mogą ukształtować procedurę rozwiązywania sporów, w tym w szczególności strony nie muszą ograniczać się do wyboru tylko jednej metody polubownego rozwiązania sporów, która będzie poprzedzać formalny etap sporny w sądzie albo arbitrażu. Co więcej, rekomendowane jest ukształtowanie wielu poziomów rozwiązywania sporów, w taki sposób aby, gdy to tylko możliwe, uniknąć osiągnięcia ostatniego etapu, jakim jest arbitraż albo postępowanie sądowe, które są najbardziej długotrwałymi, konfliktowymi i kosztownymi metodami rozwiązania sporów.

Rekomendowane jest uwzględnienie w ramach procedury rozwiązywania sporów fazy konsultacji / negocjacji lub mediacji / koncyliacji (przy czym nie ma przeciwwskazań do zawarcia obu tych etapów), etapu poddania rozstrzygnięcia sporu podmiotowi trzeciemu, a więc Komisji Rozjemczej lub ekspertowi, a dopiero jako ostateczny etap (gdy już nie da się go uniknąć) uregulowanie kwestii procedowania sporu w arbitrażu albo w ramach postępowania sądowego.

Uwaga



Takie łączenie metod rozwiązywania konfliktów może prowadzić do niejasności, a nawet bezskuteczności lub nieważności klauzuli rozstrzygania sporów, a także do licznych problemów praktycznych dotyczących, w szczególności, zależności pomiędzy poszczególnymi szczeblami procedury rozstrzygania sporów oraz (nie)wiążącego charakteru poszczególnych rozstrzygnięć.

Dlatego też istotne jest, by w przypadku opracowywania wielostopniowej klauzuli rozstrzygania sporów precyzyjnie określić terminy dotyczące każdego stopnia, a także zależności pomiędzy stopniami (sekwencja, charakter obligatoryjny/fakultatywny) oraz zapadłymi w ich skutek rozstrzygnięciami (wiążące / wiążące tymczasowo / niewiążące / ostateczne).

W przypadku wątpliwości, warto zweryfikować, czy instytucje mediacyjne / arbitrażowe, z których wsparcia strony Umowy o PPP chcą skorzystać, nie publikują na swoich stronach modelowych klauzul umownych.

Schemat 17 - Wskazówki w zakresie wielopoziomowych klauzul rozwiązywania sporów

Wskazówki
Procedura rozwiązywania sporów powinna zostać określona kompleksowo i wielopoziomowo w Umowie o PPP.
Należy dążyć do maksymalnego wykorzystania możliwości polubownego rozwiązania sporu (konsultacji, negocjacji, mediacji, koncyliacji, Komisji Rozjemczej, rozstrzygnięcia przez eksperta).
Należy pamiętać, by określić ramy czasowe dla poszczególnych etapów prób polubownego rozwiązywania sporów (np. 1 miesiąc dla negocjacji, 3 miesiące dla mediacji lub koncyliacji, 3 miesiące dla Komisji Rozjemczej/eksperta).
Arbitraż lub postępowanie sądowe powinny być zawsze traktowane jako ostateczne rozwiązanie.

2.2 Konsultacje lub negocjacje

Faza konsultacji lub negocjacji powinna stanowić pierwszy poziom procedury rozwiązywania sporów w Umowie o PPP, kiedy spór jest ukształtowany na tyle, że nie może być on już wyłącznie przedmiotem ustaleń stron prowadzonych w toku bieżącej realizacji Umowy o PPP. Jej celem jest umożliwienie Podmiotowi Publicznemu i Partnerowi Prywatnemu znalezienia kompromisowego rozwiązania, które będzie akceptowalne dla obu stron Umowy o PPP i pozwoli na uniknięcie eskalacji konfliktu.

W ramach tego etapu przedstawiciele stron Umowy o PPP powinni podjąć rozmowy w określonym i krótkim terminie, który nie powoduje nadmiernej zwłoki w realizacji Projektu PPP. Rekomendowany czas trwania negocjacji / konsultacji wynosi maksymalnie dwa (2) – cztery (4) tygodnie, co pozwala na efektywne omówienie

problemu, ale jednocześnie zapobiega przedłużaniu procedury rozwiązywania sporów.

Ważnym elementem fazy konsultacji lub negocjacji jest przejrzysta komunikacja oraz gotowość do współpracy. Strony powinny działać w dobrej wierze, dążąc do znalezienia rozwiązania, które nie narusza interesów żadnej ze stron i nie prowadzi do eskalacji konfliktu, a także jest zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Ustawą PZP i Ustawą o Finansach Publicznych. W celu zwiększenia skuteczności tego etapu, zaleca się, aby w negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele stron posiadający realne umocowanie do podejmowania decyzji oraz znajomość przedmiotu sporu, w zależności od tego czy ma on charakter techniczny, ekonomiczny lub prawny.

W przypadku, w którym decyzji nie można podjąć na szczeblu "roboczym" – przykładowo, gdy dany problem jest kluczowy dla realizacji Projektu PPP i wymaga eskalacji na wyższy szczebel decyzyjny lub wykracza poza zakres upoważnień personelu Podmiotu Publicznego lub Partnera Prywatnego – Umowa o PPP może przewidywać jego eskalację na poziom Komitetu Sterującego lub Wspólnego Komitetu Sterującego.

Komitet Sterujący może być narzędziem podejmowania decyzji w ramach struktury Podmiotu Publicznego lub Partnera Prywatnego (tj. być ciałem "wewnętrznym"). Może być jednak także ciałem wspólnym (Wspólny Komitet Sterujący), złożonym z przedstawicieli Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego, spotykającym się, przykładowo, raz na dwa (2) / trzy (3) miesiące lub w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby) i rozstrzygającym te kwestie sporne, których rozstrzygnięcie przez personel realizacyjny okazało się niemożliwe, niepraktyczne lub niepożądane.

Dobre Praktyki



W przypadku wprowadzenia instytucji Wspólnego Komitetu Sterującego, Umowa o PPP powinna określać m. in. (i) sposób wyboru oraz skład Wspólnego Komitetu Sterującego, (ii) zakres jego kompetencji oraz (iii) sposób podejmowania decyzji. Z perspektywy praktycznej, decyzje Wspólnego Komitetu Sterującego nie mają jako

Dobre Praktyki

takie wiążącej mocy prawnej i powinny zostać przeniesione na poziom umowny w formie stosownej zmiany umowy (aneksu), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Mniej sformalizowaną alternatywą dla Komitetu Sterującego mogą być konsultacje lub negocjacje zarządów Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego. W takim przypadku kwestie sporne, których nie udało się rozwiązać na poziomie roboczym są kierowane przez każdy z zespołów do zarządu danej strony. Następnie, zarządy stron odbywają spotkanie negocjacyjne, którego efektem może być rozstrzygnięcie sporu.

W pozytywnym scenariuszu, etap ten powinien zakończyć się osiągnięciem porozumienia, który w niektórych przypadkach może ze względów formalnych wymagać zawarcia aneksu do Umowy o PPP, który musi spełniać wymogi opisane Podrozdziale 2.7.2 Wytycznych Tom V. Jeżeli w wyznaczonym terminie Podmiotowi Publicznemu i Partnerowi Prywatnemu nie uda się osiągnąć porozumienia, etap konsultacyjny/negocjacyjny powinien zostać formalnie zakończony, a strony powinny przejść do kolejnego etapu procedury rozwiązywania sporów – w zależności od konstrukcji klauzuli rozwiązywania sporów - w który zaangażowany jest już podmiot trzeci, np. mediacji lub koncyliacji, rozstrzygnięcia przez Komisję Rozjemczą lub eksperta, a w ostateczności arbitrażu lub postępowania sądowego.

Przykłady

W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym zaprojektowania, budowy i eksploatacji zintegrowanego węzła komunikacyjnego, po rozpoczęciu prac wykonawczych Partner Prywatny wystąpił z wnioskiem o wydłużenie harmonogramu realizacji inwestycji, powołując się na opóźnienia w przekazaniu przez Podmiot Publiczny niektórych decyzji administracyjnych. Podmiot Publiczny

Przykłady



zakwestionował zasadność roszczenia, twierdząc, że Partner Prywatny mógł rozpocząć część prac niezależnie od tych decyzji.

Zgodnie z zapisami Umowy o PPP, strony rozpoczęły etap konsultacyjno-negocjacyjny, który miał trwać maksymalnie cztery (4) tygodnie. Do rozmów wyznaczono przedstawicieli z odpowiednimi kompetencjami decyzyjnymi i wiedzą techniczno-prawną. W toku spotkań obie strony przedstawiły swoje stanowiska i dokumenty potwierdzające przebieg zdarzeń. Dzięki przejrzystej komunikacji i nastawieniu na kompromis, wypracowano rozwiązanie polegające na częściowym wydłużeniu harmonogramu z jednoczesnym zobowiązaniem Partnera Prywatnego do intensyfikacji prac w innych obszarach projektu. Porozumienie zostało sformalizowane aneksem do Umowy o PPP.

Przykładowe Postanowienia



W przypadku sporu dotyczącego treści, wykonania, obowiązywania, ważności lub skuteczności Umowy o PPP, przed wszczęciem postępowania, o którym mowa w [] Umowy, Strony zobowiązują się do rozwiązania go w drodze negocjacji.

Strona inicjująca negocjacje składa drugiej Stronie pisemny wniosek określający przedmiot sporu.

Negocjacje rozpoczynają się w terminie [] Dni Roboczych od doręczenia wniosku.

Strony prowadzą negocjacje w dobrej wierze, wyznaczając przedstawicieli posiadających uprawnienia do podejmowania decyzji.

Informacje wymieniane w negocjacjach mają charakter poufny.

W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w terminie [] Dni Roboczych od rozpoczęcia negocjacji ani nie zgodzą się wspólnie na przedłużenie tego terminu,

Przykładowe Postanowienia



każda ze Stron może zażądać przekazania sporu do mediacji prowadzonej przez [] / rozstrzygnięcia przez Komisję Rozjemczą.

2.3 Mediacje *ad hoc* lub instytucjonalne

Mediacja jest jedną z najczęściej stosowanych metod polubownego rozwiązywania sporów w skomplikowanych projektach gospodarczych, a w szczególności z obszaru infrastruktury czy energetyki, pozwalającą uniknąć długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych albo arbitrażowych. Mediacja to dobrowolny proces, w którym strony, przy pomocy mediatora, prowadzą negocjacje mające na celu osiągnięcie satysfakcjonującego dla obu stron kompromisu. Mediacja może być stosowana zarówno w ramach postanowień Umowy o PPP, jak i w trybie przewidzianym w Ustawie PZP (art. 591 Ustawy PZP).

Schemat 18 - Istotne cechy mediacji

Dobrowolność

- Strony same decydują czy chcą wziąć udział w mediacji.
- Mediacja może być wszczęta na podstawie Umowy o PPP, przepisów prawa lub decyzji sądu.
- Strony mogą w każdej chwili zrezygnować z mediacji, jeśli uznają, że nie prowadzi ona do oczekiwanego rezultatu.

Neutralność i bezstronność mediatora

- Spotkania indywidualne i wspólne – mediator zapoznaje się z argumentami stron.
- Negocjacje – mediator pomaga w wypracowaniu kompromisu.
- Ustalenie warunków ugody – strony mogą uzgodnić warunki rozwiązania sporu.
- Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – nie wydaje wiążącego rozstrzygnięcia. Jego rolą jest facylitacja rozmów, pomoc w wypracowaniu rozwiązania i redukcja napięć między stronami.
- Mediator nie narzuca rozstrzygnięcia – strony mają pełną kontrolę nad treścią ugody.

Poufność

- Wszystkie informacje ujawnione w trakcie mediacji są objęte tajemnicą.
- Żadne oświadczenia złożone w trakcie mediacji nie mogą być później wykorzystywane w postępowaniu sądowym (art. 183⁴ § 3 KPC).
- Strony mogą w mediacji testować różne propozycje rozwiązań bez obawy, że zostaną one użyte przeciwko nim w późniejszym sporze.

Elastyczność procesu

- Mediacja nie jest ograniczona sztywnymi procedurami.
- Strony mogą samodzielnie określić sposób prowadzenia mediacji, liczbę spotkań, zakres rozmów.
- Mediacja może być prowadzona stacjonarnie, zdalnie lub w formie hybrydowej.
- Podpisanie ugody – ugoda może zostać zatwierdzona przez sąd i mieć moc ugody sądowej.
- Brak porozumienia – jeśli strony go nie osiągną porozumienia, spór przechodzi do Komisji Rozjemczej, arbitrażu lub sądu.

W przypadku zawarcia w Umowie o PPP postanowień dotyczących mediacji, jako jednego z etapów ścieżki rozwiązywania sporów, strony powinny określać m. in.:

- zasady inicjowania mediacji i wybór mediatora,
- harmonogram postępowania mediacyjnego,
- skutki mediacji, w tym możliwość zmiany Umowy o PPP zgodnie z przepisami prawa.

Przykładowe Postanowienia



1. *W przypadku powstania sporu pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym w związku z realizacją niniejszej Umowy, strony w pierwszej kolejności podejmą próbę polubownego rozwiązania sporu w drodze bezpośrednich konsultacji lub negocjacji, prowadzonych w dobrej wierze.*
2. *Jeżeli w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron nie dojdzie do zawarcia porozumienia kończącego spór, każda ze stron może zainicjować postępowanie mediacyjne przed [].*
3. *Mediacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem mediacyjnym obowiązującym w wybranym ośrodku mediacyjnym, chyba że strony postanowią inaczej.*
4. *Wybór mediatora dokonywany będzie zgodnie z procedurą obowiązującą w danym ośrodku, przy czym strony mogą wspólnie uzgodnić konkretnego mediatora z listy mediatorów danego ośrodka. W przypadku braku uzgodnienia w terminie 7 (siedmiu) dni od wszczęcia mediacji, mediator zostanie wyznaczony przez ośrodek.*
5. *Postępowanie mediacyjne powinno zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni od dnia wyznaczenia mediatora, z*

Przykładowe Postanowienia



możliwością jednorazowego przedłużenia tego terminu o kolejne 30 (trzydzieści) dni za zgodą obu stron.

- 6. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, a w przypadku osiągnięcia porozumienia – ugodę mediacyjną zawierającą uzgodnione postanowienia.*
- 7. Uгода mediacyjna, o której mowa w ust. 6, może – w zależności od jej przedmiotu – stanowić podstawę do zmiany Umowy PPP, o ile nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego.*

Mediacja umowna może być prowadzona w trybie *ad hoc* albo przy wsparciu instytucji mediacyjnych. Listy stałych mediatorów i ośrodków mediacji prowadzone są przez sądy okręgowe.

Przykładowe Postanowienia



- 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią (dalej „Spory”/”Spór”), strony przedłożą do rozwiązania w drodze mediacji w Centrum Mediacji Lewiatan zgodnie z postanowieniami Regulaminu Centrum Mediacji Lewiatan obowiązującymi w dniu rozpoczęcia mediacji. Każda ze stron może jednostronnie przerwać mediację.*
- 2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany zgodnie z tym Regulaminem w terminie 45 dni od złożenia wniosku o rozpoczęcie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, taki spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie, zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym tego Sądu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania.⁸*

⁸ Źródło: <https://lewiatan.org/centrum-mediacji-lewiatan/>

W poniższej tabeli wskazano przykładowe i najpopularniejsze ośrodki mediacji w Polsce wraz z opłatami za przeprowadzenie mediacji w ramach tych ośrodków. Strony Umowy o PPP, decydujące się na rozwiązanie sporu w drodze mediacji będą musiały ponieść koszt tych mediacji, na który składają się: (i) opłaty administracyjne (wstępne, rejestracyjne), (ii) opłaty mediacyjne (wynagrodzenie mediatora) oraz (iii) wydatki (np. koszty dojazdów mediatora lub wynajmu sali na przeprowadzenie mediacji).

Schemat 19 - Przykładowe opłaty mediacyjne

Ośrodek Mediacji	Opłaty
Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej RP ⁹	5.000 zł powiększone o należny podatek VAT.
Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) ¹⁰	Opłata rejestracyjna – 500 zł Opłata mediacyjna: 1.000 zł od każdej ze stron – dla spraw o wartości poniżej 50.000 zł; 1.500 zł od każdej ze stron – dla spraw o wartości pomiędzy 50.000 zł a 100.000 zł; 2.000 zł od każdej ze stron – dla spraw o wartości pomiędzy 100.000 zł a 200.000 zł; 3.000 zł od każdej ze stron – dla spraw o wartości pomiędzy 200.000 zł a 500.000 zł; opłata ustalana indywidualnie – dla spraw o wartości powyżej 500.000 zł.

⁹ Źródło: <https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/mediacja3>

¹⁰ Źródło: <https://sakig.pl/mediacje/centrum-mediacji-przy-kig>

Ośrodek Mediacji	Opłaty
Centrum Mediacji Lewiatan ¹¹	Opłata wstępna – 200 zł Opłata mediacyjna – 5% wartości przedmiotu sporu od każdej ze Stron, nie mniej niż po 400 zł od każdej ze Stron oraz nie więcej niż po 2400 zł od każdej ze Stron (w sprawach majątkowych). W sprawach o wartości powyżej 500.000 zł wynagrodzenie mediatora ustalane jest indywidualnie.

Standardowy przebieg postępowania mediacyjnego kształtuje się w następujący sposób:

¹¹ Źródło: <https://lewiatan.org/centrum-mediacji-lewiatan/>

Schemat 20 - Przebieg postępowania mediacyjnego

**Wszczęcie
mediacji**

- Złożenie wniosku o mediację – jedna ze stron składa wniosek do mediatora lub instytucji mediacyjnej albo sądu.
- Wybór mediatora – strony wybierają mediatora samodzielnie lub zgodnie z postanowieniami umownymi lub regulaminem instytucji mediacyjnej.
- Ustalenie harmonogramu i miejsca mediacji – mediator kontaktuje się ze stronami i organizuje spotkania.

**Przebieg
mediacji**

- Spotkania indywidualne i wspólne – mediator zapoznaje się z argumentami stron.
- Negocjacje – mediator pomaga w wypracowaniu kompromisu.
- Ustalenie warunków ugody – strony mogą uzgodnić warunki rozwiązania sporu.

**Zakończenie
mediacji**

- Podpisanie ugody – ugoda może zostać zatwierdzona przez sąd i mieć moc ugody sądowej.
- Brak porozumienia – jeśli strony nie osiągną porozumienia, spór przechodzi do Komisji Rozjemczej lub rozstrzygnięcia eksperta, albo bezpośrednio arbitrażu lub sądu.

Ugoda zawarta w mediacji może stanowić podstawę do modyfikacji warunków Umowy o PPP zgodnie z przepisami prawa, co zostało opisane w Podrozdziale 2.7.2 Wytycznych Tom V.

Przykłady

W ramach hipotetycznego Projektu PPP miasto podpisało 30–letnią umowę na modernizację oczyszczalni ścieków, obejmującą projektowanie, budowę i eksploatację obiektu przez Partnera Prywatnego. W trakcie realizacji projektu pojawiły się opóźnienia wynikające z trudnych warunków geologicznych oraz konieczność dostosowania technologii oczyszczania do nowych norm środowiskowych. Partner Prywatny domagał się istotnego zwiększenia wynagrodzenia oraz wydłużenia terminu realizacji, co spotkało się z oporem ze strony Podmiotu Publicznego, obawiającego się wzrostu kosztów Projektu PPP.

Aby uniknąć długotrwałego procesu sądowego, strony zdecydowały się na mediację *ad hoc*, w której uczestniczył niezależny mediator z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji projektów komunalnych. Po kilku miesiącach mediacji osiągnięto ugodę, na mocy której okres Etapu Inwestycyjnego został wydłużony o kilka miesięcy, a koszty dodatkowe podzielono pomiędzy strony. Dodatkowo, jako element kompromisu, Partner Prywatny uzyskał możliwość przedłużenia eksploatacji oczyszczalni o dodatkowy okres.

Dzięki mediacji udało się uniknąć eskalacji konfliktu, a Etap Inwestycyjny został ukończony bez dalszych opóźnień. Sprawne rozwiązanie sporu, przy udziale mediatora znającego specyfikę tego rodzaju inwestycji, pozwoliło na utrzymanie partnerskich relacji i potwierdziło, że mediacja może być skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu konfliktów w Projektach PPP.

2.4 Koncyliacje

Alternatywą dla postępowania mediacyjnego może być koncyliacja. Rozwiązanie to jest w szczególności rekomendowane w przypadku sporów, w których wypracowanie wspólnego stanowiska przez strony Umowy o PPP może być niemożliwe, a pomocnym dla stron okazać się może przedstawienie propozycji rozwiązania sporu przez osobę trzecią, posiadającą fachową wiedzę w danym temacie (np. ze znajomością specyfiki sektora, w którym realizowany jest Projekt PPP).

Koncyliacja to próba polubownego rozwiązania sporu, w której niezależny podmiot trzeci – koncyliator – pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia. Koncyliator, podobnie jak mediator koordynuje przebieg koncyliacji, jednak w przeciwieństwie do mediatora, po zbadaniu okoliczności danej sprawy, przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu. Strony nie są związane zaproponowaną przez koncyliatora propozycją i to od nich wyłącznie zależy, czy zaakceptują zaproponowane rozwiązanie. Koncyliacja ma więc umożliwić stronom osiągnięcie porozumienia, w sytuacji braku możliwości samodzielnego wypracowania przez strony rozwiązania danego sporu, a zadaniem koncyliatora jest wypracowanie takiej propozycji, by była ona akceptowalna dla obu stron. Strony mogą samodzielnie dokonać wyboru koncyliatora lub przeprowadzić koncyliację w ramach wyspecjalizowanej instytucji.

Dobre Praktyki



Funkcję koncyliatora powinna pełnić osoba posiadająca fachową wiedzę wymaganą dla rozpoznania sporu poddanego pod rozstrzygnięcie w ramach postępowania koncylacyjnego, ponieważ jej głównym zadaniem jest przedstawienie propozycji rozstrzygnięcia sporu przez strony. Koncyliatorem nie musi być osoba o wykształceniu prawniczym, ale może być to osoba posiadająca wiedzę inżynierską lub ekonomiczną.

Dobre Praktyki



Rekomendowaną dla Podmiotów Publicznych instytucją dla prowadzenia koncyliacji jest Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej RP¹².

Strony mogą zamieścić w Umowie o PPP klauzulę koncyliacyjną, w której wskażą, że spory będą rozstrzygane w ramach koncyliacji przed wskazaną instytucją. W przypadku braku umieszczenia w Umowie o PPP klauzuli koncyliacyjnej, strony mogą również zawrzeć odrębną umowę o koncyliację, na mocy której poddadzą zaistniały spór pod rozstrzygnięcie w drodze koncyliacji.

Przykładowe Postanowienia

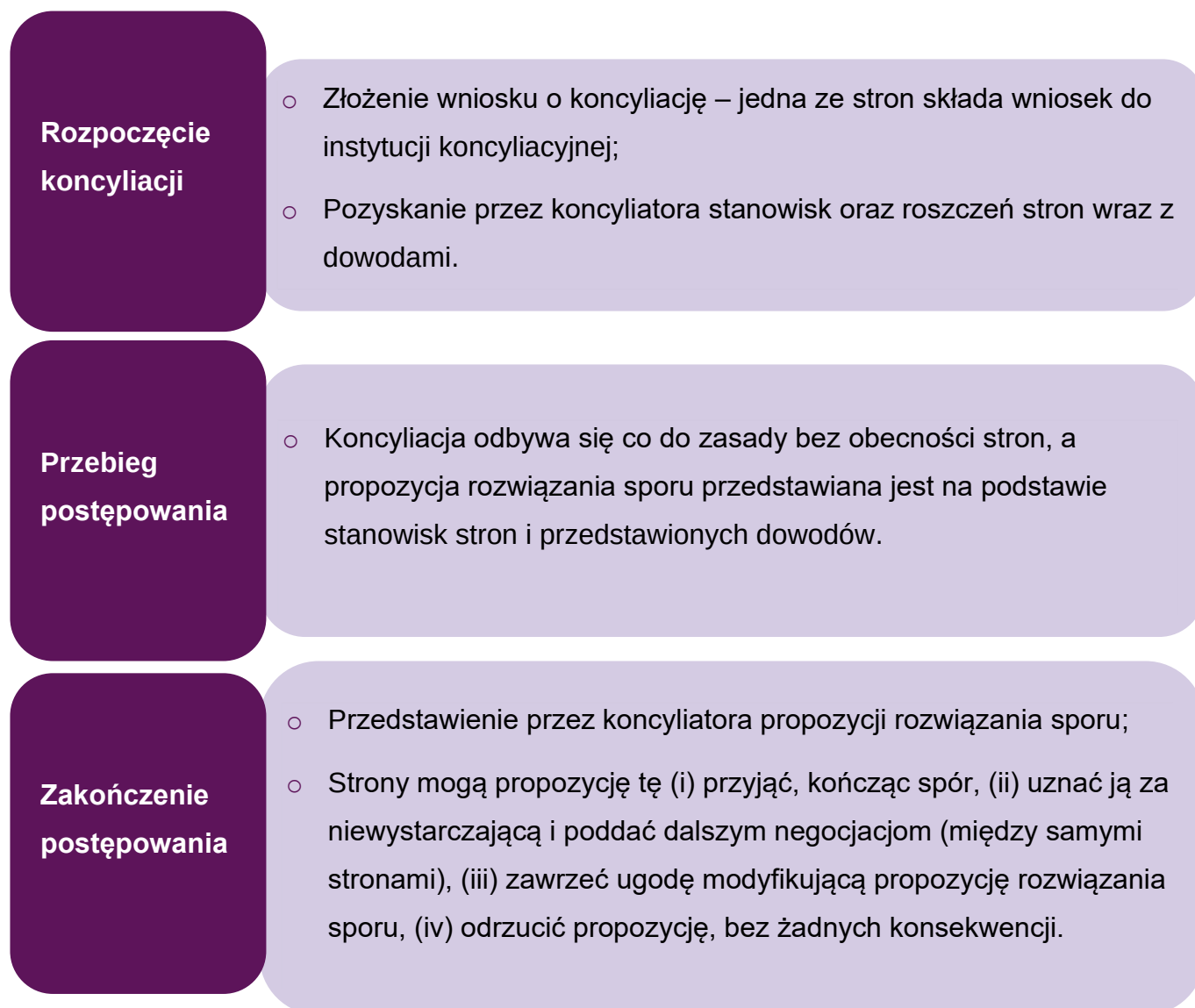


W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu¹³.

¹² Źródło: <https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/koncyliacja3>

¹³ Źródło: <https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/koncyliacja3>

Schemat 21 - Przebieg koncyliacji prowadzonych przed Sądem Polubownym przy PGRP



Wprowadzenie rozwiązań objętych propozycją rozwiązania sporu przedstawioną przez koncyliatora wymaga zawarcia przez strony ugody, ewentualnie odpowiedniego aneksu do Umowy o PPP na warunkach opisane w Podrozdziale 2.7.2 Wytycznych Tom V.

Schemat 22 – Zalety koncyliacji

Zalety koncyliacji:

- Zachowanie poufności;
- Uzyskanie szybkiego rozstrzygnięcia sporu;
- Udział podmiotu trzeciego posiadającego fachową wiedzę;
- Uzyskanie propozycji rozwiązania sporu od neutralnego koncyliatora;
- Możliwość zachowania dobrych stosunków między stronami;
- Stosunkowo niski koszt.

Opłata za postępowanie koncyliacyjne przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 5.000 zł powiększone o należny podatek VAT. Jeżeli w trakcie postępowania odbyły się więcej niż trzy (3) posiedzenia, opłata ulega zwiększeniu o 1.000 zł za każde kolejne posiedzenie. Co do zasady strony pokrywają koszty koncyliacji w częściach równych.

Przykłady



W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym zaprojektowania, budowy oraz eksploatacji wielofunkcyjnego obiektu kultury, w trakcie Etapu Operacyjnego pojawił się spór dotyczący zakresu obowiązków utrzymaniowych Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny uznał, że niektóre prace modernizacyjne powinny zostać sfinansowane przez Partnera Prywatnego w ramach opłaty za dostępność, natomiast Partner Prywatny twierdził, że są to prace wykraczające poza standardowe utrzymanie i wymagają dodatkowego wynagrodzenia. Wcześniejsze negocjacje oraz mediacja nie doprowadziły do rozwiązania, ponieważ strony nie były w stanie dojść do wspólnej interpretacji zapisów umowy, a każda ze stron obstawała przy swoim stanowisku.

Zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP, strony postanowiły skorzystać z koncyliacji przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrany koncyliator, posiadający doświadczenie w

Przykłady

projektach infrastrukturalnych i znajomość specyfiki PPP, przeanalizował dokumentację, wysłuchał argumentów obu stron oraz przeprowadził techniczno-ekonomiczną ocenę sporu. Po zakończeniu analizy przedstawił stronom pisemną propozycję rozwiązania, w której zaproponował modyfikację zakresu obowiązków Partnera Prywatnego w zamian za modyfikację pierwotnych ustaleń dotyczących Opłaty za Dostępność, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekonomicznej projektu.

Choć propozycja koncyliatora nie była wiążąca, strony uznały ją za rozsądną i zaakceptowały warunki ugody. Na tej podstawie zawarto aneks do Umowy o PPP, wprowadzający uzgodnione zmiany. Dzięki zaangażowaniu koncyliatora o odpowiednich kwalifikacjach oraz przejrzystości procedury koncyliacyjnej, udało się uniknąć dalszej eskalacji sporu, zachować ciągłość świadczenia usług dla społeczności lokalnej i zabezpieczyć trwałość współpracy między stronami.

2.5 Komisja Rozjemcza

W przypadku nieskutecznych negocjacji / konsultacji lub mediacji / koncyliacji, jako kolejną fazę procedury rozwiązywania sporów, strony Umowy o PPP mogą przyjąć skierowanie sporu do Komisji Rozjemczej. Na tym etapie strony przekazują rozstrzygnięcie zaistniałego sporu do Komisji Rozjemczej, która pełni funkcję niezależnego, profesjonalnego podmiotu oceniającego przedmiot sporu i wydającego decyzję. Komisja dokonuje analizy okoliczności konfliktu oraz przedstawia rozstrzygnięcie, które ma na celu szybkie i obiektywne rozwiązanie sporu.

Uwaga

Warunki Kontraktowe FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów) przewidują ustanowienie Komisji Rozjemczej w sporach (ang. *Dispute Adjudication Board – DAB*) jako mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a

Uwaga

wykonawcą. Komisja Rozjemcza działa na podstawie umocowania stron w ramach alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR).

W Polsce praktyka ta jest coraz częściej stosowana w dużych projektach infrastrukturalnych, choć zdarzają się przypadki ignorowania decyzji Komisji Rozjemczej przez nieusatysfakcjonowaną rozstrzygnięciem stronę, co podkreśla potrzebę precyzyjnego określenia skutków prawnych jej decyzji w umowie.

Komisja Rozjemcza może być stałym organem, powołanym raz na cały okres realizacji Umowy o PPP (lub jej danego etapu, np. Etapu Inwestycyjnego), w sposób określony przez strony Umowy o PPP (najczęściej każda strona powołuje jednego (1) członka Komisji Rozjemczej, a dwaj (2) tak wybrani członkowie wybierają przewodniczącego Komisji, ewentualnie Komisja jest czteroosobowa, a każda strona powołuje dwóch (2) członków). Strony ponoszą koszty Komisji Rozjemczej w określonej proporcji, a sama Komisja Rozjemcza spotyka się regularnie (np. raz w miesiącu) albo na żądanie stron i rozpatruje spory przedstawione jej do rozstrzygnięcia przez strony Umowy o PPP, wydając stosowne decyzje lub wytyczne.

W zależności od ustaleń stron, Komisja Rozjemcza może zatem rozstrzygać spory przed skierowaniem ich do mediacji / koncyliacji albo być kolejną fazą procedury rozwiązywania sporów. W tym zakresie ustanowienie stałej Komisji Rozjemczej jeszcze w szczególności rekomendowane przy Projektach PPP skomplikowanych pod kątem technicznym lub technologicznym w których na etapie ich realizacji, konieczne może być bieżące rozstrzygnięcie jednostkowych zagadnień wymagających oceny przez niezależny podmiot nie będący stroną Umowy o PPP.

W praktyce można spotkać się także ze stałymi Komisjami Rozjemczymi, których skład jest zmienny, tj. strony powiadamiają się wzajemnie o składzie Komisji Rozjemczej na kilka dni przed jej posiedzeniem. Rozwiązanie to, jakkolwiek uelastyczniające instytucję Komisji Rozjemczej, ma jednak tę istotną wadę, że pozbawia stałą Komisję Rozjemczą jej przewagi nad Komisją Rozjemczą *ad hoc* w postaci znajomości realiów projektu.

Alternatywnie, Umowa o PPP może przewidywać powołanie Komisji Rozjemczej *ad hoc*, do rozstrzygnięcia konkretnego sporu, jednak w takim przypadku istnienie Komisji Rozjemczej należy rozpatrywać przede wszystkim jako element wielostopniowej klauzuli rozwiązywania sporów niż jako mechanizm zarządzania sporami w toku realizacji przedsięwzięcia. Taka formuła Komisji Rozjemczej nie posiada również bieżącej wiedzy dotyczącej realizacji sporu, a jej funkcja ograniczona jest do rozstrzygnięcia konkretnego sporu, co powoduje, że – w przeciwieństwie do stałej Komisji Rozjemczej – nie mityguje ona ryzyka powstawania sporów (ang. *dispute avoidance*).

Jeżeli decyzja Komisji Rozjemczej nie jest satysfakcjonująca dla którejkolwiek ze stron, może ona żądać przejścia do formalnego postępowania zgodnie z kolejnym etapem procedury rozwiązywania sporów określonym w Umowie PPP.

Dobre Praktyki



Ważnym aspektem jest określenie w Umowie o PPP odpowiednich wymagań dotyczących kwalifikacji osób powoływanych do Komisji Rozjemczych. W przypadku Komisji Rozjemczych powinny one uwzględniać zarówno ich doświadczenie zawodowe, jak i dostosowanie kompetencji do specyfiki danego sporu. Warunki te powinny pozostawać elastyczne, tak aby możliwe było ich dopasowanie do charakteru rozstrzyganej sprawy – na przykład, jeśli przedmiotem sporu jest interpretacja zapisów Umowy o PPP w kontekście prawnym, kluczowe znaczenie będą miały wysokie kwalifikacje prawnicze eksperta. Analogicznie, w przypadku kwestii technicznych, ekspert powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie.

Schemat 23 – Zalety Komisji Rozjemczej

Zalety Komisji Rozjemczej w Projekcie PPP

- Umożliwia bieżące rozstrzyganie sporów w toku trwania projektu, zwłaszcza tak długotrwałego jak Projekt PPP.
- Motywuje strony Umowy o PPP do samodzielnego rozstrzygania sporów, a w konsekwencji zmniejsza prawdopodobieństwo ich powstawania i eskalacji.
- Pozwala optymalizować koszty realizacji Przedsięwzięcia oraz zmniejszać opóźnienia (brak przenoszenia sporów i ich konsekwencji na dalszy etap realizacji Projektu PPP).
- Zwiększa pewność stron w zakresie ich wzajemnych praw i obowiązków.

Przykładowe Postanowienia



1. *Strony uzgadniają powołanie Komisji Rozjemczej (dalej: "Komisja") w celu rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych.*
2. *Komisja składa się z trzech (3) członków: każda ze Stron wyznacza po jednym (1) członku, a dwaj (2) wyznaczeni członkowie wspólnie wybierają trzeciego członka, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji. Wszyscy członkowie Komisji muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji Projektów PPP.*
3. *Komisja jest powoływana na cały okres obowiązywania Umowy o PPP i spotyka się regularnie, nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na wniosek którejkolwiek ze Stron w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od zgłoszenia takiego wniosku.*

Przykładowe Postanowienia

4. *Procedura rozstrzygania sporu przez Komisję obejmuje:*
 - a) *Przedstawienie Komisji przez Strony pisemnych stanowisk dotyczących przedmiotu sporu wraz z niezbędną dokumentacją;*
 - b) *Przeprowadzenie przez Komisję analizy przedstawionych materiałów oraz, w razie potrzeby, wysłuchanie Stron;*
 - c) *Wydanie przez Komisję pisemnej decyzji w terminie czternastu (14) dni od daty zakończenia analizy materiałów i wysłuchania Stron.*
5. *Decyzje Komisji są wiążące dla Stron, chyba że w terminie siedmiu (7) dni od doręczenia decyzji Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia złoży pisemne oświadczenie o zamiarze skierowania sprawy do sądu arbitrażowego zgodnie z art. [] Umowy.*
6. *Koszty funkcjonowania Komisji są ponoszone przez Strony w równych częściach, chyba że Komisja postanowi inaczej w swojej decyzji*
7. *Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania bezstronności oraz poufności w zakresie informacji uzyskanych w trakcie postępowania."*

Dobre Praktyki

Komisje Rozjemcze (ang. *Dispute Adjudication Boards*) mogą funkcjonować nie tylko jako mechanizm umowny tworzony *ad hoc* lub na czas trwania projektu, ale również w formie instytucjonalnej, korzystając z zaplecza organizacyjnego wyspecjalizowanych instytucji międzynarodowych. Organizacje takie jak Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) czy Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) oferują nie tylko regulaminy postępowania przed Komisją Rozjemczą, ale także cały aparat administracyjny, ekspercki i proceduralny, który wspiera powołanie, funkcjonowanie i

Dobre Praktyki



rozstrzyganie przez Komisję Rozjemczą w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami.

Przykładowo, CIArb udostępnia kompleksowe *Dispute Board Rules*, które regulują m. in. sposób powoływania członków Komisji, przebieg postępowania, zasady bezstronności oraz formę i skutki wydawanych decyzji. Regulamin ten jest oparty na zasadach rzetelnego procesu, elastyczności proceduralnej i wysokich standardach etycznych członków Komisji¹⁴.

Z kolei ICC oferuje instytucjonalne wsparcie dla różnych form Komisji Rozjemczych, w tym Dispute Adjudication Boards (DAB) oraz Dispute Review Boards (DRB), które mogą być stosowane zarówno w Formule Tradycyjnej, jak i PPP. ICC udostępnia również standardowe klauzule umowne, które mogą być bezpośrednio implementowane do Umowy o PPP, zapewniając stronom dostęp do sprawdzonej struktury zarządzania sporami¹⁵.

Włączenie instytucjonalnego mechanizmu Komisji Rozjemczej do Umowy o PPP może zatem stanowić atrakcyjną alternatywę dla Komisji Rozjemczej tworzonej wyłącznie przez strony, zapewniając transparentność, stabilność procedury oraz dostęp do niezależnych ekspertów posiadających wysokie kwalifikacje i wsparcie organizacyjne.

Aby mechanizm Komisji Rozjemczych był skuteczny i nie prowadził do blokowania ścieżki rozwiązywania sporów, Umowa o PPP powinna przewidywać odpowiednie klauzule na wypadek braku porozumienia stron co do składu Komisji Rozjemczej. W takich przypadkach konieczne jest zapewnienie możliwości przejścia do kolejnego etapu procedury rozwiązywania sporów – np. skierowania sprawy do mediacji,

¹⁴ Źródło: <https://www.ciarb.org/media/31vfc1x0/ciarb-dispute-board-rules-practice-standards-committee-august-2014.pdf>

¹⁵ Źródło: <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/dispute-boards/>

arbitrażu lub sądu – tak aby uniknąć impasu decyzyjnego i zapewnić ciągłość procedury.

Analogicznie, jeżeli strony postanowią, że decyzje Komisji Rozjemczej mają charakter niewiążący (rekomendacyjny), albo też – mimo ich wiążącego charakteru – któraś ze stron zakwestionuje wydane rozstrzygnięcie, procedura powinna przewidywać przejście do kolejnego, formalnego etapu sporu, jakim będzie postępowanie arbitrażowe lub sądowe. W takiej sytuacji, mimo wysiłków Komisji Rozjemczej, dalsze rozstrzygnięcie sporu będzie wymagało zaangażowania podmiotu zewnętrznego, wyposażonego w kompetencje do wydania ostatecznego, wykonalnego rozstrzygnięcia.

Dlatego skuteczność Komisji Rozjemczej w praktyce zależy nie tylko od jej kompetencji i organizacji, ale również od tego, jak precyzyjnie i przewidująco Umowa o PPP reguluje możliwe warianty rozwoju procedury sporu oraz reakcje na brak współpracy jednej ze stron. W ten sposób mechanizm Komisji Rozjemczej nie tylko służy rozwiązywaniu konfliktów, lecz również chroni projekt przed paraliżem decyzyjnym i zabezpiecza jego płynność realizacyjną.

Przykłady



W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym budowy nowoczesnego centrum przesiadkowego w mieście Y, w trakcie realizacji prac okazało się, że warunki gruntowe na części terenu inwestycji odbiegają od wstępnych analiz geologicznych. Partner Prywatny uznał, że konieczne jest wykonanie dodatkowych robót wzmacniających podłoże, co wiązało się z dodatkowymi kosztami i potencjalnym opóźnieniem harmonogramu. Podmiot Publiczny, obawiając się przekroczenia budżetu i opóźnień, początkowo nie chciał uznać zasadności tych robót, argumentując, że analiza geologiczna była elementem ryzyka po stronie Partnera Prywatnego.

Zamiast odraczać decyzję i ryzykować eskalację konfliktu, strony skorzystały z mechanizmu bieżącego rozstrzygania sporów przewidzianego w umowie. Sprawa została przekazana do Komisji Rozjemczej, która na podstawie ekspertyzy

Przykłady

niezależnego geotechnika wydała tymczasową decyzję pozwalającą na kontynuację robót z jednoczesnym wypracowaniem modelu podziału dodatkowych kosztów. Dzięki szybkiemu rozstrzygnięciu uniknięto sytuacji, w której konieczne byłoby wstrzymanie inwestycji, a następnie kosztowne przeprojektowanie już wykonanych elementów. Ostateczne rozliczenie kosztów zostało pozostawione do dalszych negocjacji, ale kluczowe było to, że projekt mógł być realizowany zgodnie z harmonogramem, co było w interesie zarówno Podmiotu Publicznego, jak i Partnera Prywatnego.

2.6 Mechanizmy decyzji eksperckich

Alternatywą dla Komisji Rozjemczej, jest ustanowienie przez strony Umowy o PPP stałego eksperta, który w toku realizacji Przedsięwzięcia rozstrzyga spory przedstawione mu przez strony. Ekspert może być także powoływany *ad hoc*, do rozstrzygnięcia konkretnego sporu, jednak – podobnie jak w przypadku Komisji Rozjemczej – takie rozwiązanie jest mniej efektywne (wybór eksperta po krystalizacji sporu zazwyczaj jest trudniejszy), a także nie ma ono funkcji minimalizacji ryzyka powstawania sporów (ang. *dispute avoidance*).

Podobnie jak w przypadku Komisji Rozjemczej, polskie prawo nie przewiduje narzędzi przymuszenia do wykonania decyzji eksperta na drodze przymusu państwowego (np. w drodze egzekucji). W praktyce zatem decyzja eksperta nigdy nie będzie trwale wiążąca. Jej naruszenie przez jedną ze stron Umowy o PPP spowoduje, że druga strona będzie musiała – w celu dochodzenia swoich praw – skierować sprawę na drogę postępowania sądowego albo arbitrażowego. Nawet jednak w przypadku, w którym decyzja eksperta jest wiążąca jedynie tymczasowo (lub w ogóle nie jest wiążąca i ma walor jedynie doradczy), a każda ze stron ma prawo zakwestionować ją w ramach postępowania sądowego albo arbitrażowego, decyzja eksperta ma istotny walor dla zabezpieczenia praw i obowiązków stron do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Może ona także stanowić istotną wskazówkę dla stron, co do możliwego rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu

sądowym albo arbitrażowym, a w konsekwencji zachęcać je do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych kontrowersji.

Procedura rozstrzygania sporów przez eksperta może mieć charakter quasi-instytucjonalny, tj. procedura ta może być administrowana przez zewnętrzną instytucję, np. arbitrażową. Taką usługę świadczy w szczególności Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) w Paryżu, która może wesprzeć strony w wyborze eksperta, a także przejąć na siebie administrowanie postępowaniem eksperckim, zgodnie z Regulaminem (ang. *ICC Rules for the Administration of Expert Proceedings*), za stosownymi opłatami¹⁶.

Uwaga

Kluczowym elementem skutecznego rozwiązywania sporów w ramach Umowy o PPP jest zagwarantowanie bezstronności i niezależności osób odpowiedzialnych za ich ewentualne rozstrzygnięcie. W związku z tym Umowa o PPP powinna przewidywać możliwość wyłączenia eksperta lub członka Komisji Rozjemczej, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego neutralności – na przykład w sytuacji, gdy osoba ta pozostaje w bliskich relacjach z którąkolwiek ze stron. Mechanizmy te powinny zapewniać, że każda decyzja wydawana w ramach procedury rozstrzygania sporów będzie oparta wyłącznie na obiektywnych przesłankach i rzetelnej analizie sprawy.

Metody rozwiązywania sporów w ramach etapu polubownego mają swoje cechy charakterystyczne, które wynikają ze stopnia ich sformalizowania oraz ich przebiegu, a także ich skuteczności w ramach obowiązującego prawa. Poniżej przedstawione zostały cechy poszczególnych metod polubownego rozwiązywania sporów.

Schemat 24 - Charakterystyczne cechy poszczególnych metod polubownego rozwiązywania sporów

¹⁶ Źródło: <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/experts/administration-of-experts-proceedings/rules-for-the-administration-of-expert-proceedings/>

Cecha	Negocjacje / konsultacje	Mediacje	Koncyliacje	Komisja Rozjemcza	Decyzje eksperckie
Uczestnicy	Strony	Strony i powołany przez strony mediator, który wpiera i koordynuje mediacje. Mediator może nie być ekspertem w danej dziedzinie, jego rola ogranicza się do koordynowania mediacji.	Strony i powołany przez strony koncyliator. Koncyliator koordynuje koncyliacje oraz przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu. Koncyliator powinien posiadać wiedzę fachową wymaganą dla rozpoznania danego sporu.	Strony i powołana przez strony Komisja Rozjemcza, w skład której wchodzi eksperci w danej dziedzinie.	Strony i powołany przez strony ekspert w danej dziedzinie.

Cecha	Negocjacje / konsultacje	Mediacje	Koncyliacje	Komisja Rozjemcza	Decyzje eksperckie
Czas	Czas zależy od postępu negocjacji i nastawienia stron. Negocjacje mogą się przedłużać, dlatego istotne jest aby w umowie określić czas ich trwania.	Czas zależy od postępu mediacji i nastawienia stron. Mediator może wspierać strony i usprawniać proces mediacji. Mediacje, podobnie jak negocjacje mogą się przedłużać, dlatego istotne jest aby w umowie określić czas ich trwania.	Czas zależy od postępu koncyliacji i nastawienia stron. Strony mogą określić czas trwania koncyliacji.	Strony muszą zazwyczaj powołać Komisję Rozjemczą, co wydłuża czas rozwiązania sporu. Istotne jest określenie w Umowie o PPP terminów na powołanie Komisji Rozjemczej. W Umowie o PPP należy również określić czas, w jakim komisja powinna wydać rozstrzygnięcie .	Strony muszą zazwyczaj powołać eksperta, co wydłuża czas rozwiązania sporu. Istotne jest określenie w Umowie o PPP terminów na powołanie eksperta. W Umowie o PPP należy również określić czas, w jakim ekspert powinien wydać rozstrzygnięcie .

Cecha	Negocjacje / konsultacje	Mediacje	Koncyliacje	Komisja Rozjemcza	Decyzje eksperckie
Skuteczność	Nie gwarantuje rozstrzygnięcia . Konieczne jest osiągnięcie porozumienia i akceptacji przez strony. Strony decydują o charakterze rozstrzygnięcia.	Nie gwarantuje rozstrzygnięcia . Konieczne jest osiągnięcie porozumienia i akceptacji przez strony. Strony decydują o charakterze rozstrzygnięcia.	Koncyliator przedstawia propozycję rozwiązania sporu, która musi zostać zaakceptowana przez strony. Konieczne jest osiągnięcie porozumienia przez strony. Strony decydują o charakterze rozstrzygnięcia .	Gwarantuje rozstrzygnięcie , w formie decyzji o materii sporu. Rozstrzygnięcie zasadniczo wiąże strony, ale może zostać kwestionowane w ramach postępowania sądowego/ arbitrażu.	Gwarantuje rozstrzygnięcie w formie decyzji o materii sporu. Rozstrzygnięcie zasadniczo wiąże strony, ale może zostać kwestionowane w ramach postępowania sądowego/ arbitrażu.
Koszt	Niski koszt	Niski koszt (obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie mediatora)	Niski koszt (obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie koncyliatora)	Średni koszt	Średni koszt

Inne	Negocjacje wymagają odpowiedniego o przygotowani a przez strony w zakresie wiedzy eksperckiej i zgromadzenia dowodów. Brak odpowiedniego o przygotowani a przez stronę może uniemożliwić osiągnięcie porozumienia. Pozwalają utrzymać „dobre relacje” przy dalszej realizacji projektu. Strony mają kontrolę nad rozstrzygnięciami Zachowana poufność.	Mediacje wymagają odpowiedniego przygotowania przez strony w zakresie wiedzy eksperckiej i zgromadzenia dowodów. Brak odpowiedniego przygotowania przez stronę może uniemożliwić osiągnięcie porozumienia. Pozwalają utrzymać „dobre relacje” przy dalszej realizacji projektu. Mediator często nie posiada wiedzy eksperckiej oraz nie przeprowadza analizy dowodów i stanowisk stron. Strony mają kontrolę nad rozstrzygnięciami.	Koncyliator przedstawia propozycję rozstrzygnięcia na podstawie zebranego stanowiska od stron. Strony przedstawiają merytoryczne stanowisko koncyliatorowi niezbędne do przedstawienia proponowanego o rozwiązania sporu. Strony mają kontrolę nad rozstrzygnięciami – mogą przyjąć lub odrzucić propozycję rozstrzygnięcia · Udział podmiotu trzeciego posiadającego fachową wiedzę. Zachowanie poufności.	Członkowie Komisji Rozjemczej powinni posiadać wiedzę ekspercką. Komisja Rozjemcza analizuje dowody i stanowisko stron. Strony nie mają kontroli nad rozstrzygnięciami, które jest wydawane przez Komisję Rozjemczą. Zachowana poufność.	Ekspert powinien posiadać wiedzę ekspercką. Ekspert analizuje dowody i stanowisko stron. Strony nie mają kontroli nad rozstrzygnięciami, której jest wydawane przez eksperta. Zachowana poufność.
------	--	---	--	---	--

Cecha	Negocjacje / konsultacje	Mediacje	Koncyliacje	Komisja Rozjemcza	Decyzje eksperckie
		Zachowana poufność.			

Schemat 25 - Podsumowanie opisów i rezultatów poszczególnych etapów rozwiązywania konfliktów

	Opis	Rezultat
Etap konsultacji bez udziału podmiotu trzeciego (konsultacje/ negocjacje)	Realizowany przy zaangażowaniu osób decyzyjnych po obu stronach Umowy PPP, w ramach którego strony próbują rozwiązać konflikt w drodze ugodowej. W ramach tego etapu strony nie korzystają z udziału żadnego podmiotu trzeciego.	Etap kończy się osiągnięciem porozumienia albo brakiem porozumienia w określonym w Umowie o PPP czasie i ewentualnym skierowaniem sporu na dalszy etap – etap konsultacji z udziałem podmiotu trzeciego.

	Opis	Rezultat
Etap konsultacji z udziałem podmiotu trzeciego (mediacje / koncyliacje)	Realizowany przy zaangażowaniu osób decyzyjnych po obu stronach Umowy PPP, w ramach którego strony próbują rozwiązać konflikt w drodze ugodowej. W ramach tego etapu strony korzystają z udziału podmiotu trzeciego w osobie mediatora lub koncyliatora.	Etap kończy się osiągnięciem porozumienia albo brakiem porozumienia w określonym w Umowie o PPP czasie i ewentualnym skierowaniem sporu na dalszy etap – etap ekspercki.
Etap ekspercki (Komisja Rozjemcza lub ekspert)	W przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony mogą oddać spór pod rozstrzygnięcie przez eksperta lub Komisję Rozjemczą.	W ramach tego etapu strony Umowy o PPP powinny uzyskać propozycję rozwiązania sporu, którą mogą zaakceptować albo odrzucić i skierować sprawę na etap postępowania formalnego.

	Opis	Rezultat
Etap formalnego postępowania spornego (postępowanie sądowe albo arbitrażowe)	W przypadku braku osiągnięcia porozumienia na etapie konsultacji lub etapie eksperckim, w zależności od tego jakie forum do rozstrzygnięcia sporów zostało przez strony ustalone w Umowie o PPP, strony mogą skierować spór pod rozstrzygnięcie w postępowaniu arbitrażowym albo postępowaniu przed sądem powszechnym.	Etap ten kończy się wydaniem wyroku, który – w przypadku sądu powszechnego – może zostać zaskarżony do sądu II instancji. Postępowanie arbitrażowe jest zasadniczo jednoinstancyjne, a stronom przysługują jedynie nadzwyczajne środki zaskarżenia do sądu powszechnego.

2.7 Rola ugody

Zawarcie ugody jest najczęściej ostatnią fazą ścieżki polubownego rozwiązywania sporów w Projektach PPP, która często przybiera formę aneksu do Umowy o PPP. W zależności od kontekstu i specyfiki sporu, ugoda może być stosowana na różnych etapach rozwiązywania sporu, tj. po pozytywnym zakończeniu jednego z etapów ścieżki rozwiązywania sporów od negocjacji / konsultacji, poprzez mediację / koncyliację, aż po decyzję Komisji Rozjemczej / eksperta. Umożliwia to zakończenie konfliktu bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego albo arbitrażowego, co w kontekście wieloletnich Projektów PPP ma szczególne znaczenie dla zachowania stabilnej współpracy między Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym. Niezależnie ugoda może być oczywiście również zawarta na etapie samego postępowania sądowego.

Schemat 26 – Rola ugody

Ugoda to dwustronne porozumienie, w którym strony dokonują wzajemnych ustępstw w celu zakończenia sporu. Może obejmować m. in.:

- Zmianę warunków finansowych Umowy o PPP, w tym płatności i harmonogramu rozliczeń;
- Dostosowanie zakresu prac do zmieniających się warunków gospodarczych;
- Rozstrzygnięcie kwestii jakości wykonanych usług i infrastruktury przez Partnera Prywatnego;
- Zmianę warunków eksploatacyjnych i zarządczych, np. dotyczących dostępności obiektu;
- Modyfikację zasad odpowiedzialności stron, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od nich;

Źródła Informacji



Zgodnie z danymi statystycznymi Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r.¹⁷ w ramach tego sądu odnotowano wpływ 583 wniosków o wszczęcie mediacji, 70 wniosków o wszczęcie koncyliacji i 10 wniosków o wszczęcie postępowania arbitrażowego. Jeszcze do 2017 r. ugody zawierane przez sektor publiczny należały do rzadkości i każda informacja o takiej ugodzie była gorąco dyskutowana przez rynek. Rosnący w ostatnich latach wpływ do Sądu Polubownego wniosków o przeprowadzenie postępowań polubownych dotyczących m. in. kwestii waloryzacji czy rozliczenia inwestycji, stanowi pokaźny wzrost w porównaniu z latami poprzednimi.

Podmioty publiczne stanowiły ok. 50% uczestników tych postępowań, a łączna wartość przedmiotu sporu wynosiła 6,6 mld zł. 55 % tych postępowań stanowiły postępowania sporne z obszaru Ustawy PZP.

Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ocenia skuteczność tych postępowań w liczbie zawieranych ugód na poziomie 86 % dla mediacji i koncyliacji umownych oraz 72% dla mediacji sądowych, a średni czas (mediana) trwania postępowania to 5 miesięcy.

Widoczny jest zatem pozytywny trend wzrostowy, a także coraz większa świadomość po stronie podmiotów publicznych o korzyściach płynących z zawierania ugód.

2.7.1 Istota ugody

Ugoda stanowi instytucję prawa cywilnego, określaną jako czynność następcza lub umowa następcza w odniesieniu do pierwotnego stosunku prawnego. W ugodzie regulowane są prawa lub obowiązki stron wynikające z innego stosunku prawnego,

¹⁷ Źródło: <https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/statystyki-sadu-polubownego-przy-prokuraturii-generalnej-rp-w-2024-r-efektywnosc-dajaca-satysfakcje>

których ponowne uregulowanie stało się konieczne w wyniku powstania między stronami umowy pierwotnej sporu lub rozbieżności w zakresie interpretacji pierwotnej umowy lub związane jest z nieprawidłowym jej wykonywaniem przez którąkolwiek ze stron.

Zawieranie ugód jest dopuszczalne w stosunkach cywilnoprawnych i co do zasady należy do nich stosować ogólne zasady dla zawierania umów (art. 353¹ KC). Należy pamiętać, że zawarta ugoda nie może być sprzeczna z ustawą (w tym w zakresie w szczególności ograniczeń w dokonywaniu zmian do umowy lub zawieraniu ugód wynikających z Ustawy o PPP, Ustawy PZP oraz Ustawy o Finansach Publicznych), zasadami współżycia społecznego oraz nie może prowadzić do obejścia prawa.

Ugoda stanowi dwustronną czynność prawną, na mocy której strony czynią wzajemne ustępstwa. Dla skutecznego zawarcia ugody nie jest wymagana forma szczególna, jednak ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać z umowy kreującej pierwotny stosunek – Umowy o PPP lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ugoda może swoim zakresem obejmować całą lub część pierwotnej umowy. W praktyce, w przypadku zawarcia między stronami Umowy o PPP ugody na etapie jej realizacji, będzie ona stanowić formę aneksu do pierwotnej umowy, zmieniającego ją w zakresie objętym porozumieniem stron wyrażonym w treści ugody.

Uwaga



Należy pamiętać, że jeżeli Umowa o PPP wprowadza szczególne warunki co do jej zmiany, takie jak formę w jakiej może być dokonana zmiana Umowy o PPP lub ograniczone przypadki w jakich taka zmiana może być dokonana, to ugoda może być skutecznie zawarta wyłącznie w przypadkach i formie określonej w Umowie o PPP.

W przypadku Umów o PPP, strony oprócz ograniczeń co do zmiany umowy przewidzianych w samej Umowie o PPP, powinny mieć również na uwadze ustawowe ograniczenia w zakresie możliwości zmiany Umowy o PPP, o których mowa w Podrozdziale 2.7.2.1 Wytycznych Tom V.

Uwaga

Zawarcie ugody przez Podmioty Publiczne w rządowych Projektach PPP może wymagać (a w niektórych przypadkach wymaga) uzyskania przez Podmiot Publiczny opinii Prokuratury Generalnej (art. 17 i 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuraturze Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej). Prokuratura Generalna opiniuje projekty umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych, których wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 50 000 000 zł.

Uzyskanie opinii Prokuratury Generalnej jest obowiązkowe w przypadku projektów umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa. W innych przypadkach podmioty mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii fakultatywnej.

Podmiot Publiczny składa wniosek o wydanie opinii prawnej do Prokuratury Generalnej. Wniosek ten musi być przedłożony nie później niż na 15 dni przed planowanym dokonaniem czynności prawnej. W uzgodnieniu z Prezesem Prokuratury Generalnej termin ten może być skrócony do 4 dni.

Opłaty za wydanie opinii prawnej przez Prokuratorę Generalną są ustalane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. Wysokość opłat może się różnić w zależności od rodzaju opinii oraz wartości przedmiotu czynności prawnej. Na przykład, opłata za opinię dotyczącą projektu umowy, ugody lub jednostronnej czynności prawnej, której wartość przekracza 50 000 000 zł, jest wyższa niż za opinie dotyczące mniejszych wartości.¹⁸

¹⁸ Źródło: <https://www.gov.pl/web/prokuratoria/opinie-prawne>

2.7.2 Kluczowe regulacje w zakresie ugód w Umowach PPP

Powiązane Sekcje Wytycznych PPP Tom I–IV



Tom I: Część I Punkt 1.1 – Podstawowe cechy modelu PPP

Tom I: Część I Punkt 2 – Otoczenie instytucjonalno-prawne Projektów PPP

Tom II: Punkt 2 – Podstawy prawne oraz tryby wyboru Partnera Prywatnego

Tom III: Część I Punkt 2.2 – Istotne warunki Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 2.6 – Zakres zastosowania Ustawy PZP do Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 5 – Przypadki zewnętrzne

Tom III: Część II Punkt 7 – Zmiany Umowy o PPP

Tom IV: Część I Punkt 4 – Role i odpowiedzialność stron Umowy o PPP w procesie Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.3.1 – Zmiany w Przedsięwzięciu

W polskim porządku prawnym zawieranie ugód przez Podmioty Publiczne podlega szczególnym ograniczeniom, wynikającym przede wszystkim z Ustawy PZP oraz Ustawy o Finansach Publicznych.

2.7.2.1 Ustawa PZP

Zgodnie z art. 7 ust. 3a Ustawy o PPP do przedsięwzięć realizowanych w formule PPP mają zastosowanie zasady dotyczące zakazu wprowadzania istotnych zmian do umowy określonych w Ustawie PZP. Stanowią one efekt przeprowadzenia sformalizowanego postępowania, w którym dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o określone warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert.

Uwaga

Umowy o PPP przewidują z reguły dość szeroki katalog możliwych zmian do Umowy o PPP. Jest to konieczne z uwagi na zapewnienie odpowiedniej elastyczności w Projekcie PPP i umożliwienie dostosowywania długoterminowej Umowy o PPP do zmieniających się okoliczności.

Ponieważ zawarcie umowy w Projektach PPP, które realizowane są w oparciu o zamówienia publiczne, wymaga przede wszystkim zgodności z Ustawą PZP, to w szczególności należy mieć na uwadze zgodność z przepisami dotyczącymi zmiany umowy. Art. 592 Ustawy PZP stanowi bowiem, że zawarcie umowy nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 Ustawy PZP, a zatem umowa nie może prowadzić do naruszenia przepisów określających zasady dopuszczalności dokonywania zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. art. 454 i 455 Ustawy PZP.

Uwaga

Strony są upoważnione do daleko posuniętej ingerencji w treść Umowy o PPP, w tym do dokonania zmian istotnych, o ile w ogłoszeniu o zamówieniu lub w innych dokumentach zamówienia przewidziany został odpowiedni mechanizm wprowadzania takich zmian. Mechanizm ten powinien przybrać postać skonkretyzowanych postanowień Umowy o PPP, z góry ustalających warunki, których spełnienie umożliwi zmianę postanowień umownych (tj. przesłanki zmiany Umowy o PPP), a także rodzaj (tj. istotna lub nieistotna) i zakres takich zmian (tj. skutki ich wprowadzenia, np. zmiana wynagrodzenia, zmiana terminów wynikających z Umowy o PPP). Granicą takiej ingerencji w pierwotną treść Umowy o PPP jest zakaz zmiany jej ogólnego charakteru (art. 455 ust. 1 pkt 1 lit. c) Ustawy PZP).

Uwaga

Należy mieć na uwadze, że rodzaj i zakres zmian może zostać określony w jednym postanowieniu umownym i nie musi być każdorazowo wskazywany przy konkretnej przesłance zmiany Umowy o PPP.

→ Nieistotne zmiany Umowy o PPP

Na gruncie Ustawy PZP obowiązuje ogólny zakaz wprowadzania do niej istotnych zmian, co wynika bezpośrednio z art. 454 ust. 1 oraz art. 455 ust. 1 Ustawy PZP. W przypadku zawarcia ugody przez Podmiot Publiczny, niedozwolone jest zatem zasadniczo wprowadzanie do Umowy o PPP zmian, które noszą charakter zmian istotnych. *A contrario* zmiany o charakterze nieistotnym mogą zostać wprowadzone zawsze bez konieczności wykazywania zaistnienia jakichkolwiek przesłanek.

Nieistotność zmiany oznacza, że wprowadzona modyfikacja nie wpływa na kluczowe elementy Umowy o PPP w sposób, który mógłby zakłócić równość szans wykonawców, zmienić charakter zamówienia lub wprowadzić nowego wykonawcę w miejsce dotychczasowego.

Schemat 27 – Zmiana Umowy o PPP na gruncie Ustawy PZP

Zmiana Umowy o PPP zgodnie z art. 454 ust. 2 Ustawy PZP jest uznawana za nieistotną, jeśli spełnia łącznie następujące przesłanki:

- Brak zmiany ogólnego charakteru umowy - np. zmiana z umowy dostawy na umowę o roboty budowlane;
- Brak wpływu na konkurencję - zmiana nie prowadziła do tego, że inni wykonawcy mogliby być zainteresowani udziałem w postępowaniu, gdyby była uwzględniona w pierwotnym ogłoszeniu;
- Brak wpływu na warunki ekonomiczne - modyfikacja nie powoduje istotnej zmiany równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy. Zmiany

Zmiana Umowy o PPP zgodnie z art. 454 ust. 2 Ustawy PZP jest uznawana za nieistotną, jeśli spełnia łącznie następujące przesłanki:

umowy ekonomicznie korzystne dla zamawiającego (np. zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy) mogą zostać uznane za nieistotne;

- Brak zmiany wykonawcy - zmiana nie polega na zastąpieniu wykonawcy innym podmiotem, chyba że wynika to z sukcesji prawnej lub reorganizacji wykonawcy.

Uwaga



Zmianami nieistotnymi będą:

- Zmiany administracyjne - korekty danych kontaktowych stron, zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy.
- Dostosowanie harmonogramu - niewielkie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów projektu, które nie wpływają na ostateczny termin zakończenia.
- Zmiany techniczne - użycie równoważnych materiałów lub technologii, które nie wpływają na jakość ani funkcjonalność Projektu PPP.
- Zmiany proceduralne - uproszczenie procedur raportowania lub wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych bez wpływu na zakres obowiązków stron.

Przykłady

W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym modernizacji i eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Z, w drugim roku Etapu Operacyjnego doszło do sporu między Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym w zakresie częstotliwości raportowania danych eksploatacyjnych. Podmiot Publiczny oczekiwał comiesięcznych szczegółowych raportów, mimo że Umowa o PPP przewidywała raportowanie kwartalne. Partner Prywatny podnosił, że zwiększona częstotliwość raportowania nie była przewidziana ani w dokumentacji przetargowej, ani w pierwotnym modelu kosztowym, i generuje dodatkowe koszty administracyjne.

Po nieudanych negocjacjach strony przeprowadziły mediację i na koniec postanowiły zawrzeć ugodę, której jednym z elementów była zmiana zapisów Umowy o PPP dotyczących częstotliwości i formatu raportowania. Zgodnie z ustaleniami, Partner Prywatny zobowiązał się do przesyłania raportów co dwa miesiące w uproszczonej formule, a Podmiot Publiczny odstąpił od żądania pełnych raportów comiesięcznych.

Zmiana ta została uznana przez strony za nieistotną w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, ponieważ: (i) nie zmieniała ogólnego charakteru umowy (dotyczyła jedynie procedury wewnętrznej, nie warunków technicznych czy ekonomicznych realizacji usług), (ii) nie wpływała istotnie na równowagę ekonomiczną Umowy o PPP, (iii) nie faworyzowała żadnego wykonawcy ani nie zmieniała kręgu potencjalnych uczestników postępowania przetargowego, oraz (iv) nie skutkowałą zmianą wykonawcy ani jego obowiązków podstawowych.

Zgodnie z postanowieniami ugody, zmiana została sformalizowana w formie aneksu do Umowy PPP, a jej wprowadzenie odbyło się z zachowaniem zgodności z przepisami Działu VII rozdziału 3 Ustawy PZP.

→ Zmiana Umowy o PPP na podstawie przesłanek kontraktowych

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, zmiana Umowy o PPP jest dopuszczalna, jeżeli możliwość takiej zmiany została przewidziana w postanowieniach Umowy o PPP w formie tzw. klauzul modyfikacyjnych. Klauzule te muszą być jasne, precyzyjne i jednoznaczne, określając:

- Zakres potencjalnych zmian – co konkretnie może ulec modyfikacji (np. harmonogram, zakres prac, wynagrodzenie).
- Warunki, w jakich zmiana jest dopuszczalna – okoliczności, które muszą wystąpić, aby zmiana była możliwa.
- Procedurę zmiany – sposób, w jaki zmiana powinna zostać przeprowadzona, w tym ewentualne wymogi formalne.

Uwaga

W praktyce Projektów PPP stosuje się różne rodzaje klauzul umownych umożliwiających zmianę Umowy. Przykłady takich klauzul obejmują:

- Klauzula waloryzacyjna – umożliwiająca dostosowanie wynagrodzenia Partnera Prywatnego w przypadku istotnych zmian wskaźników makroekonomicznych (np. inflacji).
- Klauzula siły wyższej – przewidująca możliwość zmiany Umowy o PPP w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych okoliczności, takich jak wojny, katastrofy naturalne czy kryzysy gospodarcze.
- Klauzula dostosowawcza (ang. *hardship clause*) – pozwalająca na renegotiację warunków umowy, gdy równowaga ekonomiczna kontraktu zostaje znacząco naruszona na skutek okoliczności niezależnych od stron.
- Klauzula zmiany przepisów prawa – umożliwiająca modyfikację Umowy o PPP w przypadku wprowadzenia nowych regulacji prawnych wpływających na realizację Projektu PPP.

Dobre Praktyki



Efektywne zarządzanie zmianami Umowy o PPP powinno być ściśle powiązane z matrycą ryzyk oraz ustalonym podziałem ryzyk pomiędzy stronami. Oznacza to, że:

- Zmiany umowy powinny odnosić się do okoliczności, które wpływają na alokację ryzyka.

Na przykład, jeżeli ryzyko zmiany przepisów prawa zostało przypisane Podmiotowi Publicznemu, to zmiana przepisów powinna skutkować odpowiednią modyfikacją Umowy o PPP na korzyść Partnera Prywatnego.

- Matryca ryzyk powinna być punktem odniesienia przy ocenie konieczności zmiany Umowy o PPP.

Zmiany powinny służyć przywróceniu równowagi ekonomicznej umowy, jeśli określone ryzyka materializują się w sposób odbiegający od pierwotnych założeń.

Zmiana Umowy o PPP na podstawie przesłanek kontraktowych wymaga jasnych i precyzyjnych klauzul umownych, które są spójne z przyjętym podziałem ryzyk, co zapewnia przejrzystość i przewidywalność dla obu stron Umowy o PPP, a przy tym pozwala łatwiej zawrzeć ugodę w przypadku zaistniałego sporu.

→ Zmiana Umowy o PPP na podstawie przesłanek ustawowych

W praktyce realizacji Umów o PPP często spotyka się sytuacje, w których umowy te nie przewidują wystarczających przesłanek umożliwiających dostosowanie ich postanowień do zmieniających się warunków gospodarczych, prawnych czy technicznych. Brak elastycznych klauzul modyfikacyjnych może prowadzić do trudności w efektywnym zarządzaniu Projektem PPP w dłuższym horyzoncie czasowym, a także być problematyczny w przypadku chęci zawarcia ugody, aby zakończyć istniejący pomiędzy stronami spór.

W takich przypadkach zastosowanie mogą znaleźć przepisy Ustawy PZP, w szczególności art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4) oraz ust. 2 Ustawy PZP. Przepisy te

umożliwiają dokonanie zmiany Umowy o PPP bez konieczności przewidzenia takiej możliwości w pierwotnej treści kontraktu, pod warunkiem spełnienia określonych w Ustawie PZP przesłanek.

▪ **Zastąpienie dotychczasowego Partnera Prywatnego**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) Ustawy PZP istnieje możliwość dokonania zmiany podmiotowej po stronie Partnera Prywatnego. Zastąpienie Partnera Prywatnego jest możliwe, jeśli zostało to przewidziane w Umowie o PPP w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny.

Zastąpienie dotychczasowego Partnera Prywatnego nowym może również nastąpić w wyniku sukcesji, poprzez przejęcie praw i obowiązków Partnera Prywatnego w wyniku przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Partnera Prywatnego lub jego przedsiębiorstwa. W takim przypadku nowy Partner Prywatny musi spełniać warunki udziału w postępowaniu prowadzonym na Etapie Przygotowawczym, wykazać brak podstaw do wykluczenia oraz zapewnić, że nie nastąpią inne istotne zmiany Umowy o PPP, a także że nie ma to na celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy PZP.

▪ **Realizacja przez Partnera Prywatnego dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy PZP możliwe jest wprowadzenie zmian Umowy o PPP polegających na rozszerzaniu ich zakresu rzeczowego przez zlecenie realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych. Zastosowanie tego przepisu wymaga wykazania spełnienia przesłanek określonych w tym przepisie:

- Zmiana Partnera Prywatnego nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, szczególnie dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- Zmiana Partnera Prywatnego spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Podmiotu Publicznego,

- Wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej Umowy o PPP.

Uwaga



Dodatkowe roboty budowlane nieobjęte pierwotnie Umową o PPP muszą być nieprzewidywalne i wynikać z przyczyn niezależnych od Podmiotu Publicznego. Niezbędność tych robót oznacza, że bez ich wykonania cele zamówienia podstawowego wchodzącego w skład Umowy o PPP nie zostaną osiągnięte. Dokonanie zmian w Umowie o PPP bez takiej niezbędności byłoby *de facto* udzieleniem nowego zamówienia, co naruszałoby zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Przykłady



W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym budowy obwodnicy miasta K, w trakcie realizacji inwestycji doszło do nieprzewidzianego osunięcia gruntu w rejonie wiaduktu. Partner Prywatny zgłosił konieczność wykonania dodatkowych robót zabezpieczających, których nie obejmowała pierwotna Umowa o PPP. Podmiot Publiczny zakwestionował zasadność roszczenia, co doprowadziło do sporu.

Zgodnie z Umową PPP, strony skierowały sprawę do niezależnego eksperta. Po analizie dokumentacji i uwarunkowań technicznych ekspert potwierdził, że roboty są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i że jedynie Partner Prywatny dysponuje technologią kompatybilną z dotychczasowymi rozwiązaniami.

W oparciu o opinię eksperta strony zawarły ugodę, której elementem było rozszerzenie zakresu rzeczowego Umowy o PPP poprzez zlecenie dodatkowych robót budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy PZP. Zmiana została uznana za istotną, lecz dopuszczalną – spełnione zostały przesłanki techniczne, ekonomiczne oraz limit wartościowy.

Po drugie, Podmiot Publiczny musi również wykazać, że zmiana wykonawcy nie jest możliwa z powodów ekonomicznych lub technicznych, takich jak zamiennność lub interoperacyjność wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego. Jednocześnie zmiana Partnera Prywatnego mogłaby spowodować istotne niedogodności lub znaczne zwiększenie kosztów dla Podmiotu Publicznego.

Trzecią przesłanką jest wykazanie, że wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy o PPP. Wartość pierwotnej umowy to pierwotna wartość brutto wynagrodzenia Podmiotu Publicznego określona w Umowie o PPP. Jeśli Umowa o PPP zawiera postanowienia dotyczące zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny ustala się na podstawie zmienionej ceny.

Przykłady



W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym budowy i utrzymania szpitala powiatowego, w trakcie realizacji Etapu Inwestycyjnego ujawniono konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wynikających ze zmiany przepisów przeciwpożarowych. Roboty te nie były objęte pierwotnym zakresem Umowy o PPP. Partner Prywatny zgłosił gotowość ich wykonania, natomiast Podmiot Publiczny miał wątpliwości co do zasadności rozszerzenia umowy oraz sposobu wyceny dodatkowego zakresu.

Zgodnie z procedurą rozwiązywania sporów zawartą w Umowie, strony zdecydowały się na przeprowadzenie koncyliacji i wspólnie uzgodniły osobę koncyliatora – inżyniera z doświadczeniem w inwestycjach medycznych i projektach PPP. Koncyliator po analizie dokumentacji, wizji lokalnej i spotkaniach ze stronami przedstawił propozycję rozwiązania sporu, wskazując, że:

- zmiana wykonawcy robót nie jest możliwa z przyczyn technicznych i ekonomicznych, ponieważ prowadzenie prac przez innego wykonawcę na ograniczonym terenie szpitala groziłoby poważnymi zakłóceniami logistycznymi i opóźnieniami,

Przykłady



- konieczne byłoby zabezpieczenie już zrealizowanych części obiektu, co generowałoby znaczne koszty,
- dodatkowe roboty muszą być kompatybilne z systemami technologicznymi już wdrożonymi przez Partnera Prywatnego, co przesądza o wymogu ich realizacji przez tego samego wykonawcę.

W oparciu o propozycję koncyliatora strony zawarły ugodę, w ramach której dokonano istotnej zmiany Umowy o PPP na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP. Rozszerzenie zakresu rzeczowego zostało uzasadnione technicznie i mieściło się w limicie 50% wartości pierwotnej Umowy o PPP.

Dzięki koncyliacji strony uniknęły eskalacji sporu, a projekt mógł być kontynuowany bez opóźnień i z zachowaniem pełnej zgodności z przepisami Ustawy PZP.

Art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy PZP jest szczególnie istotny w kontekście Umów o PPP, ponieważ umożliwia elastyczne dostosowanie umowy do zmieniających się potrzeb i okoliczności, bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis ten pozwala na kontynuację współpracy z dotychczasowym Partnerem Prywatnym, co może być korzystne z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego, zwłaszcza gdy zmiana Podmiotu Prywatnego mogłaby prowadzić do istotnych niedogodności lub znacznego zwiększenia kosztów.

Dobre Praktyki



W praktyce, zastosowanie art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy PZP wymaga dokładnego udokumentowania i wykazania, że wszystkie przesłanki określone w przepisie zostały spełnione. Podmiot Publiczny musi wykazać, że dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane są niezbędne do wykonania Umowy o PPP i że zmiana Podmiotu Prywatnego nie jest możliwa z powodów ekonomicznych lub technicznych. Ponadto, wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekraczać 50% wartości pierwotnej Umowy o PPP, co ma na celu zapewnienie,

Dobre Praktyki



że zmiany Umowy o PPP nie prowadzą do nadmiernego zwiększenia kosztów dla Podmiotu Publicznego.

- **Okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) Ustawy PZP dopuszczalna jest zmiana Umowy o PPP bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany Umowy o PPP, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Podmiot Publiczny, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy o PPP, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy o PPP.

Okoliczności niemożliwe do przewidzenia to takie, których nie można było przewidzieć mimo starannego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. Według stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych, nie chodzi o zdarzenia nieprzewidywane przez strony, ale o te, których wystąpienie było mało prawdopodobne. Podmiot Publiczny powinien przeanalizować swoje potrzeby i warunki realizacji zamówienia. Okoliczności te muszą przekraczać standardowe ryzyka związane z realizacją Umowy o PPP. Powinny być niezależne od stron Umowy o PPP i mieć charakter nadzwyczajny, jak np. gwałtowna dekonstrukcja czy istotny wzrost cen materiałów. Konflikt zbrojny w Ukrainie jest przykładem takiego zjawiska¹⁹.

Okoliczności wywołujące konieczność zmiany umowy powinny być niezależne od jej stron. Zjawiska gospodarcze, jak gwałtowna dekonstrukcja czy istotny wzrost cen materiałów, muszą mieć charakter nadzwyczajny, aby Podmiot Publiczny nie mógł ich przewidzieć mimo zachowania należytej staranności. Okoliczności te muszą mieć

¹⁹ Źródło: <https://www.gov.pl/web/uzp/dopuszczalnosc-zmiany-umowy-w-sprawie-zamowienia-publicznego-na-podstawie-art-455-ust-1-pkt-1-i-4-oraz-art-455-ust-2-ustawy-pzp>

jednak charakter na tyle nadzwyczajny, że zamawiający, dochowując należytej staranności, nie mógł obiektywnie przewidzieć ich zaistnienia lub skali ich zaistnienia. W przypadku gdy obiektywnie możliwe było przewidzenie zaistnienia określonych zjawisk gospodarczych oraz ich skali, wprowadzenie zmian do umowy na podstawie dyspozycji komentowanego przepisu nie jest możliwe.

Przykładami takich okoliczności będą zjawiska gospodarcze zewnętrzne w stosunku do stron Umowy o PPP i w pełni od nich niezależne, jak np.: gwałtowna dekonunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów.

Nieprzewidziane okoliczności mogą znacząco wpłynąć na realizację Projektu PPP. Podmiot Publiczny musi ocenić, czy te okoliczności rzeczywiście wpływają na proces realizacji Umowy o PPP i czy konieczna jest jej zmiana. Przesłanki zmiany Umowy o PPP na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) Ustawy PZP są autonomiczne i mogą być stosowane niezależnie od klauzul waloryzacyjnych w Umowie o PPP.

Przykłady



W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym zaprojektowania, budowy i utrzymania nowoczesnego centrum edukacyjnego, Partner Prywatny w trakcie realizacji Etapu Inwestycyjnego zgłosił istotny wzrost kosztów materiałów budowlanych i usług podwykonawczych. Wzrost ten był wynikiem wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, co doprowadziło do zaburzenia łańcuchów dostaw, ograniczenia dostępności surowców oraz gwałtownego wzrostu cen, szczególnie stali i komponentów instalacyjnych.

Partner Prywatny wystąpił do Podmiotu Publicznego z wnioskiem o zmianę Umowy o PPP, w szczególności w zakresie zwiększenia wynagrodzenia, powołując się na nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności. Podmiot Publiczny, mimo dostrzegania skali problemu, zakwestionował wysokość żądanego wzrostu wynagrodzenia i zakres jego uzasadnienia. Próby negocjacji zakończyły się fiaskiem.

Zgodnie z mechanizmami rozwiązywania sporów przewidzianymi w Umowie o PPP, strony zdecydowały się na przeprowadzenie mediacji przed uzgodnionym

Przykłady

ośrodkiem mediacyjnym. W obecności mediatora strony przedstawiły swoje stanowiska oraz niezależne analizy rynkowe. Po trzech tygodniach intensywnych rozmów wypracowano kompromis polegający na częściowej waloryzacji wynagrodzenia Partnera Prywatnego, ograniczonej do pozycji kosztowych najbardziej dotkniętych skutkami wojny.

W wyniku mediacji zawarto ugodę, której częścią był aneks do Umowy o PPP wprowadzający istotną zmianę zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4) Ustawy PZP.

Dzięki wykorzystaniu mediacji oraz zastosowaniu art. 455 ust. 1 pkt 4) Ustawy PZP, strony uniknęły sporu sądowego, zapewniły kontynuację Umowy o PPP oraz ochroniły równowagę ekonomiczną Projektu PPP.

- **Zmiany bagatelne**

Art. 455 ust. 2 Ustawy PZP pozwala na zmianę Umowy o PPP bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli spełnione są określone przesłanki. Przepis ten jest szczególnie istotny w kontekście Projektów PPP, ponieważ umożliwia elastyczne dostosowanie Umowy o PPP do zmieniających się potrzeb i okoliczności. Łączna wartość zmiany musi być mniejsza niż progi unijne oraz niższa niż 10 % wartości pierwotnej Umowy o PPP w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15% w przypadku zamówień na roboty budowlane. Zmiany nie mogą modyfikować ogólnego charakteru Umowy o PPP.

Uwaga

Omawiając warunki dokonania zmiany Umowy o PPP wskazane w art. 455 ust. 2 Ustawy PZP nie sposób nie zauważyć, że opierają się one wyłącznie na przesłankach o charakterze czysto formalnym (maksymalna łączna wartość zmiany nie może przekroczyć progu unijnego i zarazem nie może przekroczyć określonego w przepisie progu procentowego wartości wskazanej w umowie).

Uwaga

Dla oceny dopuszczalności dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie wskazanej przesłanki bez znaczenia pozostają faktyczne przyczyny rodzące konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Nie wyrażając żadnych innych wymogów wprowadzenia zmiany *de minimis*, prawodawca wspólnotowy (a w ślad za nim również polski) dał wyraz swojej woli przyznania stronom umowy w sprawie zamówienia publicznego dyskrecjonalnego uprawnienia do dokonywania jej modyfikacji (w granicach limitów kwotowych wyznaczonych omawianym przepisem).

2.7.2.2 Ustawa o Finansach Publicznych

Zawieranie ugód przez Podmioty Publiczne było przez wiele lat utrudnione, ponieważ uznawano je za potencjalne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Sytuacja zmieniła się od 1 czerwca 2017 r., gdy wprowadzono do Ustawy o Finansach Publicznych nowy przepis – art. 54a, który wyraźnie dopuścił możliwość zawierania ugód przez jednostki sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 54a Ustawy o Finansach Publicznych, Podmiot Publiczny może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej, jeśli spełnione są dwa (2) warunki:

Schemat 28 – Zawarcie ugody zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych

1. Dokonano pisemnej oceny skutków zawarcia ugody, która uwzględnia:
 - a. zasadność roszczeń,
 - b. możliwość ich zaspokojenia,
 - c. przewidywany czas trwania ewentualnego postępowania sądowego lub arbitrażowego,
 - d. koszty prowadzenia sporu.
2. Ocena ta wykazała, że ugoda jest korzystniejsza niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego lub arbitrażowego.

Zasady te dotyczą każdej ugody zawieranej przez Podmiot Publiczny, w tym tych, które dotyczą Projektów PPP.

Uwaga



Jak wskazano w Rekomendacjach Prokuraturii Generalnej RP dot. postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów²⁰ podjęcie decyzji o zawarciu w takich okolicznościach ugody w konkretnej sprawie – przy zachowaniu procedury i warunków przewidzianych w art. 54a Ustawy o Finansach Publicznych oraz spełnieniu ogólnych przesłanek dopuszczalności ugody – zapewnia jednostce sektora finansów bezpieczeństwo z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych.

²⁰ Źródło: <https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/rekomendacje-prokuraturii-generalnej-rp-dotyczace-postepowania-w-zakresie-polubownego-rozwiazywania-sporow>

2.7.2.3 Mechanizmy akceptacji ugody w Projektach PPP

W świetle wymogów określonych w art. 54a Ustawy o Finansach Publicznych podjęcie decyzji o zawarciu ugody przez Podmiot Publiczny wymaga przeprowadzenia określonych analiz, których przeprowadzenie rekomenduje Prokuratoria Generalna RP. W zależności od okoliczności sprawy może ona obejmować nie tylko analizę faktów i elementy analizy prawnej, ale także analizy o charakterze merytorycznym (opinie biegłych, prywatnych ekspertów technicznych, dotyczące prawa obcego itp.).

Schemat 29 - Mechanizm zatwierdzania ugody w świetle wymogów art. 54a Ustawy o Finansach Publicznych

Przygotowanie analizy skutków ugody, w której należy uwzględnić m. in.²¹:

I. Zasadność spornych żądań

- Stan faktyczny: Jakie były okoliczności i przyczyny powstania sporu? Czy zaistniały okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie?

Oceny tej należy dokonywać w sposób zobiektywizowany, biorąc pod uwagę potencjalne różnice w interpretacji zaistniałych okoliczności przez drugą stronę sporu.

Na potrzeby tej analizy należy odtworzyć istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, w szczególności:

- przyczyny i okoliczności powstania sporu,
- działania podejmowane przez obie strony w związku z przyczyną sporu, a także niezależnie od stron okoliczności, wpływ osób trzecich na zaistnienie lub zakres sporu,
- działania podjęte przez obie strony (lub zaniechania) po powstaniu sporu.

W zależności od okoliczności sprawy, dla oceny zasadności spornych żądań mogą mieć znaczenie także inne okoliczności faktyczne, np. okoliczności zawarcia, cel Umowy o PPP i dotychczasowy przebieg jej realizacji, treść korespondencji i prezentowanych stanowisk, wcześniejsze próby polubownego rozwiązania sporu, treść wniosków dostępnych ekspertów, opinii prywatnych itp.

²¹ Źródło: <https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/rekomendacje-prokuraturii-generalnej-rp-dotyczace-postepowania-w-zakresie-polubownego-rozwiazywania-sporow>

Przygotowanie analizy skutków ugody, w której należy uwzględnić m. in.²¹:

- Ryzyka procesowe: Czy (w jakim stopniu) jest prawdopodobne, że wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego byłby korzystniejszy dla Podmiotu Publicznego niż propozycja ugodowa?
- Analiza prawna stanu faktycznego, gdzie należy ustalić przede wszystkim:
 - treść i zakres obowiązków stron (w świetle Umowy o PPP i relewantnych przepisów prawa), których dotyczy spór,
 - potencjalną podstawę lub podstawy prawne żądania (np. odpowiedzialność kontraktowa, rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego, bezpodstawne wzbogacenie itp.),
 - w przypadku odpowiedzialności kontraktowej m. in.: zasady odpowiedzialności (wina, zasada ryzyka), przy uwzględnieniu, czy dokonano rozszerzenia odpowiedzialności dłużnika w umowie, wymagany standard staranności dłużnika, odpowiedzialność za działania osób trzecich itp.,
 - zakres możliwych żądań (np. należność główna, odsetki, kary umowne, odszkodowanie),
 - wymagalność spornych żądań.

W ramach tej analizy istotne są m. in. takie okoliczności jak:

- klarowność podstaw prawnych i kontraktowych żądań (w tym: ewentualne ryzyko sporu co do treści Umowy o PPP),
- istnienie rozbieżności orzeczniczych co do istotnych dla sprawy zagadnień prawnych,
- ryzyko podważenia ważności lub skuteczności umowy lub innych istotnych dla sprawy czynności prawnych (np. odstąpienie od umowy, potrącenie), w tym ocena prawidłowości reprezentacji stron, zachowanie wymaganej formy, terminu lub trybu dokonania czynności.

Przygotowanie analizy skutków ugody, w której należy uwzględnić m. in.²¹:

- Analiza sfery dowodowej, która może obejmować w szczególności:
 - ocenę, czy Podmiot Publiczny dysponuje dowodami uzasadniającymi żądanie Partnera Prywatnego na podstawie analizy posiadanych przez Podmiot Publiczny dowodów oraz ich waloru (np. dokumenty prywatne vs. dokumenty urzędowe, dokumenty vs. zeznania świadków) i/lub wiarygodności, przy uwzględnieniu rozkładu ciężaru dowodu w danej sprawie,
 - analizę faktycznej i prawnej możliwości wykazania istotnych dla sprawy faktów za pomocą posiadanych dowodów (np. z uwagi na zmiany organizacyjne w jednostce, trudności w ustaleniu miejsca pobytu świadka, formę pisemną zastrzeżoną dla celów dowodowych itp.),
 - ocenę potrzeby przeprowadzenia dowodu (dowodów) z opinii biegłego i stopnia jej skomplikowania,
 - analizę dowodów, jakimi dysponuje lub może potencjalnie dysponować druga strona sporu.
- Ryzyko (lub możliwość) skutecznego skorzystania przez jedną ze stron z zarzutów procesowych lub innych szczególnych uprawnień, przykładowo:
 - zarzut przedawnienia/upływu terminu zawitego,
 - zarzut potrącenia,
 - zarzuty formalne, np. zarzut powagi rzeczy osądzonej, niedopuszczalności drogi sądowej albo zapisu na sąd polubowny,
 - żądanie obniżenia kary umownej,
 - uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli (błąd, podstęp, groźba),
 - żądanie unieważnienia Umowy o PPP.

Przygotowanie analizy skutków ugody, w której należy uwzględnić m. in.²¹:

II. Czas trwania postępowania sądowego albo arbitrażowego

- Na długość trwania postępowania sądowego albo arbitrażowego wpływać mogą m. in. następujące okoliczności:
 - przedmiot i zakres spornych żądań oraz stopień skomplikowania sprawy pod względem faktycznym lub prawnym,
 - przewidywany zakres postępowania dowodowego (liczba i rodzaj dowodów potrzebnych do przeprowadzenia), w tym zwłaszcza potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego,
 - obciążenie sądu właściwego (czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy),
 - nasilenie i charakter spornych kwestii oraz wartość przedmiotu sporu, które wpływają na prawdopodobieństwo wnoszenia środków zaskarżenia.

III. Koszty postępowania sądowego albo arbitrażowego

- Przy analizie tego kryterium należy brać pod uwagę:
 - koszty procesu, w tym – opłaty i inne koszty sądowe (np. koszty sporządzenia opinii biegłych, koszty zastępstwa procesowego, koszty stawienia się w sądzie, koszty tłumaczeń) i koszty postępowania egzekucyjnego,
 - inne wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione w związku ze wszczęciem lub w toku postępowania sądowego (np. koszty uzyskania prywatnych ekspertyz, przeprowadzenia innych badań lub analiz),
 - inne koszty jakie wiążą się z zaangażowaniem pracowników jednostki i innych osób (np. zewnętrznych prawników) w postępowanie sądowe.

Przygotowanie analizy skutków ugody, w której należy uwzględnić m. in.²¹:

IV. Inne okoliczności

- W ocenie można uwzględniać również inne elementy, w zależności m.in. od specyfiki i przedmiotu sporu, charakteru Podmiotu Publicznego.
- W okolicznościach konkretnej sprawy za korzystnością ugody może uzupełniająco przemawiać przykładowo:
 - interes publiczny (np. w szybkim zakończeniu realizacji Umowy o PPP w celu udostępnienia usług użyteczności publicznej),
 - wielość stron (uczestników) sporu,
 - możliwość objęcia ugodą i definitywnego rozstrzygnięcia dodatkowych kwestii spornych (ograniczenie potencjału przyszłych sporów),
 - potrzeba dalszej współpracy z drugą stroną,
 - zachowanie tajemnicy prawnie chronionej,
 - negatywny wpływ sporu na realizację innych umów.

Uwaga



Dodatkowe, niewymienione w art. 54a ust. 2 Ustawy o Finansach Publicznych przesłanki nie mogą stanowić jedynej podstawy do zawarcia ugody, albowiem mają one raczej charakter uzupełniający.

Rozdział 3

Prowadzenie sporów na drodze postępowania sądowego albo arbitrażowego

Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom I–IV

Tom III: Część II Punkt 6 – Procedura rozwiązywania sporów

Tom IV: Część II Punkt 1.3.2 – Rozwiązywanie sporów

W momencie, gdy zastosowane przez strony Umowy o PPP polubowne metody rozwiązywania sporów okażą się niewystarczające, konieczne staje się poddanie sporu pod rozstrzygnięcie w ramach postępowania sądowego lub postępowania arbitrażowego (tzw. formalny etap sporny). Zainicjowanie sporu sądowego albo arbitrażowego może mieć miejsce zarówno w trakcie realizacji Umowy o PPP, jak i po jej zakończeniu, kiedy strony wciąż mają wobec siebie niezaspokojone roszczenia związane z jej realizacją.

Formalny etap sporny należy jednak traktować jako ostateczność i skorzystać z niego w sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia z wykorzystaniem polubownych metod rozwiązywania sporów okaże się niemożliwe lub nieodpowiednie dla zaistniałej sytuacji. Przejście na formalny etap sporny stwarza jednak ryzyko znacznego pogorszenia relacji pomiędzy stronami Umowy o PPP, co w ramach Projektów PPP jest o tyle ryzykowne, że z założenia są to projekty długotrwałe i wymagające wzajemnej współpracy pomiędzy stronami przez cały okres ich trwania, aż do zakończenia Etapu Operacyjnego. Zainicjowanie przez jedną ze stron formalnego etapu spornego może doprowadzić do nieodwracalnego konfliktu, który nie tyle co utrudni, ale może nawet uniemożliwić dalszą współpracę w Projekcie PPP.

Istotne jest, aby już na etapie zawierania Umowy o PPP strony ustaliły organ właściwy do rozstrzygania sporów na formalnym etapie spornym. Decyzja czy poddać spory wynikające z danej Umowy o PPP pod jurysdykcję sądu powszechnego czy sądu arbitrażowego powinna być podejmowana osobno w ramach każdej samodzielnej inwestycji objętej daną Umową o PPP i uwzględniać przede wszystkim: (i) przedmiot tej inwestycji, (ii) jej założenia, (iii) wartość oraz (iv) oczekiwania stron.

3.1 Postępowanie arbitrażowe

3.1.1 Wady i zalety postępowania arbitrażowego

Postępowanie arbitrażowe, jako alternatywna dla sądownictwa powszechnego, cieszy się coraz większą popularnością w przypadku sporów wynikających z dużych i skomplikowanych przedsięwzięć gospodarczych, w tym w szczególności w sektorze infrastruktury i budownictwa.

Do najważniejszych zalet postępowania arbitrażowego bez wątpienia należy jego szybkość (w szczególności w porównaniu do tradycyjnego postępowania przed sądem powszechnym w Polsce), stopień wiedzy specjalistycznej arbitrów (arbitrzy wybierani są przez strony w oparciu o ich wiedzę w danym temacie, a nie według ich dostępności w formie losowania jak w sądownictwie powszechnym), jednoinstancyjność postępowania, zachowanie poufności i skuteczność orzeczeń w ramach wielu jurysdykcji.

Postępowanie arbitrażowe ma jednak swoje wady, które wynikają z jego specyfiki jako alternatywnej do sądownictwa państwowego metody rozstrzygania sporów. Należą do nich w szczególności czasami wyższe koszty postępowania arbitrażowego, co do zasady brak możliwości odwołania się od wyroku arbitrażowego, brak uprawnień w zakresie przymusu prawnego po stronie arbitrów oraz brak jednolitych zasad arbitrażu.

Schemat 30 - Wybrane zalety i wady postępowania arbitrażowego

Zalety	Wady
Szybkość postępowania - postępowanie arbitrażowe ma co do zasady charakter jednoinstancyjny, co eliminuje co do zasady długotrwałe postępowanie odwoławcze; - tempo procedowania nie jest uzależnione od obłożenia sądów; - brak formalizmu zwalniającego procedowanie; - sprawniejsza organizacja postępowania (np. wyznaczenie kilku następujących po sobie dni na przesłuchanie świadków); - możliwość określenia terminów na składanie stanowisk stron i dowodów; - możliwość ustalenia czasu, po jakim ma zapaść orzeczenie.	Wyższe koszty postępowania - wyższe honorarium arbitrów; - wyższe opłaty instytucji arbitrażowych; - brak jednolitego systemu zwrotu kosztów.
Poufność postępowania - orzeczenie nie są publikowane i powszechnie dostępne; - akta nie są dostępne dla osób trzecich; - brak jawności rozpraw.	Brak możliwości odwołania się od orzeczenia sądu arbitrażowego wyrok sądu jest co do zasady ostateczny, a możliwość uchylenia tylko w wyjątkowych sytuacjach, co w pewnym niewielkim wycinku przypadkach może okazać się istotne.

Zalety	Wady
Fachowość i specjalizacja arbitrów - arbitrzy wybierani są przez strony spośród fachowców; - lepsze zrozumienie kwestii technicznych czy ekonomicznych przez arbitrów będących ekspertami w danej dziedzinie.	Ryzyko uchylania się przez przegraną stronę od wykonania orzeczenia sądu arbitrażowego nadużywanie instytucji kontroli orzeczenia sądu arbitrażowego np. skargi o uchylenie orzeczenia sądu polubownego.
Elastyczna procedura strony decydują o zasadach postępowania.	Możliwość utrudniania egzekucji orzeczenia sądu arbitrażowego konieczne uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu arbitrażowego przez sąd powszechny, co wydłuża możliwość wszczęcia egzekucji.
Egzekwowalność orzeczeń na arenie międzynarodowej orzeczenia wydawane przez najbardziej wiarygodne instytucje arbitrażu międzynarodowego są powszechnie uznawane w ramach wielu jurysdykcji.	Brak przymusu prawnego arbitrów arbitrzy mają ograniczone uprawnienia w zakresie możliwości dyscyplinowania stron, np. w zakresie niestawiennictwa świadków.
Możliwość ustalenia neutralnego miejsca postępowania.	Nieodpowiedni dla niektórych rodzajów spraw, np. sprawy o niskiej i średniej wartości.
Większa swoboda w powoływaniu ekspertów arbitrzy powoływani są przez strony.	Brak jednolitych zasad strony mogą modyfikować zasady postępowania arbitrażowego, w tym w szczególności w zakresie gromadzenia

Zalety	Wady
	dowodów. Dotyczy to w szczególności arbitrażu <i>ad hoc</i> .

Powyższe zalety i wady postępowania arbitrażowego wskazują, że przy wyborze arbitrażu jako instytucji właściwej do rozwiązywania sporów w ramach Umowy o PPP, należy mieć na uwadze skalę i potrzeby danego Projektu PPP. W szczególności mając na uwadze, że stroną Umowy o PPP jest Podmiot Publiczny, to niektóre zalety postępowania arbitrażowego, jak np. brak jawności, mogą okazać się kłopotliwe i sprzeczne z obowiązkiem zachowania transparentności przez Podmioty Publiczne w sprawach wydawania środków publicznych lub przebiegu inwestycji.

Natomiast w przypadku Projektów PPP, których przedmiotem jest np. infrastruktura użyteczności społecznej, o kluczowym znaczeniu dla realizacji potrzeb społeczeństwa, szybkość rozwiązywania sporów, jaką arbitraż oferuje w porównaniu do postępowania przed sądem powszechnym, może się okazać kluczowym aspektem dla sukcesu danej inwestycji.

Dobre Praktyki



Konieczne jest każdorazowe rozważenie przez strony Umowy o PPP wyboru właściwej metody rozwiązywania sporów w oparciu o wymagania Projektu PPP, jego wartość i charakterystykę.

Schemat 31 – Kiedy arbitraż jest właściwym sposobem rozwiązywania sporów

Arbitraż jest właściwym rozwiązaniem w następujących przypadkach:

- W przypadku dużych inwestycji o wysokiej wartości;
- W przypadku skomplikowanych inwestycji, gdy wymagana jest wiedza specjalistyczna;
- Spór dotyczy skomplikowanych kwestii technicznych;
- Stronom zależy na szybkim rozwiązaniu sporu;
- Stronom zależy na poufności;
- Strony chcą uniknąć sformalizowanego i długotrwałego postępowania sądowego;
- Stronami umowy są podmioty z różnych jurysdykcji

3.1.2 Wybór postępowania arbitrażowego

Postępowanie arbitrażowe może być właściwą alternatywą dla postępowania sądowego w przypadku Umowy o PPP o dużej wartości, w tym w szczególności umów obejmujących skomplikowane, specjalistyczne roboty budowlane (np. w sektorze energetyki). Postępowanie arbitrażowe jest również preferowaną metodą rozwiązywania sporów w przypadku, gdy Partner Prywatny zaangażowany w Projekt PPP pochodzi z innego kraju niż Podmiot Publiczny.

Decydując się na poddanie sporów wynikających z Umowy o PPP pod właściwość sądu arbitrażowego wymagane jest zawarcie w Umowie o PPP odpowiedniej klauzuli arbitrażowej (tzw. zapisu na sąd polubowny). W ramach klauzuli arbitrażowej należy wskazać sąd arbitrażowy pod właściwość którego oddaje się spory wynikające z Umowy o PPP albo wskazać, że spory będą rozstrzygane przez sąd arbitrażowy powoływany *ad hoc*, tj. do rozstrzygnięcia określonej sprawy. Klauzula arbitrażowa powinna określać również język oraz miejsce postępowania arbitrażowego.

W przypadku braku zawarcia w Umowie o PPP klauzuli arbitrażowej, ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Jeżeli, pomimo braku zawarcia klauzuli arbitrażowej, strony będą jednak chciały poddać istniejący już spór pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, konieczne będzie zawarcie osobnej umowy o poddanie istniejącego sporu pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego. Warto również wskazać, że nowelizacja z dnia 9 marca 2023 r. wprowadziła do KPC instytucję konwersji, która umożliwia za zgodą stron, zamianę już trwającego postępowania sądowego na arbitrażowe. Dzięki dodanemu art. 1161¹ KPC strony mogą – aż do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu – przekierować sprawę do arbitrażu. W tym celu strony po powstaniu sporu muszą zawrzeć umowę arbitrażową.

Poniżej wskazano przykładowe modelowe klauzule arbitrażowe proponowane przez krajową i międzynarodową instytucję arbitrażową.

Przykładowe Postanowienia

Modelowa klauzula arbitrażowa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej:

Wszelkie spory wynikające z tej umowy lub pozostające w związku z nią zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez trybunał arbitrażowy zgodnie z regulaminem arbitrażowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania.

Językiem postępowania będzie język [polski].

Miejscem postępowania będzie [Warszawa]

Modelowa klauzula arbitrażowa Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.

3.1.3 Wybór arbitrażu *ad hoc* lub instytucjonalnego

Jeżeli strony zdecydują się na wybór arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów wynikających z Umowy o PPP, to powinny określić czy spory te będą rozwiązywane w ramach arbitrażu instytucjonalnego czy tzw. arbitrażu *ad hoc*.

Arbitraż instytucjonalny jest to arbitraż oparty o stałą instytucję arbitrażową, która zapewnia regulaminy, administrację oraz wsparcie organizacyjne, np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SAKiG), Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu, Trybunał Arbitrażowy przy Sztokholmskiej Izbie Handlowej (SCC).

W przypadku poddania Umowy o PPP pod jurysdykcję międzynarodowej instytucji arbitrażowej, do najczęściej wybieranych należą Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu²², Trybunał Arbitrażowy przy Sztokholmskiej Izbie Handlowej (SCC) w Sztokholmie²³ lub Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy w Londynie (LCIA)²⁴.

Natomiast w przypadku wyboru polskich sądów arbitrażowych, do najczęściej wybieranych instytucji należą Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SAKiG)²⁵, Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan²⁶ czy Sąd Arbitrażowy przy Prokuraturii Generalnej RP²⁷. W przypadku wyboru jednej z tych instytucji rekomendowane jest posługiwanie się modelowymi klauzulami, które można znaleźć na stronach internetowych tych instytucji.

Arbitraż instytucjonalny zapewnia stronom większą pewność toczącego się postępowania arbitrażowego, ze względu na koordynowanie go przez wyspecjalizowaną instytucję, co przekłada się na zapewnienie obsługi

²² Źródło: <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/arbitration-clause/>

²³ Źródło: <https://sccarbitrationinstitute.se/en/dispute-resolution-clauses/>

²⁴ Źródło: https://www.lcia.org/dispute_resolution_services/lcia_recommended_clauses.aspx

²⁵ Źródło: <https://sakig.pl/arbitraz/modelowe-klauzule-arbitrazowe>

²⁶ Źródło: <https://sadarbitrazowy.org.pl/arbitraz/klauzula-arbitrazowa/>

²⁷ Źródło: <https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/klauzula-umowne>

administracyjnej oraz mechanizmów na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji (np. wymiany arbitra).

Strony mają jednak mniejszą swobodę w kształtowaniu zasad postępowania arbitrażowego, gdyż co do zasady odwołują się i przyjmują regulamin danej instytucji arbitrażowej. Arbitraż instytucjonalny jest również droższy, gdyż oprócz honorarium arbitrów, strony muszą również ponieść opłaty instytucjonalne.

Zaletą arbitrażu instytucjonalnego jest jednak „kontrola” nad postępowaniem arbitrażowym przez wiarygodną instytucję, wsparcie administracyjne oraz większa pewność prawna, gdyż instytucje dbają o zgodność procedur z międzynarodowymi standardami.

Arbitraż *ad hoc* odbywa się natomiast bez odwołania do zasad instytucjonalnych. To strony powinny określić jego zasady i jest zależny od współpracy stron. W ramach tej procedury strony mają znacznie większą elastyczność w ustalaniu zasad, jednak muszą przy tym jednocześnie pilnować, by zasady arbitrażu nie naruszały międzynarodowych standardów (co może wpływać na możliwość uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku). Arbitraż *ad hoc* może być również tańszy od arbitrażu instytucyjnego (brak opłat instytucjonalnych) oraz szybszy (brak bardziej zaawansowanych procedur instytucjonalnych). Arbitraż *ad hoc* wymaga przy tym większego doświadczenia po stronie stron, gdyż to one ustalają jego zasady.

Wydaje się, że każdy z przywołanych powyżej sposobów ma swoje wady i zalety oraz odmienne zastosowanie. Arbitraż instytucjonalny wydaje się bardziej odpowiedni dla dużych i skomplikowanych spraw, podczas gdy arbitraż *ad hoc* może być z powodzeniem stosowanych w ramach mniejszych postępowań, podczas których stronom zależy na czasie i mniejszych kosztach.

Dobre Praktyki

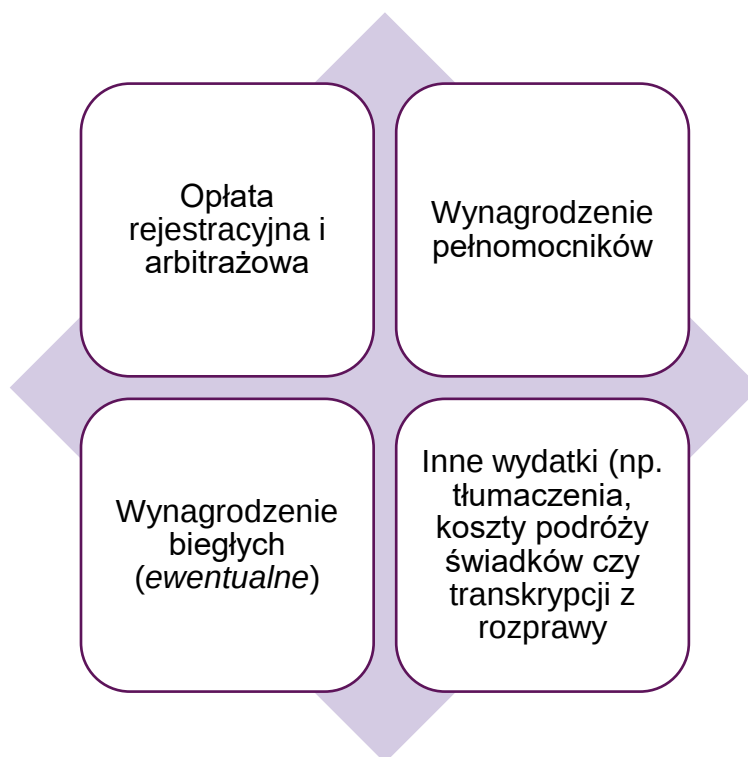


Rekomendowane jest stosowanie arbitrażu instytucjonalnego w ramach zaufanych instytucji arbitrażowych, ze względu na powszechne uznawanie orzeczeń wydawanych przez składy arbitrażowe orzekające w ramach tych instytucji.

Analizując kwestię kosztów związanych z wyborem określonej instytucji arbitrażowej, należy wziąć pod uwagę, że wysokość kosztów ponoszonych przez stronę w arbitrażu zależy przede wszystkim od wartości przedmiotu sporu.

W postępowaniu arbitrażowym ponoszone są następujące rodzaje kosztów:

Schemat 32 – Koszty postępowania arbitrażowego

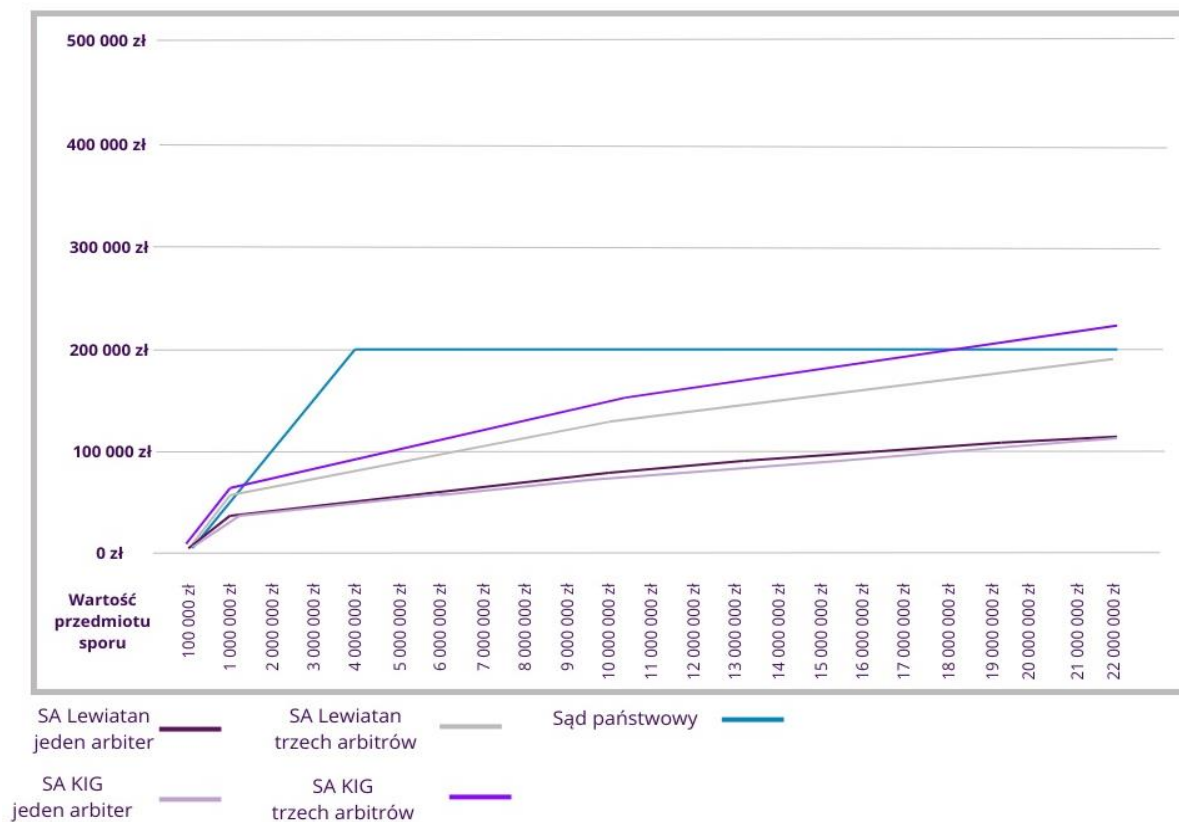


Opłata arbitrażowa jest wnoszona przez stronę wszczynającą postępowanie, czyli powoda. Pozwany jest natomiast zobowiązany do zapłaty opłaty arbitrażowej, jeżeli wytoczy powództwo wzajemne przeciwko powodowi lub podniesie zarzut potrącenia. W trakcie prowadzenia postępowania arbitrażowego każda ze stron samodzielnie pokrywa zatem swoje koszty. Po jego zakończeniu strony mogą przedstawić zestawienie poniesionych wydatków i domagać się, aby trybunał arbitrażowy zobowiązał stronę przeciwną do ich pełnego zwrotu.

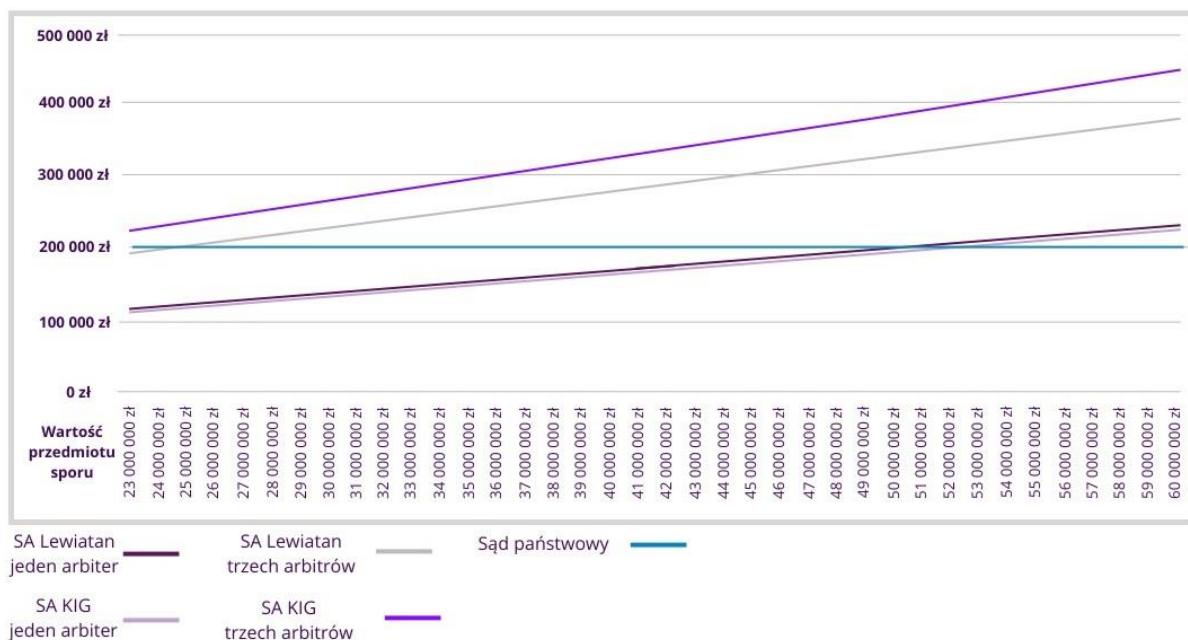
Jak wskazuje się w raportach branżowych, opłaty w postępowaniu arbitrażowym są niższe od opłat sądowych, gdy wartość przedmiotu sporu mieści się w przedziale od 1 120 000 zł do 24 580 000 zł. Ponadto opłaty w arbitrażu mogą być niższe od opłat

sądowych, nawet gdy wartość przedmiotu sporu przekroczy 50 000 000 zł, jeżeli strony ograniczą liczbę arbitrów z trzech (3) do jednego (1)²⁸.

Schemat 33 - Opłaty w sądach arbitrażowych a opłaty sądowe w Polsce

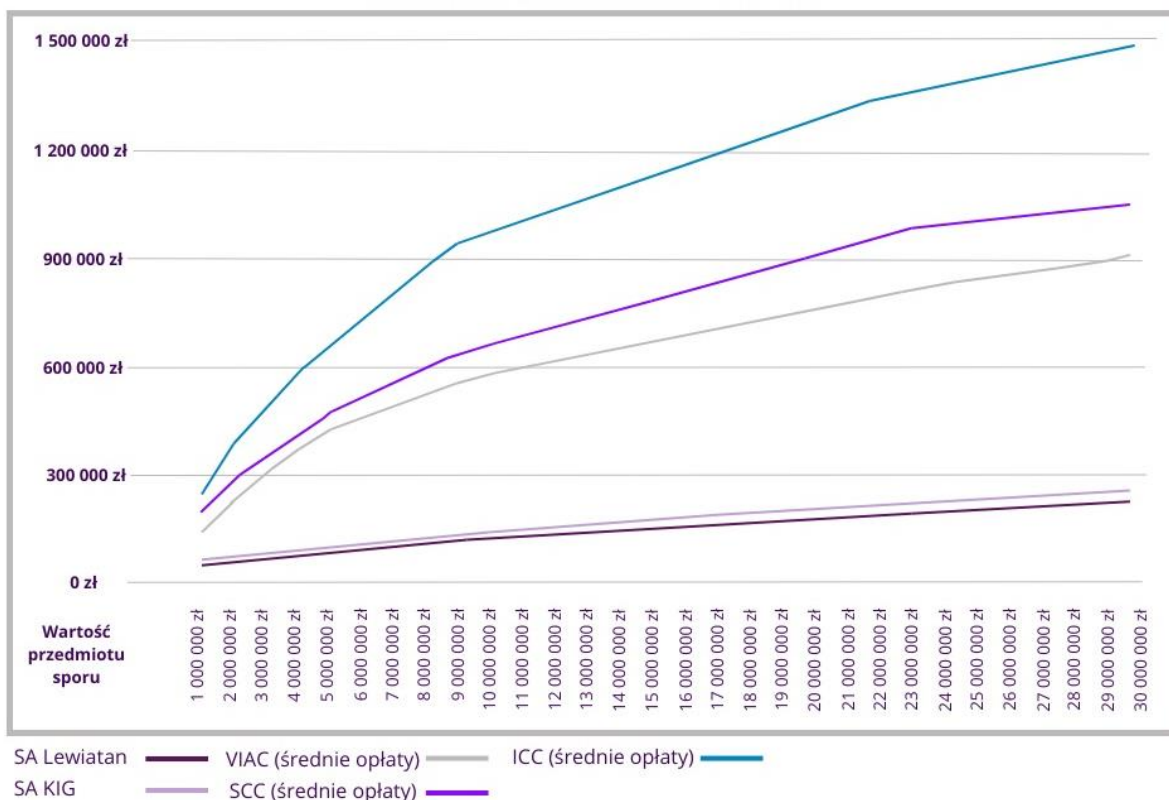


²⁸ Źródło: <https://kocurpartners.com/upload/2023/11/raport-www.pdf>



Opłaty w arbitrażu administrowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) oraz Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan są kilkukrotnie niższe niż opłaty w arbitrażu administrowanym przez zagraniczne instytucje arbitrażowe, takie jak: Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej w Wiedniu (VIAC) czy Trybunał Arbitrażowy przy Sztokholmskiej Izbie Handlowej (SCC).

Schemat 34 - Opłaty w sądach arbitrażowych w Polsce i na świecie w sprawach rozpoznawanych przez trzech arbitrów



Zasadniczo, w arbitrażu strona, która spór wygrała, może żądać od przeciwnika zwrotu całości rozsądnych kosztów poniesionych w związku z tym sporem. Jest to więc zasada odmienna od zasady obowiązującej w sądach państwowych, gdzie wygrywający otrzymuje jedynie zryczałtowany zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz innych kosztów ponoszonych w trakcie postępowania. W większości przypadków trybunały arbitrażowe, kierując się przede wszystkim wynikiem sprawy, zobowiązują stronę przegrywającą do zwrotu znaczącej części wszystkich kosztów poniesionych przez przeciwnika, w tym opłat oraz wynagrodzenia pełnomocników i biegłych. Z wyjątkiem spraw o wartości przedmiotu sporu do 200 000 zł w arbitrażu strona wygrywająca może liczyć zatem na zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości wielokrotnie wyższej od stawek zastępstwa procesowego stosowanych w polskich sądach państwowych. Ponadto do rozstrzygnięcia części spraw niezbędna jest wiedza specjalistyczna, a taka sytuacja może mieć miejsce w większości sporów związanych z realizacją Projektów PPP. Konieczne jest wówczas korzystanie z opinii biegłych. W arbitrażu strony zasadniczo

przedstawiają opinie własnych biegłych, którym płacą wynagrodzenie ustalane na zasadach rynkowych. Trybunały arbitrażowe mogą też same zlecić biegłym sporządzenie opinii. Strona, która poniosła koszty opinii biegłego, może żądać, aby trybunał arbitrażowy nakazał drugiej stronie zwrot tych kosztów.²⁹

Przy wyborze arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów strony powinny mieć zatem na uwadze przed wszystkim następujące aspekty:

²⁹ Źródło: <https://kocurpartners.com/upload/2023/11/raport-www.pdf>

Schemat 35 - Najistotniejsze kwestie analizy przy wyborze postępowania arbitrażowego, tzw. check-lista

- Klauzula arbitrażowa – powinna zostać sformułowana w umowie zgodnie z wymaganiami prawa
- Wybór rodzaju arbitrażu – arbitraż instytucjonalny lub *ad hoc*
- Wybór instytucji arbitrażowej – w przypadku arbitrażu instytucjonalnego
- Wybór pomiędzy krajowym (np. SAKiG, Lewiatan) a arbitrażem międzynarodowym (np. ICC, LCIA, SCC)
- Miejsce arbitrażu – determinuje jurysdykcję
- Wskazanie prawa właściwego
- Koszty arbitrażu
- Wybór arbitrów – arbitrzy powinni posiadać wiedzę specjalistyczną dla danego projektu
- Język postępowania
- Zasady przedstawiania dowodów w arbitrażu
- Możliwość wykonalności orzeczenia arbitrażowego

Przykłady

W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym budowy i wieloletniej eksploatacji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, w trakcie realizacji inwestycji doszło do sporu pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym. Partner zarzucał stronie publicznej opóźnienia w przekazaniu decyzji środowiskowych, co – jego zdaniem – wpłynęło na harmonogram prac oraz generowało dodatkowe koszty, które powinny zostać zrekompensowane. Podmiot Publiczny kwestionował te roszczenia, uznając, że Partner Prywatny nie dostosował właściwie organizacji prac do realiów projektu i nie podjął działań minimalizujących opóźnienia.

Strony podjęły próbę rozwiązania sporu w drodze negocjacji, a następnie mediacji prowadzonej przez niezależny ośrodek mediacyjny. Mimo wysiłków, nie udało się osiągnąć kompromisu – rozbieżności interpretacyjne były zbyt głębokie, a interesy stron zbyt odległe. W rezultacie, zgodnie z klauzulą arbitrażową zawartą w Umowie o PPP, spór został skierowany do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Postępowanie arbitrażowe okazało się dla stron korzystne z wielu powodów. Dzięki jego jednoinstancyjnemu charakterowi oraz możliwości sprawnego zaplanowania przebiegu procesu, rozstrzygnięcie zapadło w ciągu 11 miesięcy, co – biorąc pod uwagę złożoność sprawy – oznaczało istotne skrócenie czasu w porównaniu z przewidywaną długością postępowania przed sądem powszechnym. Dodatkowo, arbitrzy zostali wybrani spośród ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny rozpoznania sprawy i pozwoliło uniknąć konieczności tłumaczenia zawłości technicznych. Istotną zaletą była także poufność postępowania – strony mogły dochodzić swoich praw bez konieczności ujawniania szczegółów umowy oraz roszczeń w przestrzeni publicznej, co miało szczególne znaczenie z uwagi na społeczne i medialne zainteresowanie projektem. Orzeczenie trybunału było ostateczne i wykonalne, co pozwoliło na szybkie zakończenie sporu oraz powrót do stabilnej realizacji projektu.

3.2 Postępowanie przed sądem powszechnym

Jeżeli strony Umowy o PPP nie zdecydują się na wybranie arbitrażu jako właściwego do rozstrzygania sporów w formalnym etapie spornym, to w razie braku osiągnięcia porozumienia na etapie polubownym, wszelkie spory wynikające z Umowy o PPP będą zasadniczo rozstrzygane w drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

W przypadku postępowania sądowego swoboda stron w kształtowaniu przebiegu postępowania zostaje ograniczona niemal do minimum. Strony muszą bowiem ściśle przestrzegać postanowień KPC, a przebieg postępowania jest ściśle powiązany ze „sprawnością” orzekania sądu.

Strony w Umowie o PPP mogą jednak wskazać sąd właściwy dla rozstrzygania sporów z niej wynikających, przykładowo sąd właściwy dla siedziby Podmiotu Publicznego albo Partnera Prywatnego.

Przykładowe Postanowienia



Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Podmiotu Publicznego.

W przypadku postępowania sądowego, KPC przewiduje specjalny tryb dla postępowań gospodarczych, który w większości przypadków, jako właściwy dla umów o roboty budowlane, będzie obejmował Projekty PPP. Tryb ten nakłada na strony postępowania gospodarczego szereg obowiązków i ograniczeń oraz przewiduje rygorystyczne skutki ich niedochowania przez strony. Strony przykładowo muszą w określonym czasie przedstawić wszystkie znane im dowody oraz twierdzenia pod rygorem braku możliwości ich podnoszenia na późniejszym etapie. Tryb ten przewiduje również pewne ograniczenia dowodowe, np. uznając dowód z zeznań świadków za dowód subsydiarny wobec innych dowodów.

Jest to o tyle istotne, że w ostatnim czasie odnotowuje się znaczne obłożenie sprawami wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, które stanowi m. in. następstwo pandemii COVID-19 oraz dużym napływem tzw. spraw frankowych do

sądów powszechnych. Sytuacja ta znacząco wpłynęła na czas rozpoznawania postępowań gospodarczych. W przypadkach skomplikowanych sporów budowlanych, które mogą być charakterystyczne dla sporów z Umów o PPP, czas trwania postępowania do momentu uzyskania prawomocnego orzeczenia może wynosić nawet od pięciu (5) do dziesięciu (10) lat.

Tryb gospodarczy sporów sądowych różni się od postępowania cywilnego prowadzonego na zasadach ogólnych. Wprowadzone w nim rozwiązania miały doprowadzić do przyspieszenia rozpoznawania spraw gospodarczych, jednak w praktyce nałożyły one na strony postępowania szereg obowiązków i ograniczeń, które są często nieadekwatne dla skomplikowanych sporów gospodarczych, w szczególności sporów cechujących się licznymi dowodami oraz skomplikowanymi aspektami technicznymi.

Schemat 36 - Najważniejsze cechy sądowego postępowania gospodarczego

- Obowiązek powołania wszelkich twierdzeń i dowodów w pozwie lub odpowiedzi na pozew.
- Spóźnione twierdzenia i dowody podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe lub potrzeba ich powołania wynikała później.
- Brak możliwości występowania z nowymi roszczeniami w toku postępowania.
- Nie stosuje się przepisów dotyczących przekształcenia podmiotowego stron postępowania.
- Brak możliwości wniesienia powództwa wzajemnego.
- Subsydiarny charakter dowodu z zeznań świadków – dopuszczalny, gdy po wyczerpaniu innych dowodów pozostaną niewyjaśnione fakty (prymat dowodu z dokumentów i opinii biegłego).
- Wyrok sądu I instancji zasądzający świadczenie stanowi podstawę do uzyskania zabezpieczenia roszczenia.

Główną zaletą poddania sporu pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny są gwarancje państwowe, jakie daje taka procedura. Postępowanie sądowe jest przejawem władzy państwowej, a orzeczenia wydają zasadniczo niezależni sędziowie, którzy nie są powiązani ze stronami (strony mają prawo zgłaszać swoje zastrzeżenia co do niezależności sędziów), którzy dodatkowo mogą korzystać z przymusu państwowego (np. w przypadku niestawiennictwa świadków). Co więcej orzeczenia wydawane przez sąd powszechny korzystają z autorytetu danego im przez państwo, a więc są wykonalne i niepodważalne (z wyjątkiem przewidzianych w KPC procedur). Sądownictwo powszechne daje również możliwości weryfikacji prawidłowości wydawanych orzeczeń poprzez możliwość skorzystania z kontroli instancyjnej oraz skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Z drugiej strony, jak już było to wielokrotnie wskazywane w Wytycznych, postępowania przed sądem powszechnym stanowią najbardziej czasochłonną

metodę rozwiązywania sporów. Generują również ryzyko, że spór będzie rozpoznawany przy braku odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, ze względu na ograniczenia w tym zakresie po stronie sędziów i występujące problemy z biegłymi.

Przykłady



W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym modernizacji i wieloletniego utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie R, po trzech (3) latach od zawarcia Umowy o PPP doszło do sporu pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym w zakresie zasadności wprowadzenia korekty wynagrodzenia. Partner Prywatny argumentował, że znaczący wzrost cen energii elektrycznej oraz komponentów do wymiany opraw LED przekroczył standardowe ryzyka rynkowe i w związku z tym wystąpił o dostosowanie wysokości opłaty za dostępność. Gmina uznała, że żądanie nie znajduje podstawy w umowie i odmówiła renegocjacji stawek.

Strony podjęły krótką próbę rozwiązania sporu w drodze negocjacji, jednak już na wczesnym etapie rozmowy zostały przerwane ze względu na sztywne stanowiska obu stron. Umowa o PPP nie zawierała klauzul przewidujących inne metody polubownego rozstrzygania sporów, takie jak mediacja, koncyliacja czy rozstrzygnięcie przez eksperta. W efekcie, Partner Prywatny skierował sprawę bezpośrednio do sądu powszechnego.

Spór był rozpatrywany w trybie postępowania gospodarczego. Pomimo stosunkowo niewielkiej wartości przedmiotu sporu, sprawa okazała się złożona – wymagała przeprowadzenia opinii biegłego z zakresu ekonomiki projektów infrastrukturalnych oraz energetyki, którego wyznaczenie zajęło sądowi ponad dziewięć (9) miesięcy. Opinie były niejednoznaczne, a sąd kilkakrotnie przekładał terminy rozpraw z powodu braków kadrowych i obłożenia wydziału. Całość postępowania trwała ponad cztery (4) lata i zakończyła się prawomocnym orzeczeniem na korzyść Podmiotu Publicznego.

Pomimo formalnego zwycięstwa Gminy, postępowanie sądowe znacząco wpłynęło na dalszą realizację Umowy o PPP. Partner Prywatny, rozczarowany brakiem próby wypracowania kompromisu, ograniczył swoją gotowość do współpracy w

Przykłady

zakresie bieżącej eksploatacji infrastruktury – każda wątpliwość była rozstrzygana w sposób literalny i zachowawczy. Atmosfera braku zaufania doprowadziła do licznych incydentów związanych z opóźnieniami w usuwaniu usterek, wzrostem liczby reklamacji ze strony mieszkańców i koniecznością częstszego angażowania nadzoru ze strony Gminy.

3.3 Różnice pomiędzy postępowaniem sądowym i arbitrażowym

Postępowanie sądowe i postępowanie arbitrażowe to dwa (2) odrębne sposoby rozstrzygania sporów, które pomimo, że na pierwszy rzut oka wydają się podobne, każdy posiada swoje unikalne cechy i zastosowanie.

Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi dwoma postępowaniami są odmienne procedury, które regulują sposób rozstrzygania sporów w ramach tych instytucji. Różnica ta wpływa na odmiennność tych postępowań i ich właściwość dla poszczególnych podmiotów.

Istotną różnicą pomiędzy postępowaniem sądowym a arbitrażowym jest obecność wiedzy eksperckiej w ramach tych postępowań. W postępowaniu arbitrażowym, strony mają dużą swobodę w wyborze składu orzekającego. Strony mogą wybrać arbitrów, którzy posiadają wiedzę specjalistyczną w ramach tematu, który jest przedmiotem postępowania dotyczącego sporu z Umowy o PPP. Ponadto, w postępowaniu arbitrażowym strony wskazują ekspertów, którzy mają sporządzić opinię specjalistyczną w postępowaniu.

Natomiast w postępowaniu przed sądem powszechnym kwestia posiadania wiedzy specjalistycznej w temacie danego sporu jest powszechnie podnoszonym problemem w ostatnich latach. Sędziowie przydzielani są w ramach losowania do spraw z różnych dziedzin. Przykładowo ten sam sędzia może orzekać w tym samym okresie w sprawach z zakresu wad instalacji budowlanej, kredytów frankowych oraz prawidłowego wykonania usług informatycznych. Sędzia powołany do rozpoznania sprawy czerpie więc swoją wiedzę specjalistyczną przede wszystkim z dowodów przedstawionych przez strony i z opinii biegłych. Jednocześnie istnieje ryzyko, że

sędzia wybrany w ramach procedur losowania może nie być ekspertem w danej dziedzinie.

Jednocześnie w ostatnich latach sygnalizuje się problem z dostępnością i specjalizacją biegłych³⁰. Liczba biegłych sądowych jest niewystarczająca, a ich obłożenie w ramach toczących się spraw znacząco wpływa na czas sporządzanych przez nich opinii, co w rezultacie wydłuża czas rozpoznawania danej sprawy.

Kolejną istotną różnicą pomiędzy postępowaniem sądowym a arbitrażem jest instancyjność. Orzeczenie sądu arbitrażowego jest co do zasady ostateczne, podczas gdy orzeczenia sądów powszechnych podlegają kontroli instancyjnej w postępowaniu apelacyjnym.

³⁰ Źródło: <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/reforma-przepisow-o-bieglych-sadowych>

Schemat 37 - Najistotniejsze różnice pomiędzy postępowaniem sądowym i arbitrażowym

	Postępowanie sądowe	Arbitraż
Skład orzekający	Postępowanie przed sądem powszechnym – sędzia wyznaczony w drodze losowania.	Arbitrzy wyznaczeni przez strony – możliwość wyboru arbitrów posiadających wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie.
Czas	Długość postępowania jest poza kontrolą stron. W ostatnim czasie znacznie wydłużył się czas postępowań, w tym w szczególności postępowań dotyczących sporów gospodarczych. Postępowanie może trwać wiele lat, nawet od pięciu (5) do dziesięciu (10) lat w obydwu instancjach.	Postępowanie może trwać od jednego (1) roku do trzech (3) lat (zależy od tego, jaki harmonogram postępowania strony ustalą z trybunałem)
Skuteczność	Gwarantuje rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie może podlegać apelacji do II instancji, jak również skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Ostateczne rozstrzygnięcie ma charakter wiążący dla stron.	Gwarantuje rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie jest ostateczne i wiążące dla stron, a wyrok arbitrażowy może być podważany w ograniczonych przypadkach.

	Postępowanie sądowe	Arbitraż
Koszt	Wysoki koszt	W niektórych przypadkach wyższy koszt
Inne	Wiedza ekspercka dostarczana przez ekspertów powoływanych przez sąd. Obecnie zauważalny jest problem z dostępnością biegłych sądowych. Brak zachowania poufności (ryzyko ujawnienia informacji wrażliwych).	Wiedza ekspercka dostarczana przez eksperta powołanego przez strony. Zachowana poufność.

Wytyczne PPP

Tom V: Rozwiązywanie sporów w Projektach PPP
